

투자계약증권의 법률상 쟁점 검토 및 감독정책상 시사점

— 증권성 판단, 발행, 유통 과정을 중심으로

안상현*

국문초록

본 연구는 투자계약증권의 요건 및 증권성 판단 사례를 살펴보고, 증권성 판단, 발행 및 유통 단계에서 쟁점이 되는 사항을 중점적으로 검토하였다. 증권성 판단과 관련하여, 자본시장법의 문언상 전매차익형은 투자계약증권에 포함되지 않으나 입법론으로는 이를 포함함이 타당하다. 조각투자 증권성 판단, 가상자산 관련 판결 및 수사사안에서도 이러한 요건은 문제되고 있으며, 특히 가상자산의 사례에서 전매차익형의 포함여부에 주목할 필요가 있다. 실무상 쟁점과 관련하여, “타인이 수행”요건에서 “타인”은 사업자와 법률상·계약상 관계가 있는 자로 해석할 필요가 있고, 그로 인한 발행인의 플랫폼화 문제는 발행인 인가제도를 도입하여 해결할 필요가 있다.

한편 증권신고서상 투자자 보호장치 관련 사항은 임시적인 통제수단이므로, 장기적으로는 자본시장법상 관련 규제의 도입을 통해 통제하는 것이 타당하다. 또한 투자계약증권이 공모발행 되는 경우를 명시적으로 집합투자에서 배제하여 발행 단계에서의 예측가능성을 제고할 필요가 있다. 투자계약증권의 유통과 관련해서는, 특례규정 신설을 통하여 증권 및 기초자산의 동시 양도 문제를 해결할 필요가 있고, 비금전신탁 수익증권의 유통규제에 준하는 유통규제를 도입할 필요가 있다.

□ 주제어: 투자계약증권, 조각투자, 토큰증권, 증권성판단, 증권신고서

□ JEL: K4 법적 절차, 법제도 및 불법 행동

투고일: 2026.1.9.

수정일: 2026.3.27.

게재확정일: 2026. 4.24.

* 금융감독원 선임조사역(ash1031@fss.or.kr)

※ 본 논문의 내용은 연구자 개인의 의견이며 소속기관의 입장이 아님을 밝힙니다.

I. 조각투자 개념 및 투자계약증권 규제연혁 개관

1. 조각투자의 개념 및 투자계약증권의 특성

(1) 조각투자 개념 및 조각투자 시장 개관

조각투자는 일반적으로 2인 이상의 투자자가 실물자산, 그 밖에 재산적 가치가 있는 권리를 분할한 청구권에 투자·거래하는 신종 투자형태의 의미로 받아들여지고 있다.¹⁾ 조각투자는 법령상 정의된 개념은 아니며, 실무상 조각투자는 투자계약증권(자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”) 제4조 제6항) 발행 또는 금융혁신지원 특별법(이하 “금융혁신법”)에 따른 혁신금융서비스 지정을 통한 비금전신탁 수익증권²⁾ 발행을 통하여 투자자로부터 자금을 조달하여 사업을 수행한 후 그 수익을 분배하는 형태로 이루어져 왔기 때문에, 국내에서 조각투자는 투자계약증권 또는 비금전신탁 수익증권의 발행 및 유통과 유사한 의미로 이해되고 있다.³⁾

-
- 1) 금융위원회·금융감독원, 2022, 조각투자 등 신종증권 사업 가이드라인, 보도자료(4.28.), 별첨 1면.
 - 2) 현행 자본시장법상 신탁업자의 비금전신탁 수익증권 발행근거가 마련되어 있지 않기 때문에 (자본시장법 제110조 제1항), 비금전신탁 수익증권 형태의 조각투자는 혁신금융서비스 지정을 통해 동 규정의 적용을 배제하는 형태로 진행되어 왔다가, 2025.6.16. 비금전신탁 수익증권의 발행플랫폼에 대한 인가단위 규제를 신설하기 위한 개정 자본시장법 시행령이 시행되었으며, 현행 규정 하에서는 비금전신탁 수익증권은 자산유동화법상 수익증권 발행 규정을 통하여 발행된다(금융위원회, 2008, 조각투자 샌드박스 제도화, ATS의 ETF 거래 허용 등을 위한 자본법 시행령·규정 입법예고, 보도자료, (2.3.) 참조). 나아가 비금전신탁 수익증권의 발행근거를 자본시장법에 두기 위한 자본시장법 개정작업도 진행 중이며(2024.11. 발의된 김상훈 의원안(의안번호 2205423) 참고), 동 개정이 완료될 경우 비금전신탁 수익증권 발행 시 자산유동화법상 수익증권 발행 규정에 근거하지 않아도 비금전신탁 수익증권을 발행할 수 있을 것으로 예상된다.
 - 3) 국내 조각투자 플랫폼 업체로 언급되는 업체들 중에는, 금융위원회로부터 증권성에 대한 판단(예컨대, 미술품 및 한우에 대한 금융위원회(증권선물위원회)의 증권성 판단(2022.11) 및 조치면제(2023.7.)(이하 그러한 증권성판단 및 조치면제 과정을 포괄하여 “증권위 사업개편”)을 받거나 혁신금융서비스 지정을 받지 아니한 업체도 존재하는 것으로 보인다. 그런데 이와 같은 형태를 조각투자의 새 유형으로 보기에는 시장에서의 영향력이 제한적이며, 당해 업체들의 사업모델이 현행 법령 및 금융당국의 가이드라인을 준수하고 있는지 확인되지 아니한 측면도 존재한다.

국내 조각투자는 2019년 말 부동산 조각투자 플랫폼 ‘카사’의 부동산 조각투자 서비스(비금전신탁 수익증권 형태)가 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정받음으로써 본격적으로 제도권 내로 도입되었다. 조각투자는 토큰증권(Security Token)의 국내 도입에 따른 수혜를 받을 것으로 예측되는 대표적인 분야로 전망되고 있다. 예컨대 국내 토큰증권 시장은 2028년 233조원(GDP 대비 9.4%), 2030년 367조원(GDP 대비 14.5%)에 달할 것으로 전망된 바 있고, 이 전망에 따르면 2030년 국내 토큰증권 시장에서 비금융자산, 부동산 등은 각각 29.8%, 19.9%의 비중을 차지할 것으로 예상된다.⁴⁾ 종래⁵⁾ 조각투자 관련 제도는 원칙적으로 증권(투자계약증권 또는 비금전신탁 수익증권)이 실물발행되거나 전자등록되는 것을 전제로 하고 있으나, 2026.2.3. 토큰증권 관련 자본시장법 및 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”) 개정이 완료됨에 따라(2027.2.4. 시행예정), 토큰증권의 발행 및 유통 인프라가 법제화되고 권리추정력 등 증권에 준하는 법률상 보호장치가 마련되었으며, 투자매매·중개업자의 투자계약증권 매매·중개행위가 허용되었는바⁶⁾, 토큰화된 증권을 거래할 수 있는 장외거래시설이 운영되어 경쟁과 혁신이 촉진되고, 발행인의 자본시장 접근성 및 자본조달 비용이 감소할 것으로 기대된다.⁷⁾

금융감독원 전자공시시스템(DART)에 제출된 증권신고서를 기준으로 2026.3.26. 현재 증권신고서의 효력이 발생한 투자계약증권은 6개의 발행사가 미술품(4개사), 한우(1개사), 한돈(1개사)을 기초자산으로 하여 발행한 25건(미술품 18건, 한우 6건, 한돈 1건)의 사례가 존재한다.⁸⁾ 이 중 2개사(미술품, 한돈)를 제외한 나머지 발행사들은 2022.11.29. 증권선물위원회(이하 “증선위”)의 증권성 판단 및 조건부 제재절차 보류·유예 조치를 받은 이후, 2023.7.12. 증선위로부터 동 보류·유예 조치의 이행을 확인받은 바 있다. 위 증권의 총 모집가액은 240.34억원으로, 미술품 투자계약증권은 184.2억원, 한우 투자계약증권은

4) 삼일PwC경영연구원, 2024, 조각투자의 이해 및 STO(토큰증권 발행) 시장 전망, Issue Brief(2024.6.), 24면, 김갑래, 2024, 토큰증권 발행·유통 제도 구축에 있어서의 주요 이슈 및 발전 방안, 자본시장연구원 이슈보고서 24-12, (6.20.), 3면.

5) 본고에서 투자계약증권과 관련한 국내외 제도 및 사례에 관한 설명은, 특별한 언급이 없는 한 본고의 최종 수정일인 2026.3.26.을 기준으로 한다.

6) 토큰증권 관련 법률 개정안의 주요 내용은 금융위원회, 2026, 토큰증권 도입 및 투자계약증권 유통을 위한 「전자증권법」·「자본시장법」 개정안 국회 본회의 통과, 보도자료(1.15.) 참조.

7) 김갑래, 앞의 보고서(2024.6.20.), 5면.

8) 음악 저작권 조각투자의 경우 2022.4.20. 증선위는 동 조각투자의 기초자산인 음악 저작권료 참여청구권 구조가 투자계약증권에 해당한다고 판단한 바 있으나, 발행인이 사업구조를 신탁 수익증권 발행 및 전자등록 방식으로 사업구조를 전환하여 투자계약증권 발행으로 이어지지 않았다(증권선물위원회, 2022, “(주)뮤직카우의 사업재편 이행여부 점검결과 보고 및 (주)뮤직카우에 대한 제재 면제안”, 의결 제219호, (11.29.), 2면).

53.98억원, 한돈 투자계약증권은 2.16억원이 발행되었다.⁹⁾ 한편 발행된 투자계약증권 중 청산이 완료된 건은 5건(미술품 2개사 3건, 한우 1개사 5건)(모집금액 총 40.71억원)으로, 발행인이 발표한 연평균 수익률(세전 기준)은 미술품의 경우 78.51%, 44.32%, 31.3%, 한우의 경우 11%~17% 수준이었다.¹⁰⁾

한편 비금전신탁 수익증권을 활용한 조각투자의 경우, 부동산(3개사), 음악 저작권(1개사)을 기초자산으로 한 발행사례가 존재한다.¹¹⁾ 이 중 부동산 조각투자 발행사들의 경우 분산원장기술로 관리되는 블록체인 기반의 부동산 수익증권 거래 플랫폼 서비스에 대한 혁신금융서비스 지정을 받았는데, 증권 발행 시 신탁법(제78조) 및 전자증권법에 따른 수익증권 발행과 동시에 분산원장기술로 관리되는 동량의 디지털자산 수익증권을 발행하고, 조각투자 발행사가 운영하는 플랫폼에서 동 디지털자산 수익증권을 매매함으로써 비금전 신탁 수익증권을 거래할 수 있도록 하는 서비스를 제공하고 있다.

(2) 조각투자 발행형식별 비교

조각투자의 발행형식의 결정은 단순히 기초자산과 투자자를 매개할 도관체의 종류를 정하는 것을 넘어서, 조각투자의 증권성 판단, 도산절연의 난이도, 증권신고서 심사절차, 유통시장, 투자자권리 등에도 영향을 미치고 있으며, 그 차이점을 간단히 비교한 결과는 아래 [표 1]과 같다.

9) 2026.3.26. 현재 1건의 증권신고서(한우 1건)가 제출 후 효력이 발생하지 않았으며, 그 모집금액은 12.18억원이다.

10) 투게더아트가 홈페이지(weshareart.com/disclosurelist)에 게시한 2024.8.6. 수시공시(청산금 지급 등) 및 2024.10.28. 수시공시(청산금 지급 등), 열매컴퍼니가 홈페이지(artnguide.co.kr/customer-service/public-notice/701)에 게시한 2025.4.15. 수시공시, 스타키피가 홈페이지(hankcow.co.kr/funding/home)에 게시한 공지사항 참조.

11) 대출채권(1개사), 항공기 엔진(1개사) 조각투자에 대한 혁신금융서비스 지정도 이루어진 바 있으나, 현재 증권신고서 제출 등 발행절차가 구체적으로 진행되지는 않고 있다.

[표 1] 조각투자의 발행형식별 차이점 비교(2026.2.3. 개정 자본시장법 기준)

항목	투자계약증권	비금전신탁 수익증권
발행근거	자본시장법	혁신금융서비스 지정 (자본시장법 개정 중)
증권성 판단	판단과정 필요	성질상 불필요
도산절연 조치	투자자 보호 목적상 필요	성질상 불필요
증권신고서 심사	자본시장법	혁신금융서비스 지정조건 자산유동화법 (자본시장법 개정 중)
증권발행 형태	실물발행, 전자등록(분산원장 포함)	실물발행, 전자등록(분산원장 포함), 분산원장 디지털증권
증권 유통방식	기초자산 양수도절차 필요 (사업자 도산절연 요구 시)	수익증권 또는 분산원장 디지털증권 양수도
권리추정력	전자등록시 존재	전자등록시 존재
투자자 권리	투자계약	신탁계약
인허가	발행	불필요
	유통	발행플랫폼 인가제도 도입
		유통플랫폼 인가제도 도입

투자계약증권(자본시장법 제4조 제6항)은 자본시장법상 증권 정의에 대한 포괄주의 규제 도입에 따라 새로이 도입된 증권으로서, 그 적용범위가 폭넓게 인정될 수 있다. 또한, 투자계약증권의 정의를 충족하는 증권이 다른 증권의 유형에 해당하는 경우에는 해당 증권을 투자계약증권으로 파악할 필요가 없다는 것이 유력한 견해이다(투자계약증권의 보충성).¹²⁾ 이에 따라 투자계약증권 발행을 위해서는 발행인이 의도하는 사업구조가 투자계약증권에 해당하는지를 사전에 판단할 필요가 있고, 당국 역시 같은 입장을 취하고 있다.¹³⁾ 또한 투자계약증권의 보충성으로 인해 집합투자적 성격을 가진 계약 가운데 자본시장법상 집합투자기구를 이용하지 않는 투자구조가 주로 투자계약증권에 해당하는 경우가 되고, 발행인의 고유재산과 공동사업의 대상자산의 분별관리가 어려워지는 특성이 존재한다.¹⁴⁾ 이에 따라, 뮤직카우의 증권성 검토 및 제재 면제사례 및 한우 및 미술품 관련 5개사의 증선위 사업개편 사안에서 금융당국은 투자자의 권리·재산을 사업자의 도

12) 김건식·정순섭, 2023, 자본시장법(제4판), 박영사, 65면 참조. 상세한 논의는 “II.2.” 참조.

13) 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.4.28.) 중 별첨, 2면.

14) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 66, 67면. 상세한 논의는 “II.2.” 참조.

산위험과 법적으로 절연시킬 것을 일관되게 요구하고 있다. 이러한 방침에 따라 현재 발행된 투자계약증권은 기초자산에 대하여 투자자가 민법상 공동소유권을 보유하는 형태를 취하고 있으며, 청약증거금 및 기초자산 매각대금 등 사업수익에 대해서도 도산절연 조치를 취하고 있다.¹⁵⁾

한편, 투자계약증권 발행이 자본시장법상 모집·매출 요건을 충족하는 경우 증권신고서를 제출하여야 하는바(자본시장법 제119조),¹⁶⁾ 현재 발행된 투자계약증권의 증권신고서의 심사, 제재 등의 규제체계는 다른 종류의 증권과 동일하다. 즉 증권신고서의 중요 사항 기재누락 또는 거짓기재 등에 대해서는 금융위원회(금융감독원)의 정정요구(자본시장법 제122조 제1항) 등의 조치가 가능하고, 또한 발행인은 증권신고서의 기재와 관련한 민사상 손해배상책임(자본시장법 제125조) 또는 형사상, 행정처분상 제재대상이 될 수 있다(자본시장법 제132조, 제444조 제13호).

공모 투자계약증권은 전자증권법상 전자등록의 대상이 되는바(전자등록업무규정 제1-3조)¹⁷⁾ 전자등록되어 발행되는 경우 전자증권법상 권리추정력(전자증권법 제35조)이 인정된다. 그러나, 예탁결제원 주식·사채 등의 전자등록업무규정(제36조 제1항 제9호) 및 동 시행세칙(제36조 제2항 제6호)상 기초자산의 소유권을 분할하여 취득하는 구조의 투자계약증권을 발행하는 경우에는 계좌부의 대체기재(전자증권법 제30조)가 제한되는바, 현재 발행되고 있는 미술품, 한우, 한돈 투자계약증권이 전자등록되더라도 계좌간 대체의 전자등록이 제한될 수 있다.¹⁸⁾ 다만, 기초자산의 소유권을 투자자가 보유하고 있는 투자계약증권 구조에서는, 투자계약증권의 양수도만으로는 기초자산의 소유권이 당연히 이전되지 않기 때문에, 기초자산의 소유권 이전절차를 별도로 거칠 필요가 있다.¹⁹⁾ 그리고 투자계약증권에서 투자자 및 사업자의 권리의무는 통상적으로 투자계약에

15) 투자계약증권의 도산절연조치의 상세한 내용에 대해서는 “IV.2.” 참조.

16) 온라인소액투자중개(크라우드펀딩)를 통해 일정규모 이하의 투자계약증권을 모집하는 경우 증권신고서 제출이 면제될 수 있으나(자본시장법 제9조 제27항, 제117조의10), 크라우드펀딩을 통한 투자계약증권 발행사례가 없고 현재 투자계약증권의 발전단계상 장려되기 어려운바(상세한 논의는 “IV.2.” 참조) 본고의 검토범위에서는 제외하였다.

17) 종래 투자계약증권은 전자증권법 및 그 하위규정상 전자등록의 대상에 포함되지 않았으나, 2024.1.18. 전자등록업무규정 개정으로 공모 투자계약증권에 대한 전자등록 근거가 마련되었다.

18) 위 예탁결제원 업무규정 및 시행세칙은 예탁결제원에 개설되는 계좌부(즉 전자증권법상 고객관리계좌부 또는 계좌관리기관등 자기계좌부)에 적용되는 것이므로, 특정 계좌관리기관(증권사)의 고객계좌부 내에서의 계좌대체까지 명시적으로 제한하고 있지는 않다. 즉 동일 증권사에 투자계약증권을 전자등록한 투자자 간에는, 증권사의 소유권 이전사실 확인 등을 거쳐서 고객계좌부 내 계좌대체를 진행하는 것이 가능할 수 있다. 다만, 투자계약증권의 전자등록 실적 저조, 계좌관리기관의 실무상 부담 등으로 실제 사례는 찾기 힘들 것으로 예상된다.

서 정해지는데, 자본시장법은 투자계약 자체를 정의하고 있지는 아니하나, 투자계약증권에 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 “계약상의 권리”가 표시되도록 요구하고 있다(자본시장법 제4조 제6항). 마지막으로 투자계약증권의 발행을 위한 별도의 금융투자업 인가규제는 존재하지 아니하나, 조각투자 유통플랫폼의 도입 시 투자계약증권 장외거래중개업 인가단위를 신설할 방침이 제시되었고²⁰⁾, 2026.2.3. 자본시장법이 개정되어 투자매매·중개업자의 투자계약증권 매매·중개행위가 허용됨에 따라 인가단위 등 하위법령 개정이 진행될 것으로 예상된다. .

반면, 비금전신탁 수익증권의 경우, 현행 자본시장법상으로는 신탁업자가 발행할 수 있는 수익증권은 금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권에 국한되기 때문에(자본시장법 제110조 제1항), 앞에서 살펴본 바와 같이 혁신금융서비스 지정을 통하여 동규정에 대한 특례를 인정받는 형태를 취하고 있다. 그럼에도 비금전신탁 수익증권은 일종의 수익증권발행신탁(신탁법 제78조)으로서 (현행법상으로도) 자본시장법상 증권성의 분류는 수익증권(자본시장법 제4조 제5항)으로 성질결정될 것으로 보이는바, 증권성의 판단 필요성은 낮다고 판단되며, 신탁의 특성상 신탁행위를 넘어서는 도산절연 조치의 필요성도 별도로 요구되지는 않는다고 생각된다.

한편, 비금전신탁 수익증권의 증권신고서는 각 혁신금융사업자의 홈페이지 등을 통해 게시·공고되고 있으나, 이는 혁신금융서비스 지정 조건에 따른 것이고 자본시장법상 증권신고서 제도에 근거한 조치는 아니다.²¹⁾ 따라서, 현재까지 발행된 비금전신탁 수익증권의 증권신고서는, 자본시장법상 증권신고서에 대한 심사체계(예컨대, 앞서 언급한 금융위원회(금융감독원)의 정정요구 등)에 근거하여 심사되지 못했던 측면이 존재하며, 자본시장법 및 그 하위규정에서도 증권신고서의 기재사항이나 첨부서류, 서식 등을 정하고 있지 아니하다. 금융위원회는 비금전신탁 수익증권 발행 관련 구체적인 발행감독은 투자계약증권과 같이 증권신고서 심사를 통해 진행하겠다는 방향을 밝힌 바 있으나,²²⁾ 현재 구체적인 증권신고서 양식이나 작성기준은 마련되지 않은 상황으로 보이며, 아직

19) 투자계약증권 및 기초자산의 양수도 절차와 관련한 상세한 논의는 “IV.3.” 참조.

20) 금융위원회·금융감독원, 2023, 토큰 증권(Security Token) 발행·유통 규율체계 정비방안, 금융위원회 보도자료, (2.3.)(이하 “토큰증권 가이드라인”) 참조.

21) 예컨대, 뮤직카우의 혁신금융서비스 지정 공고문(금융위원회, 2022, (주)뮤직카우 및 키움증권(주) 등 2개 신탁회사의 혁신금융서비스 지정, 공고 제2022-335호, (9.7.), 4면)에서는 증권신고서 제출에 대한 규정(자본시장법 제119조 제1항)을 규제특례 대상 금융관련 법령으로 정하고, 증권신고서의 제출을 공시규정·절차 관련 부가조건으로 정하고 있다.

22) 금융위원회, 앞의 보도자료(2025.2.3.), 9면.

자산유동화법을 이용한 비금전신탁 수익증권 발행사례도 존재하지 않는다.²³⁾ 장기적으로 비금전신탁 수익증권의 발행근거가 자본시장법에 마련되면, 비금전신탁 수익증권에 대한 증권신고서 심사체계가 완전히 자본시장법으로 편입될 것으로 보인다.

비금전신탁 수익증권은 전자증권법상으로는 신탁법에 따른 수익자가 취득하는 수익권(제2조 제1호 사목)으로서 전자등록의 대상이 되고, 이에 따라 전자증권법에 따른 권리추정력(전자증권법 제35조)이 인정되며, 증권의 양수도 역시 계좌부의 대체기재(전자증권법 제30조)로 이루어질 수 있다. 또한, 신탁의 특성상 수익증권의 양수도로 수익권이 이전할 뿐, 신탁재산은 여전히 수탁자에게 신탁되어 있기 때문에 투자계약증권과 같은 기초자산의 소유권 별도 이전 문제가 발생하지 않는다. 다만 수익증권과 대응되는 분산원장 디지털증권이 발급되었던 경우, 그 디지털증권은 아직 전자증권법상 전자등록대상에 해당하지 아니하여 권리추정력이 인정되지 않았는바, 분산원장 디지털증권의 권리변동과 수익증권의 권리변동이 일치되지 않을 위험이 존재하였다.²⁴⁾ 다만, 2026.2.3. 전자증권법 개정에 따라 전자증권법상 요건을 준수한 분산원장 등록 증권의 권리추정력이 인정될 것인바, 이러한 위험은 개정 전자증권법 시행 이후에는 발생하지 않을 것으로 보인다. 마지막으로, 비금전신탁 수익증권에서 투자자, 위탁자²⁵⁾, 신탁업자(수탁자)의 권리의무는 신탁계약에서 정하여지며, 통상적으로는 신탁재산의 신탁, 관리 및 처분, 수익배분 및 수익자의 의사결정 등의 사항을 정하고 있다.

마지막으로 발행 관련 투자중개업 인가단위의 신설에도 현행 자본시장법상 비금전신탁 수익증권의 발행은 제한되어 있는바(자본시장법 제110조 제1항), 동 규정에 대한 자본시장법 개정²⁶⁾ 이전에는 비금전신탁 수익증권은 자산유동화법상 수익증권 발행 관련 규정을 근거로 하여 발행된다. 한편, 유통플랫폼 인가규제 관련 자본시장법 시행령 역

23) 발행플랫폼 인가단위를 추가한 2025.6.16. 자본시장법 시행령 개정 이후에도 혁신금융서비스 지정기간 내에 있는 사업자는 혁신금융서비스 지정조건에 따라 증권신고서를 제출할 수 있고, 지정기간이 만료되고 법령정비기간(금융혁신법 제10조의2)마저 만료된 사업자의 경우에는 발행플랫폼 금융투자업인가를 취득한 후 자산유동화법에 근거하여 비금전신탁 수익증권을 발행할 수 있다(금융위원회, 앞의 보도자료(2025.2.3.), 3면).

24) 이러한 사항은 투자자들에게도 증권신고서 등을 통해 사전 고지되고 있다(예컨대, ㈜카사코리아가 금융위원회에 제출한 2024.10.11.자 증권신고서(부동산관리처분신탁 수익증권) 11면 및 12면 참조).

25) 위탁자는 기초자산의 소유권을 신탁하는 원소유자이며, 비금전신탁 수익증권 플랫폼의 계열회사(기초자산을 선매입하는 경우)인 경우도 있고(뮤직카우 등), 동 플랫폼과 특수관계가 없는 계약상대방인 경우도 있다.

26) 국회에 신탁업자의 비금전신탁 수익증권의 발행근거를 두기 위한 자본시장법 및 전자증권법 개정안(김상훈의원 등 13인, 의안번호 : 2205423, 2205425)이 계류되어 있다.

시 2025.9.23. 시행되어 비금전신탁 수익증권의 유통 관련 투자중개업 인가단위가 신설되었다. 금융위원회는 발행플랫폼 신규인가는 기존 혁신금융사업자에 대한 인가심사를 우선하고, 유통플랫폼의 경우 현재 시장규모를 고려하여 신규인가 개수를 2개 이하로 제한할 예정임을 밝힌 바 있다.²⁷⁾ 이러한 기조에 따라 2026.2.13. 금융위원회는 2개 컨소시엄(NXT컨소시엄, KDX)에 대한 수익증권 장외거래중개업 예비인가를 승인하였다.²⁸⁾

(3) 투자계약증권을 이용한 조각투자에 대한 연구 필요성 및 논의 방향

위 비교 결과를 살펴보면, 투자계약증권은 증권성 판단에 대한 기준 정립 및 발행·유통 규제체계 구축 차원에서 초기 단계에 있으며 그만큼 개선과 논의의 필요성이 많아 보인다. 우선 비금전신탁 수익증권과 달리 투자계약증권은 그 특성상 증권성 판단 과정이 필요한바, 투자계약증권을 이용한 조각투자가 안정적으로 진행되기 위해서는 그 증권성 요건에 대한 상세한 논의가 정립될 필요가 있다. 그러나 현재 금융당국의 가이드라인은 원칙 중심이므로 성질상 개별 사안에 대한 명확한 지침을 제공하기 어렵고²⁹⁾, 당국의 증권성 판단 및 투자계약증권의 발행사례 축적도 많이 이루어지지 않은 상황이므로 구체적·개별적인 쟁점에 활용될만한 논의가 널리 진행되지는 않은 것으로 보인다. 또한, 인허가 규제(발행플랫폼 및 유통플랫폼 인가 등) 및 인프라 규제(업자별 영업행위규제 및 시장규제 등) 체계가 구축되고 있는 비금전신탁 수익증권과 달리, 현행 자본시장법상 투자계약증권은 발행인의 자격이 정해져 있거나 인가제로 운영되고 있지 아니하며 이에 대한 입법적 논의도 진행되지 않고 있다. 유통단계에 있어서도 토큰증권 가이드라인에서 유통플랫폼(장외거래중개업)의 제도화 방향이 제시된 바 있으나 그간 투자계약증권에 대하여는 자본시장법상 유통규제의 적용이 배제되어 왔는데(자본시장법 제4조 제1항), 2026.2.3. 자본시장법 개정으로 해당 규정이 폐지됨에 따라 유통규제의 내용에 대한 논

27) 금융위원회, 2025, 조각투자 장외거래소(유통플랫폼) 신규인가 운영방안 안내, 보도자료(9.4.), 2면.

28) 금융위원회, 2026, 수익증권 장외거래중개업(조각투자 장외거래소) 예비인가 금융위원회 정례회의('26.2.13.) 의결, 보도자료(2.13.) 참조. 이에 따르면, NXT컨소시엄과 KDX는 6개월 이내에 예비인가의 내용 및 조건을 이행한 후 「금융산업구조개선법」상 출자승인 및 본인가를 신청해야 하며, 본인가가 최종 승인되면 영업을 개시하게 된다. 다만 NXT컨소시엄의 경우 공정거래위원회의 행정조사가 개시되는 경우 예비인가에 부과된 조건에 따라 본인가 심사가 중단된다.

29) 금융위원회, 앞의 보도자료(2022.4.28.), 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2023.2.3.)가 대표적이다.

의가 본격화될 것으로 보이나, 현재까지는 구체적인 윤곽이 제시되지는 않은 상황이다.³⁰⁾ 그리고 비금전신탁 수익증권과 달리 투자계약증권의 양수도 시 기초자산의 양수도 절차(반환청구권의 채권양도절차)를 함께 수행하여야 하는 점이 투자계약증권의 유통에 큰 장애물로 평가되고 있다.³¹⁾

한편, 투자계약증권은 자본시장법이 정한 증권 종류로서, 증권신고서의 제출 및 심사와 관련해서는 현행 자본시장법상의 체계가 그대로 적용되고, 금융감독원에서도 투자계약증권 증권신고서와 관련한 「기업공시서식 작성기준」을 개정하는 등 공시심사 기준을 확립하여 왔으며, 증권신고서에 대한 정정요구 등 심사사례도 다수 축적되어 왔다. 즉 투자계약증권은 제도적 미완성에도 불구하고 투자자보호를 위한 개별 증권신고서 심사는 체계적으로 수행되어 온 것으로 판단되고, 이러한 측면에서 투자계약증권의 심사체계 및 증권신고서 심사 시 쟁점을 검토하는 것은 막 자본시장법상 증권신고서 심사체계에 편입된 비금전신탁 수익증권의 증권신고서 심사 및 동 심사에 수반한 투자자보호장치 심사에 시사하는 점도 크다고 할 수 있다.

요컨대 투자계약증권은 증권성 판단 및 발행·유통 규제체계 구축 차원에서 해결되지 않은 쟁점이 다수 존재하여 그 해법에 대해 논의가 필요한 영역이 큰 반면, 조각투자 상품 일반의 관점에서는 투자자(금융소비자) 보호 차원에서 참고할 사항이 다수 축적되어 있다. 이에 따라 본고에서는 투자계약증권에 집중하여 (i) 투자계약증권의 요건별 의미를 엄밀히 검토하고, (ii) 금융당국, 법원 및 수사기관 등의 증권성 판단사례를 분석하여 증권성 판단의 경향을 살펴보고자 하며, 아울러 (iii) 증권성 판단, 증권신고서 제출 및 심사, 발행 이후 유통시장 등 투자계약증권의 설계, 생성(발행), 유통 단계에서 실무상 문제되는 각종 쟁점을 검토하고, 감독정책상 개선점 내지 시사점을 도출해보고자 한다.

2. 투자계약증권 규제연혁 개관

투자계약증권은 타인의 노력에 의하여 수익이 결정되는 모든 증권을 자본시장법상

30) 토큰증권 법안의 내용에 대해서는 “IV.3.” 참조. 또한 금융위원회는 2026.3. 토큰증권 제도, 인프라 세부설계를 위한 토큰증권 협의체를 발족하였고 동 협의체에서는 장외거래소 인가, 유통공시, 거래한도 등 유통 단계에서의 규제방향을 논의할 것으로 보인다(금융위원회, 2026, 민·관 합동 「토큰증권 협의체」 Kick-off 회의 개최, 보도자료(3.4.)).

31) 김갑래, 앞의 보고서(2024.6.20.), 21면.

“증권”으로 포섭하기 위하여 자본시장법 제정 시 도입된 개념으로서, 자본시장법의 포괄주의 원칙으로의 전환을 가장 특징적으로 보여주는 것이라 할 수 있다.³²⁾ 그러나 자본시장법 시행 이후 장기간 투자계약증권의 발행사례는 존재하지 않다가, 2022.4.20. 증권선물위원회는 (주)뮤직카우가 발행한 음악 저작권료 참여청구권이 투자계약증권에 해당한다고 판단하면서, (주)뮤직카우가 증권신고서의 제출 없이 위 청구권을 발행한 것이 자본시장법상 증권신고서 제출의무(자본시장법 제119조 제1항) 위반이라고 판단하였다.³³⁾

또한 금융위원회는 “조각투자 등 신종증권 사업 가이드라인”(이하 “신종증권 가이드라인”)을 발표하여 사업자가 조각투자 상품의 증권성을 판단할 수 있는 기준을 제시하면서 투자계약증권 증권성이 인정되는 경우 현행 자본시장법의 규제를 모두 준수하면서 조각투자 증권을 발행할 수 있는 점을 분명히 하였다.³⁴⁾ 이후 증권선물위원회는 2022.11.29. (주)뮤직카우가 사업재편 조건을 이행함에 따라 증권신고서 미제출 등에 대한 제재면제를 의결하였고, 동시에 한우(1개사)·미술품(4개사) 조각투자 사업자가 발행한 조각투자상품이 자본시장법상 투자계약의 요건에 해당한다고 판단하였고, 뮤직카우 사례와 마찬가지로 사업재편 조건 이행을 조건으로 증권신고서 미제출에 대한 제재를 면제하였다.³⁵⁾ 한우·미술품 조각투자에 대한 증권성 판단사례는 투자자에게 기초자산에 대한 민법상 공동소유권이 부여된 조각투자에 대한 최초의 증권성 판단사례이며, 또한 혁신금융서비스 지정을 통한 발행-유통시장 겸영 특례를 허용하지 않은 사례라는 특징이 있다.

이후 금융위원회는 2023.2.3. 토큰증권(Security Token) 발행과 관련한 규제체계를 정비하기 위하여 토큰증권 가이드라인을 발표하였는데, 투자계약증권 규제 관점에서는 ①기존 신종증권 가이드라인에 더하여 투자계약증권 판단원칙을 요건별로 제시하였고, ②투자계약증권의 토큰증권 발행을 위한 법률개정 방안을 제시하였으며, ③투자계약증

32) 심인숙, 2008, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 상 ‘투자계약증권 개념에 대한 검토, 비교사법, 제15권 제1호(통권40호), 55면.

33) 금융위원회·금융감독원, 2022, 저작권료 참여청구권의 증권성 여부 판단 및 (주)뮤직카우에 대한 조치, 보도자료, (4.20.) 참조. 다만, 투자계약증권의 첫 적용사례인 점 등을 고려하여 사업자의 도산위험과 투자자 권리·재산의 절연 등의 제재절차 보류 조건(사업재편 조건)을 증선위 의결일로부터 6개월 이내에 충족하는 경우 증권신고서 제출의무 위반에 따른 제재를 면제하기로 결정하였다.

34) 금융위원회, 앞의 보도자료(2022.4.28.).

35) 금융위원회·금융감독원, 2022, 조각투자 시장의 규율을 지속적으로 확립해 나가겠습니다, 보도자료, (11.29.) 참조. 이후 증권선물위원회는 2023.7.12. 위 5개사의 사업재편 요건을 충족하였음을 확인하여 최종적인 제재가 면제되었으며(증권선물위원회, 2023, (주)스탁키퍼 등 5개사의 사업재편 이행여부 점검결과 보고 및 5개사에 대한 제재 면제안, 의결 제135호, (7.12.)), (주)테사를 제외한 4개사가 증권신고서를 제출하여 투자계약증권을 발행하였다.

권의 자본시장법상 증권 유통규정 적용, 장외거래업 인가 신설, 한국거래소 상장시장 개설 등의 방향을 제시하였다는 특징이 있다. 이 중 한국거래소 상장시장 개설과 관련하여서는, 2023.12.13. 한국거래소가 KRX 신중증권(투자계약증권·비금전신탁 수익증권)시장 개설에 대한 혁신금융서비스 지정을 받은바 있으며³⁶⁾, 이에 따라 2025.9.22. 신중증권시장 운영규정이 제정되어 시행을 앞두고 있다.³⁷⁾ 한편 발행규제와 관련하여 2023.6.13. 자본시장법 시행령 개정에 따라 투자계약증권의 경우 과거 1년 간 모집·매출 금액이 10억원 미만이었다도 증권신고서를 제출하도록 하여 공모발행에 대해서는 발행 규모와 관계없이 증권신고서 심사를 받도록 하였고, 2024.1.18.에는 전자등록업규정이 개정되어 투자계약증권의 전자증권법상 전자등록에 대한 법률상 근거가 마련되었다.

한편 조각투자 사업자들에 대한 사업재판 승인이 마무리됨에 따라 금융감독원은 2023.8.1. 투자계약증권의 증권신고서 제출·심사 등 공시체계 개편 내용을 발표하였다. 그 주요 내용은 투자계약증권 증권신고서 서식 전면개정, 공시심사부서 내 전담심사조직 운영, 발행 시 유의사항(先증권성 판단 검토 등) 및 주요 심사방향 발표 등이 포함되었다.³⁸⁾ 이러한 공시체계 개편 이후 2023.8.11. 최초의 투자계약증권 증권신고서가 접수되었으나, 2023.8.29. 금융감독원이 증권신고서 정정을 요구한 후 2023.8.31. 철회되었고, 이후 2023.10.11. 두 번째로 접수된 투자계약증권 증권신고서에 대해서도 2023.11.2. 정정요구가 부과되었으나, 2023.11.23. 정정한 증권신고서의 효력이 2023.12.15. 최종 발생함으로써 최초의 투자계약증권 증권신고서의 청약절차가 개시되었다. 금융감독원은 최초의 투자계약증권 증권신고서의 효력발생 사실을 공지하면서, 1인당 청약한도, 청약 방식, 투자자적합성 테스트, 수수료체계 개편, 기초자산의 실물확인 방안 등 구체적인 심사 내용을 제시하였다.³⁹⁾ 그 이후, 금융감독원은 2024.7.9. 그간 심사과정에서 축적된 모범 사례를 활용하여 투자계약증권 투자자 보호 모범규준을 마련하였다. 위 투자자보호 모범규준은 기초자산, 내부통제, 청약·배정, 투자자권리 등의 주요 항목별로 증권신고서 작성을 위한 원칙, 세부설명 및 작성예시를 제공하여 발행인의 증권신고서 작성부담 경감 및 신속한 자금조달 유도, 투자계약증권 시장의 조기정착 등에 기여하는 것을 목표로

36) 금융위원회·금융감독원, 2023, 조각투자 방식 신중증권 장내시장 개설 혁신금융서비스 신규 지정, 보도자료, (12.13.).

37) 신중증권시장 운영규정 시행세칙으로 정하는 날에 시행 예정이다.

38) 금융감독원, 2023, “투자계약증권 최초 발행 예정” 공시·심사체계 개편으로 투자자 보호를 강화하겠습니다, 보도자료(8.1.).

39) 금융감독원, 2023, 2023.12.15.부터 투자계약증권 투자가 가능해집니다, 보도자료, (12.15.).

하고 있다.⁴⁰⁾

이후 투자계약증권의 규제체계는 큰 변화 없이 개별 증권신고서의 심사 위주로 전개되어 왔다. 다만, 2025.5.2. 소상공인(백년가게)의 사업에 기반한 투자계약증권의 유통을 위한 장외거래 플랫폼이 혁신금융서비스로 지정되었는데, 소상공인이 증권사를 통해 투자계약증권을 발행하면, 혁신금융사업자(한국ST거래)가 그 투자계약증권을 거래할 수 있는 유통 플랫폼을 운영하는 구조로 보인다.⁴¹⁾ 위 혁신금융서비스의 부가조건은 비금전신탁 수익증권 유통플랫폼 규제내용과 유사한 측면이 있는바, 위 부가조건의 분석을 통해 투자계약증권의 유통플랫폼 규제의 방향을 예측할 수 있을 것으로 보인다.⁴²⁾ 한편, 2026.2.3. 자본시장법 개정에 따라 투자계약증권에 대한 자본시장법상 유통규제의 적용이 폐지되었는바(자본시장법 제4조 제1항), 투자매매·중개업자도 투자계약증권의 매매·중개가 가능해졌으나 하위법령상 인가단위 신설, 유통규제의 내용 등의 정비가 필요한 상황이다.

II. 투자계약증권 요건별 의미 검토

자본시장법상 투자계약증권의 정의는 “특정 투자자가 그 투자자와 타인(다른 투자자를 포함) 간의 공동사업에 금전등을 투자하고 주로 타인이 수행한 공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시된 것(자본시장법 제4조 제6항)”이다. 이와 같은 자본시장법상 정의조항을 요건별로 분리하면, ①투자자와 타인(다른 투자자 포함) 간의 공동사업, ②금전등의 투자, ③주로 타인이 수행, ④손익을 귀속받을 계약상 권리로 구분할 수 있다. 그런데 투자계약증권은 미국 1933년 증권법(Securities Act of 1933)(이하 “미국 증권법”)상 투자계약(investment contract)을 모델로 도입된 개념으로서⁴³⁾, 미국 증권법상 투자계약의 개념요소의 기준은 1946년 연방대법원의 SEC v. W.J. Howey

40) 금융감독원, 2024, 투자계약증권 투자자 보호 모범규준 마련, 보도자료(7.10.).

41) 금융위원회·금융감독원, 2025, 소상공인 사업 기반 투자계약증권 유통플랫폼 등 혁신금융서비스 28건 신규 지정 의결, 보도자료, (5.2.).

42) 위 혁신금융서비스에 대한 상세한 검토는 “IV.3” 참조.

43) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 58면.

Co. 판결(이하 “Howey 판결”)⁴⁴⁾에서 실시한 기준(이하 “Howey 기준”)을 따르고 있다.⁴⁵⁾ 따라서, 자본시장법상 투자계약증권의 요건별 의미를 이해하기 위해서는 Howey 기준에서 실시하는 투자계약의 요건을 먼저 이해할 필요가 있다.

1. 미국 증권법상 투자계약증권의 요건 및 일본의 투자계약증권 개념 도입⁴⁶⁾

Howey 기준에서 미국 연방대법원은 투자계약의 요건을 “(i) 공동사업에, (ii) 자금을 투자하여, (iii) 오로지 사업자나 제3자의 노력으로부터, (iv) 수익을 기대하는 계약·거래·계획을 의미한다”고 실시한 바 있고⁴⁷⁾, 이러한 기준은 이후 미 법원의 판례에서 약간의 수정을 거친 바 있으나 거의 그대로 유지되고 있다. 우선 첫 번째 요건인 공동사업에 대해서는 미국 연방대법원이 명확한 요건의 의미를 실시하지 아니한바, 미국 법원의 판례는 수직적 공동성(vertical commonality)만을 요구하는 것과 수평적 공동성(horizontal commonality)까지 요구하는 것으로 분화되어 있다.⁴⁸⁾ 여기서 수평적 공동성이란 투자자들의 출연금의 집합(pooling)과 투자자들 사이의 손익의 비례배분을 의미하며, 이를 통해 개별투자자의 운명이 다른 투자자의 운명과 연계되는바 개념상 투자자가 1인뿐인 거래는 제외된다.⁴⁹⁾ 한편 수직적 공동성은 투자자와 사업자의 관계에 주목하여 투자자와 사업자 간 운명의 상호의존성에 주목하는 개념이다. 다수의 판례는 수평적 공동성을 요구하고

44) SEC v. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293(1946).

45) 재정경제부, 2006, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제정안」 설명자료, 보도자료(6.30.)(이하 “재정부 자본시장법 설명자료”), 11면에 의하면, 자본시장법을 기초한 재정경제부는 투자계약증권 개념은 미국 증권법상 투자계약을 정의하기 위해 미국 판례에서 형성한 Howey 기준을 원용한 것이라고 한다.

46) 미국 증권법, 판례상 투자계약증권의 요건별로 확립된 법리에 대한 상세한 내용은 심인숙, 2006, 미국 증권법상 증권(Security) 개념, 중앙법학 제8집 제2호, 심인숙, 앞의 논문(2008) 참조)

47) 원문은 다음과 같다. “an investment contract means a contract, transaction or scheme whereby a person invests his money in a common enterprise and is led to expect profits solely from the efforts of the promoter or a third party”

48) 김건식·송옥렬, 2004, 미국의 증권규제, 홍문사, 148면. 수직적 공동성을 요구하는 판례는, 통상적인 의미의 수직적 공동성(모든 투자자의 성공여부가 권유자 또는 제3자의 노력과 성공에 불가분적으로 연결되어 있을 것)만 인정되면 족하다는 것과 “엄격한 수직적 공동성”(수직적 공동성 개념에 더하여, 권유자 또는 제3자의 성패 역시 개별 투자자의 손익과 상관관계가 인정될 것을 추가적으로 요구하는 개념)을 요구하는 것으로 분화된다(상세한 내용은 심인숙, 앞의 논문(2008), 63면 참조).

49) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 59면.

있으며, 최근 판례의 경향도 그러하다고 한다.⁵⁰⁾

두 번째 요건과 관련하여, 연방대법원은 금전이 현금에 한정된 것이 아니라고 판시하였고,⁵¹⁾ 이에 따라 용역의 제공, 신용대여 및 담보제공 등 재산적 가치를 가지는 것은 모두 투자수단으로 인정된다. 그리고 세 번째 요건과 관련하여, Howey 판결에서는 “오로지(solely)”라는 문구를 사용하고 있으나, 그렇게 되면 투자자가 사소한 부분에서 투자에 참여하는 경우 투자계약이 아니라고 보게 되어 불합리한 결과를 초래할 수 있으므로, 대부분의 판례에서 “제3자의 노력이 부인할 수 없을 정도로 중대한 것이어서 기업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상의 노력으로부터 비롯되는” 것인지⁵²⁾를 세 번째 요건을 판단하는 기준으로 사용하고 있다.

네 번째 요건과 관련하여, “수익”은 금전의 형태를 취할 필요는 없으나, 순수한 사업성과의 배분을 추구하는 수익배분형은 물론 시가 상승에 따른 전매차익을 추구하는 전매이익형을 모두 포괄하는 개념⁵³⁾이며, 확정수익도 포함된다. 다만, 실물자산을 스스로 사용하거나 소비할 목적으로 매입하는 경우에는 이익에 해당하지 않으며,⁵⁴⁾ 수익이 제3자의 노력으로 말미암아 발생한 것이 아니라면 증권으로 보지 않는다.⁵⁵⁾ 여기서 수익의 기대의 유무는 사업자 등의 선전자료, 구두약속, 계약서 등을 토대로 판단한다. 또한 Howey 판례는 “계약, 거래, 계획”이라는 용어를 사용하였는바, 자본시장법상의 정의(계약상의 권리)보다 포괄적인 표현을 사용하고 있다.

일본 금융상품거래법 또한 미국 증권법상 투자계약증권의 개념을 간주유가증권으로서 도입하였다고 평가되는데⁵⁶⁾, 이를 집단투자스킴지분이라 한다. 집단투자스킴지분은 “조합계약, 익명조합계약, 투자사업유한책임조합계약 또는 유한책임사업조합계약에 근

50) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 60면.

51) International Brotherhood of Teamsters v. Daniel, 439 U.S. 551, 560(1979) 참조.

52) 이는 연방 제9항소법원의 판시사항으로(Glenn W. Turner Enterprises, Inc., 474 F. 2d 476(9th Cir), cert. denied, 414 U.S. 821(1973)) 대부분의 항소법원이 이와 같은 입장을 택하고 있다고 한다(심인숙, 앞의 논문(2008), 61면).

53) United Housing Found., Inc. v. Forman 421 U.S. 837 (1975) 참조. 수익배분형 및 전매이익형이라는 표현은 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 60면의 표현이며, 판례 원문의 표현은 전매차익형의 경우 초기 투자금의 개발로 인한 자본수익(capital appreciation resulting from the development of initial investment)이며, 수익배분형의 경우 투자자 자금의 활용으로 인한 이익에의 참여(participation in earnings resulting from the use of investors' funds)이다.

54) United Housing Found., Inc. v. Forman 421 U.S. 837 (1975) 참조.

55) 김건식·송옥렬, 앞의 책(2004), 148면.

56) 한국증권법학회, 2015, 자본시장법 주석서 I (개정판), 박영사, 21-22면.

거한 권리, 사단법인의 사원권, 기타의 권리 가운데, 해당 권리를 가진 자(출자자)가 출자 또는 각출한 금전을 충당하여 하는 사업에서 발생한 수익의 배당 또는 해당 출자대상사업에 관련된 재산의 분배를 받을 수 있는 권리”로 정의되어 있고, “출자자 전원이 출자대상사업에 관여하는 경우”를 집단투자스킴지분에서 배제하고 있다(일본 금융상품거래법 제2조 제2항 제5호). 이러한 집단투자스킴의 정의는 대체로 Howey 기준의 요건에 대응하는 것으로 이해되나, 공동사업 요건과 관련하여 복수의 투자자를 요건으로 하고 있지 않아 수직적 공동성만 인정되면 충분하다고 해석된다.⁵⁷⁾ 또한 집단투자스킴은 전매차익형을 포함할 수 없다고 해석되며, 이에 따라 전매차익형을 포함하도록 개정해야 한다는 견해가 존재한다.⁵⁸⁾

2. 자본시장법상 투자계약증권 요건 검토

(1) 공동사업

자본시장법상 공동사업이 동법에 정의된 용어는 아니므로, 그 해석에 있어서는 앞서 살펴본 Howey 기준상 공동사업에 대한 논의가 참고가 될 수 있다. 그러나 자본시장법은 “투자자와 “타인” 간 공동사업”이라고 규정하면서 그 타인에 다른 투자자를 포함한다고 명시하고 있기 때문에, 미국에서의 판례상 대립과 달리 자본시장법상의 공동사업은 수평적 공동성과 수직적 공동성을 모두 포함한다는 견해도 존재하나⁵⁹⁾, 수평적 공동성이 결여된 경우에도 공동사업을 충족하는 것으로 해석할 수 있으며, 투자자가 1인만 존재하는 경우도 가능하다는 견해도 유력하다.⁶⁰⁾ 토큰증권 가이드라인은 수평적 공동성을 “2인 이상 투자자 간의 수익 관련성이 있는 경우”로, 수직적 공동성을 “투자자와 발행인 간의 수익 관련성이 있는 경우”로 정하면서, 수평적 공동성 또는 수직적 공동성이 있는 경우 공동사업에 해당한다고 정하고 있다. 따라서 금융당국의 입장은 후자의 입장으로 이해된다.

이러한 당국의 입장에 대해서는, 미국에서 일임매매를 수행하는 증권업자와 다수의

57) 한국증권법학회, 앞의 책(2015), 22면, 김종원, 2023, 투자계약증권의 판단기준에 대한 비교법적 고찰, 기업법연구 제37권 제4호, 487면.

58) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 64면,

59) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 62면, 이정수, 2023, 가상자산의 증권성 판단기준 -서울남부지방법원 2020.3.25. 선고 2019가단225099 판결, 상사판례연구 제36권 제2호, 143면 참조

60) 심인숙, 앞의 논문(2008)(81면), 한국증권법학회, 앞의 책(2015), 23면.

투자자 간 일임매매계약에서 투자자 간 공동성을 결하여 투자계약으로 판단하지 않은 사례⁶¹⁾가 있다는 이유 등으로 의문을 제기하는 견해가 존재한다.⁶²⁾ 그러나 투자자가 1인인 경우에도 해당 공동사업에서 발행인이 다수의 잠재적 투자자들에게 청약의 권유를 수행하는 경우도 존재할 수 있고, 이러한 경우에도 투자계약증권성을 부정하는 것은 금융소비자의 보호가 취약해질 우려가 있는 바 금융당국의 견해는 그 필요성이 인정된다고 판단된다.⁶³⁾

또한 자본시장법이나 Howey 기준은 공동사업의 법률상 사업구조에 대하여 언급하고 있지 않고 있다. 2인 이상의 자가 공동사업을 경영하는 경우 상정할 수 있는 사업 구조 형태는, 상법상 회사나 조합, 신탁법상 신탁 또는 민법상 조합 등이 있다. 그런데, 상법상 회사의 경우 그 지분은 지분증권에 해당함은 별다른 의문이 없고, 민법상 조합은 조합채무에 대한 무한책임이 유지되는 한 자본시장법상 증권이 될 수 없다. 또한, 사업자와 투자자 사이의 관계가 신탁에 해당하거나, 상법상 조합(익명조합 또는 합자조합)에 해당하는 경우에도 투자계약증권이 인정되기 어렵다.⁶⁴⁾ 전자의 경우에는 집합투자에 해당할 가능성이 높고, 후자의 경우에는 지분증권에 해당할 가능성이 높기 때문이다. 따라서 투자계약증권의 공동사업은 사업자와 투자자간 채권적 형태의 투자계약이 일반적인 구조가 될 것으로 판단된다.

(2) 금전 등의 투자

한편 자본시장법상 “금전등”은 금전 외에 재산적 가치가 있는 것이 포함되므로(자본시장법 제3조 제1항), 재산적 가치가 인정되는 한 모든 것이 투자수단으로 인정되는바,

61) 김건식·송옥렬, 앞의 책(2004), 148면.

62) 이정수, 앞의 논문(2023), 143면.

63) 예컨대, 자본시장법상 모집 해당여부는 실제 투자를 행한 자의 숫자가 아니라 청약의 권유를 받은 자의 수를 기준으로 검토하는바, 투자자가 1인인 경우에도 투자계약증권의 공모에 해당하는 경우가 존재할 수 있을 것이며, 이러한 경우까지 증권성을 배제하게 되면 당해 발행인이 증권신고서 제출 없이 공동사업을 수행하는 경우에 자본시장법상 증권신고서 미제출에 따른 제재 등을 할 수 없게 될 것이다.

64) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 63면. 재경부 자본시장법 설명자료 11면은 투자계약증권이 상법상 익명조합·민법상 조합을 활용한 간접투자기구에 관한 지분을 포괄할 수 있다고 하나, 상법상 익명조합의 출자지분은 자본시장법상 지분증권에 해당하고(자본시장법 제4조 제4항), 민법상 조합은 본문에서 본 바와 같이 무한책임성으로 인해 증권성이 인정되기 어렵다고 보여진다.

Howey 기준에서의 태도와 거의 동일하다고 판단된다. 토큰증권 가이드라인도 투자되는 금전은 반드시 법정통화(금전)일 필요는 없으며, 법정 통화와의 교환 가능성, 재산적 가치의 유무 등을 종합적으로 고려한다고 하여 같은 입장이나, “법정 통화와의 교환 가능성”을 고려요소로 명시한 차이가 있다.

(3) 주로 타인이 수행

또한 “주로 타인이 수행”요건과 관련하여, 자본시장법은 이미 “주로”라는 표현을 사용하고 있는바 투자자가 사업수행에 참여하는 경우도 포함하며, 앞서 살펴본 Glenn W. Turner Enterprises, Inc. 사건에서 미국 법원이 실시한 사항과 유사하게 판단하는 것이 일반적이다.⁶⁵⁾ 토큰증권 가이드라인 역시 타인(발행인)의 노력이 부정할 수 없을 정도로 증대하고 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상의 노력이어야 한다고 하여 같은 입장에 있는 것으로 보인다. 이에 더하여, 토큰증권 가이드라인은 타인(발행인)이 모든 사업을 수행하지 않더라도, 투자자 외 사업주체의 공동적·집단적 노력이 있는 경우를 포함하고, 발행주체와 사업주체가 형식적으로만 상이한 경우 공동 발행인으로 볼 수 있으며, 투자자가 사업 일부를 수행하더라도 사업 대부분의 사항에 대한 정보비대칭성이 있는 경우 타인이 수행한 것으로 볼 수 있다고 기재하고 있다.

토큰증권 가이드라인이 기재하고 있는 사항은, Howey 사안에서 연방대법원이 투자계약증권의 해당여부 판단은 형식보다는 실질을 우선하여 경제적 실질을 중시하여야 한다고 전제⁶⁶⁾한 점, 증권규제의 적용이유는 정보의 비대칭성 때문인 점⁶⁷⁾을 고려한 것으로 보인다. 그러나 이러한 기재에도 불구하고, 자본시장법상 “주로 타인이 수행한 공동사업”에서의 타인의 범위가 발행인에 국한되는 것인지 의문점이 존재하며, 이에 대해서는 “Ⅲ.3.”에서 상세히 검토한다.

65) 이정수, 앞의 논문(2023), 144면, 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 63면, 심인숙, 앞의 논문(2008), 86면.

66) 심인숙, 앞의 논문(2008), 59면.

67) 이정수, 앞의 논문(2023), 144면.

(4) 손익을 귀속받는 계약상 권리

(가) 결과에 따른 손익의 귀속

마지막으로 자본시장법상 투자계약증권은 “(공동사업의) 결과에 따른 손익을 귀속 받는 계약상의 권리가 표시된 것”을 요건으로 하고 있다. 이는 “결과에 따른 손익의 귀속”과 “계약상의 권리”라는 요소로 양분할 수 있다. 우선 전자에 대해서 살펴보면, 이는 공동사업의 운영자가 공동사업을 영위하여 얻은 이익으로 해석되므로, 전매차익은 이에 해당하지 않는다고 보는 견해가 다수인 것으로 보이며⁶⁸⁾, 나아가 투자대상의 가격상승으로 인한 시세차익도 이에 해당하지 않는다고 보는 견해도 있는 것으로 보인다.⁶⁹⁾

투자자가 공동사업 결과에 따른 손익의 귀속 없이 자신이 보유한 투자계약증권에 대한 전매차익만을 기대할 수 있는 경우⁷⁰⁾에는 요건에 해당하기 어렵다는 점은 문언에 비추어 비교적 명백해 보인다.⁷¹⁾ 현재까지의 증권성 판단사례에서 감독당국은 “손익의 귀속”요건의 판단기준을 명백히 밝히지는 아니하였다. 유통시장이 개설된 뮤직카우 발행 “청구권”의 증권성 판단사례나, 미술품 조각투자에 대한 증권성 판단사례에서 증선위는

68) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 64면, 이정수, 앞의 논문(2023), 150면-151면.

69) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 64면. 반면 이정수, 앞의 논문(2023), 150면-151면은 투자계약증권의 투자성 판단에 있어 이익귀속형과 전매차익형을 구분하고, 전매차익형을 “계약상 권리가 표시되어 있지는 않지만 전매과정에서 이익이 발생할 수 있고, 그 이익이 타인의 경영적 노력으로 인한 것으로서, 보유자가 발행자에 대해 이익분배에 대한 계약상 권리를 법적으로 직접 요구할 수는 없는 것”으로 규정하면서 전매차익형이 투자계약증권에 해당하지 않는다고 한다. 이에 따르면, “투자대상의 가격상승으로 인한 시세차익”이 공동사업의 손익으로 계상되어 투자자들이 발행인에게 이익분배에 대한 계약상 권리를 요구할 수 있다면 투자계약증권에 해당하는 것으로 판단될 것으로 보인다. 본고에서의 전매차익형은 이정수, 앞의 논문(2023), 150면-151면에서 정의한 전매차익형을 의미한다.

70) 논의의 선명성을 위하여 본문에서는 공동사업 결과에 따른 손익의 귀속이 없는 경우를 전매차익형으로 분류하였으나, 현실적으로는 전매차익형에 해당하더라도 전매차익이 투자자가 기대하는 주된 투자이익이고, 부수적으로나마 공동사업 결과에 따른 손익 귀속이 발생할 수 있는 경우가 다수일 것으로 보인다.

71) 전매차익형 가상자산까지 투자계약증권의 요건을 충족하여 테라·루나코인이 가상자산에 해당한다는 견해는 전우정, 2023, 가상자산의 증권성에 대한 소고, 법조 제72권 제4호, 381면. 그 주요 근거는 자본시장법 제4조 제6항이 “수익”이 아니라 “손익”으로, “분배”가 아니라 “귀속”으로 정하고 있다는 것인데, “공동사업의 결과”를 “귀속”받는 것이 유통시장의 양도차익을 포섭할 수 있는 개념일지 의문이 있다.

또한 자본시장법상 투자계약증권에서의 “권리”는 사업자에 대한 이익배분청구권에 국한되지 않는다는 이유로 전매차익형 자산도 투자계약증권에 해당한다는 견해는 김갑래, 2024, 미연방법원의 루나 증권성 판결의 시사점, 자본시장포커스(2024-08호) 연구의견, 5면 참조. 다만, “투자계약상 권리”가 이익배분청구권에 국한되지 않는다고 할지라도 여기에 전매차익이 포함될 수 있을지 의문의 여지가 있어 보인다.

“이익획득목적(자본시장법 제3조 1항)”을 긍정하면서도 손익귀속 요건을 명시적으로 판단하지는 아니하였는데⁷²⁾, 위 사례들의 사업구조를 고려할 때 부수적으로 전매차익을 기대할 수 있다고 하더라도 공동사업자로부터의 손익분배가 주된 투자목적인 경우에는 해당 요건을 충족하는 것으로 판단하는 입장으로 보인다. 토큰증권 가이드라인에서도 동 요건과 관련해 “투자자와 발행인 간 계약에 따른 수익 청구권이 인정되어야 한다”고 하며, “디지털자산에 표시된 권리가 없거나, 사업 수익에 대한 투자자의 권리가 없는 경우”, “지급결제 또는 교환매개로 활용하기 위해 안정적인 가치유지를 목적으로 발행되고 상환을 약속하지 않는 경우” 등을 증권에 해당할 가능성이 낮은 경우로 예시하였는데, 구체적인 근거를 제시하지는 않았으나 전매차익형 증권을 배제하는 태도와 유사한 맥락으로 이해된다.

다만, 전매차익형을 배제하는 경우 (i) 전매차익을 포함하는 Howey 기준과의 괴리가 발생하여 자본시장법상 투자계약증권의 범위가 좁아질 우려가 있고, (ii) 전매차익이 전체 투자수익에서 어느 정도의 비중을 차지하여야 증권성을 상실하는지에 대한 기준을 설정하여야 하는지에 대한 난점이 존재하며, (iii) 사업자의 주된 노력으로 공동사업의 가치를 증가시킴에도 수익실현을 주로 전매차익으로만 하도록 설계하여 자본시장법상의 규제를 회피하는 규제차익 유인⁷³⁾이 증가하게 된다. 이러한 점을 고려하면, 입법론상으로는 투자계약증권에 전매차익형을 포함하는 것이 바람직하다고 생각된다. 전매차익형을 포함하더라도, “타인의 노력” 요건 충족을 위해서는 그 전매차익이 공동사업자측의 노력에서 기원하였는지 여부에 따라 증권성을 판단하여야 하기 때문에 투자계약증권의 범위가 적절히 통제될 수 있다고 생각된다.

예컨대, 미국 증권거래위원회(SEC)가 가상자산인 리플의 운영사(Ripple Labs Inc.)(이하 “리플랩스”)에 대하여 제기한 소송(이하 “리플 사안”)⁷⁴⁾의 판결(2023.7.13.)

72) 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.4.20.), 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.11.29.), 8면.

73) 김갑래, 앞의 연구의견(2024), 6면도 유사한 취지이나, 이를 근거로 현행 자본시장법상 해석으로도 전매차익형을 포함하여야 한다고 한다.

74) SEC v. Ripple, Case 1:20-cv-10832-AT-SN-Document 874 (S.D.N.Y. 2021). 사실관계를 간단히 요약하면, 리플랩스는 2013년부터 2020년까지 가상자산인 리플을 기관투자자 및 가상자산 거래소의 일반투자자에게 발행, 유통하였는데, SEC는 그러한 발행이 미국 증권법상의 공모절차를 거치지 않아 위법하다며 뉴욕 남부 연방지방법원에 제소하였고, 이에 대하여 리플은 리플이 증권이 아닌 상품(Commodity)으로 발행, 유통되었는바 미국 증권법을 위반하지 아니하였다고 주장하였다. 한편, 동 판결은 SEC 및 리플랩스 측이 2025.8.7. 동 판결에 대한 항소 및 교차항소를 상호 취하하기로 합의하고, 미국 제2순회항소법원이

에서 뉴욕 남부 연방지방법원은 리플 판매가 투자계약증권에 해당하는지에 대해 Howey 기준을 적용하면서, “투자수익의 합리적 기대”와 “타인의 노력” 요건에 대하여 타인의 기업가적 또는 경영적 노력으로부터 나오는 수익의 합리적 기대(“a reasonable expectation of profits to be derived from the entrepreneurial or managerial efforts of others”)가 있어야 한다고 설시하였다.⁷⁵⁾ 리플의 경우 투자자가 리플 운영사의 수익을 공유받거나 리플의 보유로 인한 이자수익 등을 제공받지 않아 사실상 거래소 내 매도를 통한 시세차익으로만 수익을 실현할 수 있는바 전매차익형으로 분류될 수 있을 것인데, 전매차익의 발생이 사업자의 노력에 기원한 것인지를 근거로 투자계약증권성을 판단함으로써 투자계약증권의 범위의 과도한 확장을 통제하는 한편, 전매차익형임을 이유로 일률적으로 증권법상의 규제를 회피하는 규제차익의 유인을 적절히 차단하고 있는 것이다.⁷⁶⁾

이후 2026.3.17. SEC는 “특정 유형의 가상자산 및 가상자산이 관여된 특정 거래의 증권법상 적용(Application of the Federal Securities Laws to Certain Types of Crypto Assets and Certain Transactions Involving Crypto Assets)”(SEC Release No.33-11412)이라는 제목의 유권해석(이하 “2026.3.17.자 SEC 유권해석”)을 발표하였다.⁷⁷⁾ 위 유권해석에서 리플이라는 가상자산 자체는 디지털 상품으로 분류되어 증권성이 부정되었다.⁷⁸⁾ 그러나 SEC는 증권이 아닌 가상자산이더라도, 발행인이 공동사업에

2025.8.22. 이를 승인하면서 확정되었다.

75) 테라·루나의 운영사인 테라폼랩스가 뉴욕 남부 연방지방법원에 SEC가 제기한 소송의 각하를 요청한 사안(SEC v. Terraform Labs, Pte, Ltd., Case 1:23-cv-1346(JSR) – Document 51 (S.D.N.Y. Jul. 31, 2023)(이하 “테라·루나 사건”)에서도 동 법원은 오직 권유자 또는 제3자의 노력으로부터 나오는 수익의 합리적 기대(“reasonable expectation of profits solely from the efforts of the promotor or a third party”)가 있어야 한다고 설시하였다.

76) 다만, 동 판례에서 유통시장에서의 일반투자자 판매분을 일괄하여 투자계약이 아니라고 판단한 부분에 대해서는 같은 법원 테라·루나 사건 재판부의 비판이 존재하는바, 이에 대해서는 “III.2”에서 검토한다.

77) 동 유권해석에서 SEC는 가상자산(crypto assets)을 (i)디지털 상품(Digital Commodities), (ii)디지털 수집품(Digital Collectibles), (ii)디지털 도구(Digital Tools), (iii)스테이블 코인(Stablecoins)(미국 GENIUS Act에 따라 허가된 발행인이 발행하는 payment stablecoin), (iv)디지털 증권(Digital Securities)(증권법상 증권이 가상자산의 형태로 발행된 것)으로 구분하고, 디지털 증권을 제외한 나머지 가상자산의 증권성(미 증권법상 투자계약 해당 여부)을 부정하였다.

78) SEC가 디지털 상품이 투자계약이 아니라고 판단한 근거는, 디지털 상품의 가치가 본질적으로 수요와 공급의 변동뿐만 아니라 기능적인 암호시스템(특정 암호시스템에 사용되기 위해 생성된 가상자산이 시스템의 프로그램적 효용을 위해 사용되는 암호 시스템)의 프로그램적 운영에서 비롯되는바, “타인의 본질적 경영상 노력에 의한 이익의 기대(the expectation of

대한 투자를 권유하고 투자자가 수익에 대한 합리적인 기대를 할 수 있는 본질적인 경영상 노력(essential managerial efforts)을 약속하면서 그 가상자산을 모집하는 경우에는 (그러한 모집이) 투자계약에 해당할 수 있다고 보았다.⁷⁹⁾ 다만 그러한 가상자산의 모집이 투자계약에 해당하더라도, 그 (증권이 아닌) 가상자산이 유통시장에서 거래되는 경우에 그 전득자가 그와 같은 본질적인 경영상 노력(essential managerial efforts)을 기대할 수 없는 경우에는 유통시장에서의 거래가 투자계약에 해당하지는 않는다고 보았다.⁸⁰⁾ 생 각건대 2026.3.17.자 SEC 유권해석은 리플 사안에서의 뉴욕 남부 지방법원 재판부의 논 리⁸¹⁾와 유사한 취지이나 유통시장에서의 투자계약 성립 가능성을 열어 두고 있는 것으 로 보인다. 이러한 최근 법원 및 SEC 유권해석의 태도는, 투자자의 기대수익의 성격보다 는 타인의 본질적인 경영상 노력에서 유래하는지 여부가 투자계약의 기준으로 확립되고 있음을 시사한다.

한편 투자대상의 가격상승으로 인한 시세차익의 경우, 그러한 시세차익이 공동사업 의 이익으로 편입된다면 “결과에 따른 손익귀속” 요건에 해당하는 것으로 보는 것이 타당 하다고 판단된다. 예컨대 기 발행된 미술품이나 한우 조각투자 사례에서, 시장가격 변동 으로 인한 미술품이나 한우의 가치 상승으로 인한 시세차익은 궁극적으로 공동사업의 손

profits from the essential managerial efforts of others)”라는 투자계약의 요건을 충족하지 않기 때문이다. 즉, 디지털상품 자체는 수동적인 수익(yield)을 창출하거나 기업, 계약자 또는 채무자의 수입, 이윤 또는 자산에 대한 권리를 전달하지 않는다고 보았다. 또한 디지털 상품은 특정 암호 시스템 내에서 거래의 검증, 명령, 확인을 촉진 및 유인하고 그 암호 시스템의 기능 및 보안 등을 유지하기 위하여 생성되었는바 그 암호 시스템에서의 운영과 필수불가결하다. 이러한 측면에서 디지털 상품은 투자계약과 같은 “증권”이 아니라, 그 가치가 상품 자체가 생산하는 채화와 용역에 근거하고 수요와 공급의 변동에 의해 결정되는 “상품”에 가깝다는 것이다. 또한 SEC는 암호 시스템 내에서 사용자의 참여를 감독하고 수익의 분배를 관장하는 중앙화된 존재(central party)가 없다는 점에도 주목하였다(상세한 내용은 2026.3.17.자 SEC 유권해석 14-16면 참조).

79) SEC, 2026, Application of the Federal Securities Laws to Certain Types of Crypto Assets and Certain Transactions Involving Crypto Assets(Release Nos. 33-11412; 34-105020; File No. S7-2026-09), (3.17.), 24-25면.

80) SEC, 앞의 유권해석(2026.3.17.), 28면. 부연하면, 전득자가 본질적인 경영상 노력에 대한 약속을 계속 기대할 수 있는 경우에는 유통시장의 가상자산 매매도 투자계약에 해당할 수 있다. 그러나 그러한 “기대의 승계”도 영구적으로 이루어지는 것은 아니며, (1) 발행인이 본질적인 경영상 노력에 대한 약속을 이행하거나(예컨대 ICO(initial coin offering)에서 발행인이 투자자의 금전투자의 대가로 발행 시 코인지급을 약속하였고 그 이행이 완료된 경우), (2) 발행인이 그러한 약속을 이행할 것을 합리적으로 기대할 수 없는 경우에는 투자계약의 성질을 상실하게 된다(다만, 그 발행인은 증권법상 사기방지(anti-fraud) 규정이 적용될 수 있다)(SEC, 앞의 유권해석(2026.3.17.), 29-34면).

81) 세부적 적용 및 결론을 달리하나, 테라·루나 사건에서의 재판부의 논리도 핵심적인 측면(투자자가 발행인 등의 경영상 노력에 대한 합리적 기대가 있어야 한다는 점)은 동일하다.

익에 귀속되고, 투자자는 발행인에게 그 손익을 청구할 권리를 투자계약상 보유하는 것 인바, 해당 요건을 충족하고 있는 것으로 봄이 타당할 것이다. 토큰증권 가이드라인은 이 쟁점을 명시적으로 다루고 있지는 아니하나, “발행인 등이 투자자의 금전등으로 사업을 수행하여, 그 수행한 사업의 성과에 따른 수익을 귀속시키기로 약정한 경우”를 해당한다고 설명하고 있는바, “사업 성과에 따른 수익”에 있어 “가격상승으로 인한 시세차익”을 배제하지는 않는 것으로 보인다.

(나) 계약상의 권리

그리고 후자(“계약상의 권리” 부분)와 관련하여, 계약상의 권리는 그 권리를 주장할 수 있는 상대방의 존재를 전제하는데, 그 상대방이 발행인에 국한하는지 아니면 제3자까지 포함하는지에 대하여 견해가 대립한다.⁸²⁾ 이에 대하여 토큰증권 가이드라인은 발행인이 투자자에게 사업 수익을 직접 분배할 것을 명시적·묵시적으로 약속하거나, 발행인이 제3자와의 계약 등을 바탕으로 해당 제3자가 투자자에게 사업 수익을 분배할 것을 약속하는 등 투자자와 발행인 간 계약에 따른 수익 청구권이 인정되어야 한다는 입장을 취하고 있다. 토큰증권 가이드라인의 입장은 일종의 절충적 태도로 이해되고, 문언의 의미와 투자자보호 필요성 사이의 균형을 유지하는 해석으로서 합리적이라고 판단된다. 다만 입법론상으로는 전매차익형을 투자계약증권에 포섭하는 경우 계약상의 권리의 상대방이 반드시 사업자에 국한될 필요는 없으므로, 상대방을 명시하지 않는 것이 타당하며 Howey 기준에서의 “계약, 거래, 계획”과 같은 포괄적인 표현을 사용하는 것도 고려해볼 수 있다고 판단된다.

(5) 자본시장법상 타 종류 증권 및 집합투자와의 관계

앞서 본 바와 같이 투자계약증권은 타인의 노력에 의하여 수익이 결정되는 모든 증권을 자본시장법상 “증권”으로 포섭하기 위하여 도입된 개념이므로, 특정 사업구조가 자본시장법상 투자계약증권이 아닌 다른 증권유형에 해당하는 경우도 있을 것이다. 이 경우 투자계약증권은 자본시장법에 구체적으로 열거되지 않은 투자대상을 포괄하기 위한

82) 그 상대방이 제3자까지 포함한다는 견해로는 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 64면. 상대방이 발행인에 국한된다는 견해로는 이정수, 앞의 논문(2023), 145면.

보충적 도구개념이므로 다른 증권유형에 해당하는 것을 투자계약증권으로 파악하지 않는다는 것이 통설적 견해로 보인다(이른바 투자계약증권의 보충성).⁸³⁾ 금융위원회 유권 해석 역시, 자본시장법상 투자계약증권이 적용되는 것은 주로 집합투자적 성격을 가진 계약 가운데 자본시장법에 규정된 집합투자기구를 이용하지 않는 투자구조라고 밝힌 바 있으며, 특히 “지분증권, 채무증권, 집합투자증권 등 정형적인 증권에 해당되지 않는 비정형증권일 것”을 투자계약증권의 판별기준 중 하나로 제시하였는바 같은 입장에 있는 것으로 판단된다.⁸⁴⁾ 또한 한국ST거래의 혁신금융서비스 지정문의 부가조건에서도 증권신고서 제출을 통해 모집된 투자계약증권이 보충성 요건을 충족하도록 하고 있는 등⁸⁵⁾ 이러한 태도가 유지되고 있는 것으로 보인다.

투자계약증권과 타 유형 증권의 중복문제가 가장 두드러지는 경우는 집합투자이다. 자본시장법은 영국의 집합투자개념을 도입하면서 미국 증권법상 투자계약을 함께 도입하였기 때문에, 자본시장법상 투자계약증권을 미국의 투자계약과 동일하게 볼 수는 없다.⁸⁶⁾ 부연하면, 영국의 집합투자는 다수 투자자로부터의 자금 집합(Pooling)을 통해 재산에 투자하는 모든 구조를 포괄하는 개념으로서, 투자계약의 개념이 별도로 존재하지 아니하는 대신 집합투자의 정의에 Howey 기준의 요건을 반영한 것으로 평가된다.⁸⁷⁾ 이와 달리 미국의 1940년 투자회사법은 투자회사의 운용대상을 증권으로 한정⁸⁸⁾하고, 집합투자 성격의 사업형태 중 투자회사에 해당하지 않는 것을 투자계약으로 광범위하게 규정하였다. 우리나라의 경우 투자계약증권과 집합투자를 동시에 도입하였으므로, 투자계약증권의 보충성 원칙을 적용하면 미국보다 투자계약증권이 적용될 공간이 좁아지게 되는바, 결과적으로 앞서 언급한 금융위원회 법규유권해석(일련번호 140015)과 같이 집합투자적 성격을 가진 계약 중 자본시장법상 집합투자기구를 이용하지 않는 투자구조가 주

83) 자본시장통합연구회(편), 2007, 자본시장통합법해설서, 한국증권업협회, 21면, 42면, 49면. 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 65면, 김종원, “투자계약증권의 판단기준에 대한 비교법적 고찰”, 기업법연구 제37권 제4호(2023), 497면.

84) 금융위원회, “투자계약증권의 성격에 대한 질의”, 금융위원회 법규유권해석(일련번호 140015).

85) 금융위원회, “한국ST거래(주)의 혁신금융서비스 지정”, 금융위원회 공고 제2025-300호, 2면.

86) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 66면.

87) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 65-66면. 영국의 집합투자개념은 “2인 이상의 투자자로부터 집합한 자산을 투자자로부터의 일상적인 운용지시를 받지 않으면서 운용하여 그 실적을 배당하는 모든 구조”로 정의된다.

88) 미국 1940년 투자회사법(Investment Company Act of 1940)(Section 3)상 투자회사는 “증권투자나 거래를 주된 업무로 하면서 40% 이상의 자산을 증권에 투자하고, 공모 등의 요건을 충족하는 발행인”을 의미한다.

로 투자계약증권이 적용되는 영역이 된다고 보는 것이 일반적인 견해이다.⁸⁹⁾ 그런데 집합투자기구를 이용하지 않는 투자구조라고 하더라도 자본시장법상 집합투자의 개념(자본시장법 제6조 제5항)에 해당할 위험성이 완전히 배제되지는 않으므로⁹⁰⁾, 투자계약증권의 공동사업 구조 설계 시 자본시장법상 집합투자의 요건에 해당하지 않도록 유의할 필요가 있다.⁹¹⁾

(6) 소결

자본시장법상 투자계약증권의 요건 중 공동사업은 수평적 공동성 또는 수직적 공동성이 구비되면 이를 충족한다고 보는 것이 타당하다. 또한 자본시장법상 다른 증권과의 관계를 고려할 때 공동사업의 구조는 사업자와 투자자간 채권적 형태의 투자계약이 일반적일 것으로 생각된다. 주로 타인 수행 요건과 관련하여 토큰증권 가이드라인에서는 발행인의 노력이 부정할 수 없을 정도로 중대하고 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상의 노력이어야 한다고 하나, 그 범위를 발행인으로 국한한 것에는 의문의 여지가 있다. 손익 귀속 요건과 관련해서는, 법률의 문언상 전매차익형 공동사업이 배제된다고 해석되고 금융당국의 태도도 유사한 것으로 보인다.

그러나 전매차익형을 배제하는 경우 Howey 기준과의 괴리, 전매차익적 요소의 비중에 대한 모호성, 자본시장법 규제 회피 유인 발생 가능성 등을 고려하면 입법론상으로는 전매차익형을 포함하는 것이 타당하고, 미국의 리플, 테라·루나 사건 판례와 같이 “타인의 노력” 요건과의 유기적 해석을 할 필요도 있을 것으로 보인다.⁹²⁾ 한편, 투자계약증권은

89) 김건식·정순섭, 앞의 책(2023), 66면, 임재연, 2021, 자본시장법, 박영사, 69면. 이한준, 2023, 바람직한 조각투자 규제체계에 관한 고찰, 증권법연구 제24권 제3호, 147면 참조.

90) 같은 견해로 이한준, 앞의 논문(2023), 146-150면 참조. 이에 따르면, 투자계약증권의 요건인 “주로 타인이 수행한 공동사업”이 충족되면서 (집합투자의 요건에 해당하지 않기 위한) “일상적 운용지시” 또한 인정되는 경우를 상정하기는 어렵다고 한다.

91) 집합투자가 아님을 확인하기 위한 증권신고서상 수단 및 개선점에 대해서는 “IV.2” 참조.

92) 우리나라는 가상자산에 대하여 이용자 보호 규제(가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률)가 존재하고 나아가 가상자산 2단계 입법(이른바 디지털 자산 기본법)이 추진 중이어서, 투자계약증권의 외연에 전매차익형을 추가하는 것이 증권과 가상자산과의 경계를 모호하게 하고 법률상 불확실성을 증가시킬 수 있다는 관점도 존재할 수 있다. 그러나 가상자산 자체가 법제상 증권과 구분된다고 하더라도 가상자산이 영업의 대상이 되는 공동사업으로서 투자계약증권에 해당하는 경우가 존재할 수 있고, 이 경우에 투자자가 기대하는 주된 수익은 전매차익일 가능성을 배제할 수 없는바, 전매차익형을 투자계약증권에 편입하는 실익이 없다고 보기는 어렵다. 오히려 이 경우를 투자계약증권에서 배제하는 경우, 가상자산규제와 증권규제 사이의 사각지대가 발생할 가능성도 존재한다.

집합투자와의 중복가능성이 주로 문제되는데, 미국과 달리 우리나라는 투자계약증권과 집합투자 개념을 모두 도입하였기 때문에 독자적인 투자계약증권의 영역이 축소되어 있으며, 이에 따라 집합투자로 분류되지 않기 위해서는 집합투자기구를 사용하지 않더라도 자본시장법상 집합투자 개념에 해당하지 않도록 유의할 필요가 있다.

III. 증권성 판단 사례 및 실무상 쟁점 검토

1. 금융당국의 증권성 판단사례 검토

(1) 뮤직카우 “청구권”의 투자계약증권 판단 사례

앞서 언급한 바와 같이, 금융당국이 최초로 투자계약증권에 해당한다고 판단한 사례는 (주)뮤직카우의 저작권료참여청구권 발행사례이다.⁹³⁾ 동 사례에서 증선위는 “공동사업”, “주로 타인이 수행”, “이익획득 목적(자본시장법 제3조 제1항)”의 요건을 충족하여 투자계약증권의 요건에 해당한다고 보았고, “결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리” 요건은 검토하지 않았다. 우선 첫 번째 요건과 관련하여 증선위는 동일한 “청구권” 보유 투자자가 저작권료 수입과 청구권 가격변동 수익을 동일하게 향유하여 요건을 충족한다고 보았는데, 이는 앞서 검토한 수평적 공동성 요건의 충족과 같은 맥락의 판단으로 이해된다. 두 번째 요건과 관련하여 증선위는 공동사업의 일체 업무를 뮤직카우 및 에셋이 전적으로 수행하여⁹⁴⁾ “주로 타인이 수행” 요건을 충족한다고 보았다. 이는 “타인”의 범

또한, 전매차익형 공동사업은 가상자산이 아닌 다른 사업을 소재로도 발생할 수 있으므로, 가상자산 규제 맥락이 아니더라도 전매차익형을 투자계약증권에 편입하여 규율할 필요성이 존재한다.

93) 해당 사례의 사업구조를 간략히 설명하면, (주)뮤직카우(이하 “뮤직카우”)의 자회사인 (주)뮤직카우에셋(이하 “에셋”)은 음악 저작권의 원보유자로부터 그 저작권을 신탁조건부로 매수하고, 에셋은 동 저작권을 저작권협회에 신탁한다. 에셋은 그 신탁된 저작권으로부터 발생하는 저작권료의 지급을 동사에 청구할 수 있는 “저작권료참여권”을 뮤직카우에 발행하고, 뮤직카우는 그 저작권료참여권에 터잡아 수령하는 저작권료 상당 금액의 지급을 청구할 수 있는 “청구권”(이하 “청구권”으로 표기)을 투자자에게 경매 방식으로 발행한다(금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.4.20.), 7면 참조)

94) 그 근거로 “청구권” 및 그 유통시장의 창설이 뮤직카우(에셋)에 의해 이루어져 뮤직카우(에

위를 발행인에 국한하지 않고 발행인과 계약관계 또는 지분관계가 있는 제3자로 확장하여 고려한 것으로 이해된다. Howey 기준에서도 (투자자가 아닌) “제3자의 노력”이 필수적인 경영상의 노력인지를 판단할 뿐 제3자의 요건을 엄격히 제한하고 있지는 않다는 점에서, 이러한 방향은 타당하다고 생각된다. 그리고 세 번째 요건과 관련하여 증선위는 투자자들이 사용목적이 아니라 저작권료 수입 또는 매매차익을 목적으로 “청구권”을 매수하였다고 보았는데, 이는 “이익획득 목적”에서의 “이익”에 매매차익을 포함하는 것을 전제한 것으로 보인다.

이에 대해서는, 뮤직카우의 “청구권” 구조는 투자계약증권으로 보기 어렵다는 견해도 존재한다.⁹⁵⁾ 우선 “이익을 얻을 목적” 요건과 관련하여 유통시장의 매매차익은 사업에서 창출되는 이익이 아닌 점, 저작권료 수입은 자산 소유로부터 직접 발생하므로 일반적인 증권에서의 투자이익과 다른 점을 들어 충족되기 어렵다고 본다. 그리고 “주로 타인이 수행” 요건 및 “손익의 귀속”과 관련해서는 뮤직카우 투자자의 수익은 신탁된 저작권에서 발생하는 반면 사업자의 수익은 경매수익이나 유통시장 수수료에서 발생하므로 충족되기 어렵다고 본다. 마지막으로 “공동사업”과 관련해서는 수평적, 수직적 공동성은 일응 충족될 수 있으나 뮤직카우의 사업이 투자자의 손익과 관련이 없으므로 사업성이 인정되기 어렵다고 한다.

그러나 자본시장법상 “이익을 얻을 목적”에서 유통시장의 매매차익(전매차익)이 명시적으로 배제된다고 보기는 어려우며⁹⁶⁾, 만약 그렇다고 하더라도 또 다른 수익원인 저작권료 수입이 “이익”에 해당할 가능성은 충분히 보인다. 또한 주식의 배당이나 채권의 표면이자 역시 자산의 보유로부터 나오는 수입인바, 저작권료 수입이 그러한 투자이익과 본질적으로 다르다고 보기도 어렵다고 사료된다. “주로 타인이 수행” 요건 및 “손익의 귀속” 요건, “공동사업”요건과 관련하여서도, 앞서 살펴본 바와 같이 사업자와 투자자의 손익구조가 동일한지 여부는 해당 요건의 성립과 직접적인 관련이 없으므로, 손익구조의 차이점만을 근거로 요건해당성을 부정하기는 어려운 점이 있다고 생각된다.⁹⁷⁾ 따라서 증

셋)의 사업이 없이는 투자수익 획득이 불가하며, 투자자가 뮤직카우를 통하지 않고 저작권료 수령이 불가하다는 점을 지적하였다.

95) 성희활, 2022, 조각투자의 증권성에 대한 연구, 경제법연구 제21권 3호, 44-46면.

96) 자본시장법 제정 당시 재정경제부도 가치변동이 있는 실물자산을 소비 목적으로 매입하는 경우 등은 이익획득/손실회피 목적(자본시장법 제3조 제1항)에 해당하지 않는다고 언급할 뿐, 전매차익을 이익에서 명시적으로 제외하지는 않았다(재정부 자본시장법 설명자료, 8면).

97) Howey 사례에서도 사업자(Howey-in-the-Hills Service Inc.)는 고객들과 용역계약을 체결하면서 노임과 재료비 외에 고정비용을 받고, 고객들은 전체 토지에서 수확한 과실을 판

선위의 증권성 인정 결정은 합리성이 있다고 판단되나, “결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리” 요건을 별도로 검토하지 않은 측면은 보완의 여지가 있어 보인다.⁹⁸⁾

(2) 한우, 미술품 조각투자의 증권성 판단 사례

앞서 본 바와 같이, 2022.11. 증선위는 한우 및 미술품 조각투자에 대해서도 투자계약증권성이 인정된다는 결정을 한 바 있다.⁹⁹⁾ 동 사안에서 증선위는 “공동사업”, “주로 타인 수행”, “이익획득 목적” 요건을 중심으로 투자계약증권 해당여부를 검토하였다. “공동사업” 요건과 관련하여 주목할 점은 뮤직카우 사례와 달리 수직적 공동성을 함께 검토하였다는 것이다.¹⁰⁰⁾ 이에 따르면, 기초자산(미술품 또는 한우)의 매각에 따른 투자자 수익이 증가해야 회사의 수수료 수입도 증가하게 되므로, 회사의 성패가 투자자들의 손익과 연계된다고 하여 수직적 공동성이 인정된다고 판단하고 있다. 한편, “주로 타인 수행” 요건과 관련하여서는 회사가 전문성을 활용해 보관·관리, 운용·매각 및 손익배분 등의 업무를 전적으로 수행하였고, 그러한 전문성이 기초자산의 가치를 상승시키며, 투자자 모집 시 그러한 전문성이 핵심적인 홍보사항으로 제시되었다고 보았다.

한편 금융당국이 명시적으로 밝히지는 않았으나, 뮤직카우 건에서와 마찬가지로 금융당국은 회사의 전문성과 노력을 판단함에 있어서 회사와 계약관계에 있는 자(예컨대, 한우 조각투자에서 한우의 보관 및 사육을 담당하는 농가회원, 미술품 조각투자에서 협력관계에 있는 국내외 갤러리) 또는 회사와 지분관계가 있는 자(예컨대, 미술품 조각투자 중 테사 사례에서 미술품 매입·관리·매각 업무를 수행하는 테사에셋, 서울옥션블루 및 투게더아트 사례에서 계열관계에 있는 서울옥션, 케이옥션 등)가 수행하는 업무를 함께

매한 후 실현된 순수익을 토지 소유면적에 비례하여 분배받았다(심인숙, 앞의 논문(2006), 319면, 임재연, 2009, 미국증권법, 박영사, 72면). 더욱이, 공동사업의 성과가 향상되는 경우 뮤직카우로서도 경매수수료 및 유통수수료 수익 증가를 동시에 기대할 수 있으므로, 회사의 성패와 투자자의 손익이 완전히 절연되어 있다고 보기도 어렵다.

98) 다만 앞선 논의에 비추어볼 때, 전매차익 이외에 “청구권” 보유 시 저작권료에서 나오는 수입이 발생하고 그러한 수입을 수취할 권리가 뮤직카우와 투자자 간 계약에 의하여 정해지므로 해당 요건을 충족하였을 것으로 판단된다.

99) 금융위원회, 앞의 보도자료(2022.11.29.), 8-9면. 증권선물위원회, 2022, “한우 및 미술품 관련 5개 조각투자 서비스의 증권성 여부 및 ㈜스타키피 등 4개사에 대한 조치안”, 의결 제 218호, (11.29.)(이하 “한우 및 미술품 증선위 조치안”) 참조. 위 조각투자의 상세한 구조에 대해서는 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.11.29.), 8-9면 참조.

100) 증선위는 투자자가 동일 한우 또는 미술품의 매각결과에 따른 손익을 동일하게 향유하므로 수평적 공동성을 충족한다고 보았고 이에 대해서는 특별한 의문의 여지는 없어 보인다.

고려한 것으로 보인다. 마지막으로 “이익획득의 목적” 요건에서는 기초자산을 사용·수익하기 위한 목적이 아닌 투자목적으로 조각투자 지분을 매수하였다고 하여 이익획득 목적을 긍정하였다고 하면서도, 그 투자목적이 기초자산 매매차익의 취득목적인지 전매차익 실현목적인지를 구분하지는 아니하였다.

위 사례와 관련하여, 미술품 조각투자가 투자계약증권에 해당하기 어렵다는 견해가 존재한다.¹⁰¹⁾ 이에 따르면, 통상의 미술품 매매가 소비활동에 해당하여 자본시장법상 금융투자상품이 아닌 것으로 보는 것이 일반적이어서 미술품 조각투자도 소비활동이 아니라고 단정하기 어려우므로 이익획득 목적을 인정하기 어렵다고 한다. “주로 타인이 수행” 요건의 경우, 투자의 성패가 미술품 자체의 시장가치 상승에 있기에 회사의 역할은 부수적인 수준에 그치는바 회사의 노력이 투자의 성패를 가를 만큼 중대한 것이라고 보기 어렵다고 한다. 그리고 이로 인하여, 사업으로부터의 손익이 직접 투자자에게 귀속된다고 보기도 어렵다고 한다.

그러나 회사에 대한 사전 관람신청을 통한 미술품 관람¹⁰²⁾ 등 일부 소비로 해석될 수 있는 권리를 감안하더라도, 주된 목적이 공동사업의 손익배분 또는 전매차익이라면 이익기대 목적이 있는 것으로 보는 것이 타당하다고 생각된다. Howey 기준에서의 “이익기대” 요건에서도 투자자가 금전 등을 제공한 목적이 여러 가지라면, 당해 거래의 경제적 실질에 비추어 보아 주된 목적이 무엇인지를 교량하여 판단한다.¹⁰³⁾ 미술품 조각투자의 주된 목적은 투자수익(공동사업의 손익배분 또는 전매차익)의 향유이고 기초자산의 관람은 보관·관리차원의 부수적 권리행사에 불과하므로, 이익획득목적 요건은 충족된다고 보는 것이 타당해 보인다. 그리고 “주로 타인이 수행”과 “손익귀속” 요건과 관련해서도, 미술품의 가격 자체는 회사의 노력 없이도 시장상황에 영향을 받는 측면이 있더라도, 사업의 성과는 미술품의 종류, 투자자 유치(자금동원력), 매수시점 및 매입가격, 매도시점 및 매도가격 등에 영향을 받으므로 매입대상 미술품의 선정, 기초자산 매각, 조각투자 생태계 조성 등은 사업의 성패를 좌우하는 영역인바 이에 대한 회사의 전문성과 노력은 필수적인 경영상의 노력에 해당한다고 보는 것이 타당해 보인다.

101) 성희환, 앞의 논문(2022), 51면.

102) 현재 발행된 미술품 투자계약증권의 경우, 일반적으로 청약기간 중 작품을 공개 전시하고, 발행 이후에는 투자자가 미리 요청하는 경우 작품을 관람할 수 있도록 하고 있다.

103) 심인숙, 앞의 논문(2008), 61면.

(3) 소결

증선위의 증권성 판단사례는 대체로 투자계약증권의 요건에 대한 일반적인 논의에 부합하나, “손익귀속” 요건을 별도로 검토하지 않은 한계점이 있다. 뮤직카우 사례에서는 투자계약증권성을 충족하지 않는다는 의견도 있으나, (1) 자본시장법상 “이익을 얻을 목적”에 전매차익이나 자산의 보유로부터 나오는 수익이 배제되기 어려운 점, (2) 사업자와 투자자의 손익구조의 차이만으로 투자계약증권성을 부정하기는 어려운 점을 고려하면 투자계약증권에 해당한다고 보는 것이 타당하다. 미술품·한우 사례에서 증선위는 회사의 전문성과 노력 판단 시 회사와 지분관계 또는 계약관계가 있는 자의 전문성과 노력을 함께 판단하여 묵시적으로 “타인의 노력”에서의 “타인”의 범위를 확장하고 있는데, 이러한 방향은 타당하다고 생각된다. 미술품 조각투자에 대해서는 투자계약증권에 해당하기 어렵다는 견해도 있으나, (1) 미술품 조각투자의 주된 목적은 투자수익의 향유인 점, (2) 공동사업의 성과 창출을 위해서는 매입대상의 선정, 기초자산 매각 결정, 조각투자 생태계 조성 등에 대한 사업자의 전문성과 노력이 필요한 점 등을 고려하면 투자계약증권에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

2. 판결 및 수사사례상 증권성 판단사례 검토

(1) 법원 판결

현재 투자계약증권의 증권성 판단과 관련한 법원의 판결은 가상자산의 증권성 판단 관련 사안이 대부분¹⁰⁴⁾이며, 대법원의 판단이 이루어진 판결은 찾기 어려운 것으로 보인다. 그 중 서울남부지방법원 2020.3.25. 선고 2019가단225099 판결(이하 “서울남부지방법원 2019가단225099 판결”)은 가상자산의 증권성 판단에 대한 최초의 판결로 평가되며¹⁰⁵⁾, 이후 유사한 하급심 사안에서 같은 취지의 판시가 이어지고 있다.¹⁰⁶⁾ 해당 판결

104) 부동산 투자계약이 투자계약증권에 해당하여 유사수신행위를 인정한 하급심 판례도 존재하나(의정부지방법원 고양지원 2025.4.17. 선고 2022가합73737), 동 판례에서 법원은 투자계약증권에 해당한다고 판단한 근거를 제시하지 않고 있다(관련 형사판결(의정부지방법원 2022.7.20. 선고 2020고단3840 판결이며 이는 같은 법원 2023.12.21. 선고 2022노2182 판결로 확정되었다)에서 법원이 피고의 사업을 투자계약증권으로 판단하였다고 하나, 해당 판결에서 자본시장법상 투자계약증권 해당여부에 대한 구체적 논증을 찾기는 어렵다).

105) 이정수, 앞의 논문(2023), 137면. 해당 사안에서 피고 회사는 자신이 운영하는 거래소 내

에서 법원은 ① 피고 회사가 발행한 가상자산(토큰)을 보유함으로써 피고 회사가 운영하는 거래소의 수익을 분배받기는 하지만, 그러한 수익분배는 가상자산의 거래를 활성화하기 위하여 토큰 보유자에게 부수적으로 제공하는 이익일 뿐 토큰에 내재된 구체적인 계약상 권리라거나 본질적 기능이라고 볼 수 없고, ② 토큰거래 자체로 발생하는 시세차익의 취득이 토큰 매수의 가장 큰 동기이고 이에 관하여 투자자 사이에 이해관계가 상충한다고 하여 위 토큰을 투자계약증권으로 볼 수 없다고 보았다.

본 판결은 법원이 전매차익형 공동사업이 투자계약증권에 해당하지 않는다고 판단한 사안으로서,¹⁰⁷⁾ 미국의 투자계약과 다른 자본시장법상 투자계약증권 개념의 독자성을 보여주는 의미가 있다고 평가할 수 있다. 그러나 법원은 거래소의 수익분배 부분이 부수적인 기능이라고 본 근거를 제시하지 않았고, 나아가 거래소 수익분배 부분만을 분리하여 투자계약증권으로 볼 여지가 있는지도 판시하지 않았다. 또한 수익분배와 전매차익이 혼합된 경우에 어느 정도의 수익분배 기능이 포함되어야 투자계약증권의 요건을 충족하는지에 대한 기준도 제시하지 않은 한계가 있다고 보인다.

한편 판례에서 언급된 투자자 사이의 이해관계의 상충은 “수평적 공동성” 요건이 충족되지 않는다는 취지로 보인다.¹⁰⁸⁾ 그러나 전매차익형 공동사업의 증권성은 Howey 기준에서는 “이익기대” 요건과 자본시장법에서는 “손익귀속” 요건과 각 관련이 있는 것일 뿐, “수평적 공동성” 요건과 관련이 있다고 보기는 어렵다. 또한 사안에서 사업자의 노력(토큰 발행 관련 구조설계, 홍보, 광고, 거래소 영업 등)이 투자자의 성공과 불가분적으로 연결되어 있다는 점에서 수직적 공동성이 인정될 가능성이 크다는 점에서 “공동사업” 요건을 부정하는 논거가 되기도 어려워 보인다.

에서 사용할 수 있는 가상자산(자체 토큰)을 만들어 투자자들을 모집하였는데, 동 가상자산의 보유자에게 거래소의 수익 중 일정액을 지급하거나 거래행위에 사용한 수수료에 따라 토큰을 지급하는 방법으로 이익을 취득할 수 있다고 홍보하였고, 투자자들(원고들)은 회사에 이더리움을 지급하고 그에 상응하는 위 가상자산을 지급받았다. 그러나 원고들은 위 가상자산의 가격이 하락하여 손해를 입자, 위 가상자산이 투자계약증권임에도 자본시장법이 정한 공모절차에 따라 발행되지 아니하여 손해를 입었다고 주장하며 소를 제기하였다.

106) 의정부지방법원고양지원 2021.9.10. 선고 2019가단78506(의정부지방법원 2021나219018 호로 확정) 판결이 있으며, 동 사안도 피고(가상화폐 거래소)가 거래소 수익을 분배받는 기능을 가진 자체발행 코인을 투자자들에게 발행한 사안이었다.

107) 이정수, 앞의 논문, 152면.

108) 같은 취지로 이정수, 앞의 논문, 162면.

(2) 검찰 수사사례 : 루나 코인 사건

법원의 판단이 이루어진 사안은 아니나, 검찰은 이른바 “루나 코인” 사건에서 테라폼랩스의 ‘스테이블 코인(루나) 블록체인’ 사업인 테라프로젝트가 투자계약증권에 해당한다고 판단하여 테라폼랩스 관련자들을 자본시장법상 사기적 부정거래, 배임수재 등의 혐의로 기소하였다. 검찰은 동 사안에 대한 수사결과를 밝히면서¹⁰⁹⁾, 루나 코인이 자본시장법상 투자계약증권에 해당한다고 하여 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의를 적용하였다. 이에 따르면, 루나 소유자는 테라 플랫폼 이용 수수료 및 테라 코인¹¹⁰⁾을 발행한 주조차익(시노리지)을 사업성으로 추구하고, 그러한 사업손익이 루나 코인의 가치에 반영되고 테라폼랩스 역시 이러한 점을 홍보하며 투자자들을 모집(ICO, Initial Coin Offering)하였다고 한다. 구체적으로 검찰은 타인을 테라폼랩스로, 공동사업을 테라 블록체인 플랫폼 사업으로, 결과에 따른 손익을 수수료 및 주조차익으로, 계약상 권리가 표시된 것을 루나 코인으로 보았다.¹¹¹⁾ 한편, 테라·루나 코인의 증권성에 대해서 뉴욕 남부연방지방법원은 2023.7.31. (i) 테라폼랩스가 루나 판매 수익을 테라폼 블록체인 개발에 사용하였으며 그러한 개발이 루나의 가치를 상승시키므로 수평적 공통성을 인정하였고, (ii) 테라폼랩스가 루나의 계속된 판매로 발생하는 수익이 테라폼 생태계의 추가 개발로 재투자될 것이라고 강조하였는바 투자수익의 합리적 기대 및 타인의 노력 요건도 충족한다고 판단하여 투자계약에 해당한다고 보았다.¹¹²⁾¹¹³⁾

109) 서울남부지방법검찰청, 2023, ‘테라 프로젝트’ 금융사기 사건 수사결과, 보도자료(4.25.) 참조. 현재 테라폼랩스 관련자의 자본시장법 위반 등의 혐의에 대한 국내 재판은 1심 진행 중이며, 증권사기 등 혐의에 대한 미국에서의 형사재판은 2025.12.11. 뉴욕 남부연방지방법원의 1심 판결이 선고되었다.

110) 테라 코인은 가격고정(pegging)이 이루어지는 스테이블코인을 표방하여 발행된 코인이었고, 루나 코인은 이러한 테라 코인 프로젝트를 수행하기 위한 자금을 조달하기 위해 발행된 가상자산이다(서울남부지방법검찰청, 앞의 보도자료(2023), 1면, 12면).

111) 서울남부지방법검찰청, 앞의 보도자료(2023), 14면. 다만, 검찰은 루나코인에 그러한 권리가 화체되었다고 언급할 뿐, “계약상 권리”의 원천이 무엇인지에 대하여 언급하지는 않았으나 이는 루나코인의 백서(white paper)일 것으로 보인다. 같은 취지에서 루나 코인의 백서가 일종의 약관에 해당하여 계약상 권리에 해당한다는 견해로는 전우정, 앞의 논문(2023), 382면 참조.

112) SEC v. Terraform Labs, Pte, Ltd., Case 1:23-cv-1346(JSR) - Document 51 (S.D.N.Y. Jul. 31, 2023). 동 판결은 테라코인에 대해서도 유사한 논리로 증권성을 인정하였으며, 주요 내용은 전우정, 앞의 논문(2023), 381면 참조. 한편, 루나코인이 투자계약증권에 해당하지 않는다는 견해는 이중기, 2023, 지급결제수단인 스테이블코인의 증권성 여부 - 루나, 테라를 중심으로, 홍익법학 제24권 제1호 참조.

113) 또한 뉴욕 남부지방법원은 2025.12.11. 테라폼랩스의 창립자에 대하여 증권사기 등의 혐의로 15년형을 선고하였다(United States v. Kwon, 1:23-cr-00151, (S.D.N.Y.)).

앞선 서울남부지방법원 2019가단225099 판결의 태도, 수평적 공동성 및 타인의 노력 요건에 대한 미국 법원의 판단을 고려하면, 루나 코인에서 주로 문제되는 투자계약증권의 요건은 “결과에 따른 손익을 귀속받을 계약상 권리”라고 생각된다.¹¹⁴⁾ 루나코인 보유자는 루나코인을 가상자산 거래소에서 거래하여 전매차익을 취할 수도 있고, 이를 그대로 보유하여 테라 블록체인 이용 수수료를 지급받거나 주조차익을 통한 루나의 가치 상승 효과를 향유할 수도 있었다.¹¹⁵⁾ 서울남부지방법원 2019가단225099 판결에서는 거래소의 수수료 수익 등을 가상자산 투자의 부수적인 목적으로 보고 주된 목적을 전매차익이라고 보았는데, 루나코인 역시 같은 맥락에서 이해해야 하는 것인가? 생각건대 루나 코인의 경우 스테이블 코인을 표방한 테라 코인의 가치고정을 위한 가상자산으로서 발행되었는바 테라의 사용으로 인한 수수료 수익 또는 테라 코인의 주조차익¹¹⁶⁾은 거래활성화를 위해 제공된 부수적 기능이라기보다 루나 코인에 “내재된 계약상 권리가거나 본질적

114) 보유자가 시노리지를 받기 위해서 응용프로그램 등록 및 검증자 투표가 필요하여 “주로 타인 수행” 요건이 문제된다는 견해도 가능하나, 일부 이용자의 참여가 필요하다라도 “테라 프로젝트” 전체의 관점에서 테라폼랩스의 노력이 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 노력에 해당한다는 점을 부정하기는 어려워 보인다. “이익을 얻을 목적”과 관련해서도, 루나 코인의 주 목적은 수수료, 주조차익 및 전매차익의 취득이므로, 가격고정을 표방하였다고 하여 이익을 얻을 목적이 없었다고 보기는 어렵다고 생각된다(조선비즈, 2023, 테라·루나, 증권아니라는 권도형...검찰이 넘어야 할 두 가지 벽, (4.28.) 참조). 참고로 2026.3.17.자 SEC 유권해석에서는 Protocol Mining (단독 채굴, Mining Pool 활동 포함), Protocol Staking (이와 관련한 예치, Liquid Staking, Staking Receipt Token 발급 등 부수활동 포함)과 같은 가상자산 시스템 내에서의 거래 검증 등에 참여하고 그로부터 보상을 얻는 활동이 원칙적으로 투자계약에 해당하지 않는다고 보았으며, 주된 논거는 해당 활동들은 “타인의 본질적 경영상 노력에서 유래된 이익의 기대”에서 수행한 것이 아니라, 가상자산 네트워크 내에서의 운영상 또는 관리상(administrative or ministerial) 행위에 불과하다는 것이다(SEC, 앞의 보도자료(2026.3.17.), 34-54면) 그러나 루나코인에서의 시노리지는 앵커 프로토콜을 통해서도 지급되었는데, 테라폼랩스는 이례적인 수준의 20%의 확정 수익률을 보장하였고, 앵커 프로토콜 운영 과정에서 스테이킹의 대상이 된 루나코인을 담보로 (스테이킹된 루나코인을 표상하는 b토큰 발급을 통하여) 테라코인(UST)을 대출하는 등(IT조선, 2023, [테라 몰락 전말] ⑧앵커 20% 이자 주려고 ‘돌려막기’ 파국, (5.4..) 참조), 루나코인에서의 시노리지 지급은 단순한 네트워크 내의 운영상, 관리상 행위를 넘어 타인(테라폼랩스)의 경영상 노력을 통한 수익의 지급이라고 볼 만한 여지가 크다고 생각된다. 2026.3.17.자 SEC 유권해석 역시 Liquid Staking 공급자가 추가 수익 제공을 위해 Staking Receipt Token을 발급하는 행위를 유권해석의 대상에서 제외하고 있다(각주 131, 54면).

115) 플랫폼 사업을 통한 거래수수료는 보유자에게 지급되고, 주조차익은 루나 가격의 상승에 일부 반영되는 형태인 것으로 보인다(조선비즈, 앞의 기사(2023.4.28.)).

116) 여기서 주조차익을 사업자의 노력으로 인한 루나의 가치증가로 본다면 이 부분은 전매차익이 아닌 공동사업의 결과로서의 수익으로 보는 것이 타당하다. 다만, “주조차익”은 결국 공동사업의 청산이 아니라 루나의 매각(전매)을 통해 실현되므로 일종의 전매차익으로 볼 여지도 배제할 수는 없어 보이고, 이 경우에는 루나코인의 투자계약증권성은 약화될 것이다.

기능”에 해당한다고 볼 여지가 커 보이는바, 투자자의 주요 투자동기가 (전매차익이 아닌) 이러한 수수료 수익 또는 주조차익이라고 볼 여지도 있어 보인다. 따라서 서울남부지방법원 2019가단225099 판결의 논리에 따르면, 루나코인의 투자계약증권성을 쉽게 배제하기는 어려울 것으로 보인다. 한편, 투자자가 테라 블록체인 수수료를 지급받으려면 자발적 예치(스테이킹)이 필요하므로 수익의 분배에 해당하지 않는다는 견해¹¹⁷⁾가 있으나, 투자자의 스테이킹 참여는 테라·루나 프로젝트라는 공동사업의 한 요소이므로 이를 분리하여 판단하는 것은 타당하지 않다고 생각된다.¹¹⁸⁾

한편, 거래소를 통해 일반투자자에게 판매된 부분에 대해서 투자계약 여부를 인정할지에 대해서는 미국 내에서도 판례의 입장이 상충하고 있다. 리플 사안에서는 일반투자자들을 대상으로 가상자산 거래소를 통해 프로그램 판매(Programmatic Sales) 방식으로 발행·유통된 부분은 판매자와 구매자가 서로 모르는 블라인드 거래(blind bid/ask transaction)이고, 리플랩스와 의무보호예수 등의 계약을 체결하거나 사업계획에 대한 자료가 제공되지 않은 점 등을 이유로 “타인의 노력” 및 “수익 기대” 요건을 충족하지 않는다고 보았다. 이와 달리, 기관투자자에게 발행·유통된 부분의 경우 리플랩스의 홍보, 마케팅 그리고 기관 판매의 성격 등을 고려할 때 기관투자자의 자금이 리플 시장의 활성화 및 리플 원장(Ledger)의 개발에 사용하여 리플의 가치를 증가시킬 것이라는 점을 기관투자자가 이해할 수 있었다는 점을 근거로 동 요건을 충족한다고 보았다.¹¹⁹⁾ 그런데 테라·루나 코인 사건에서의 같은 법원 재판부는 리플 사건 재판부의 판시를 비판하며, Howey 기준은 증권의 판매 방식에 따라 증권성을 구분하지 않는다고 보았다. 즉 루나의 일반투자자들도 코인의 판매수익이 투자자의 이익을 창출하기 위해 사용할 것이라고 믿을 만한 상당한 이유가 있다고 판단하였다.¹²⁰⁾ 미국의 판례가 정립되지 않아 속단하기 어려운 면

117) 이중기, 앞의 논문(2023), 101면.

118) 그리고 위 견해에서 명시적으로 다루어지지 않는 것은, 투자자의 참여행위가 있다는 이유만으로 “주로 타인이 수행” 요건을 부정하기도 어렵다고 사료된다. 또한 앞서 살펴본 2026.3.17.자 SEC 유권해석의 내용을 고려하면, 스테이킹이 가상자산 네트워크 내에서의 운영상, 관리상 검증을 위해서가 아니라 보유자의 수익 보상을 위해 이루어지는 경우에는 “주로 타인이 수행” 요건이 해당할 여지가 클 것이다.

119) 동 판례에 대한 상세한 분석은 전우정, 앞의 논문(2023), 이상근·양창규·임승민, 2024, “가상자산의 증권성 판단기준에 대한 연구”, 증권법연구 제25권 제1호, 107-109면 참조.

120) SEC v. Terraform Labs, Pte, Ltd., Case 1:23-cv-1346(JSR) - Document 51 (S.D.N.Y. Jul. 31, 2023), 40-42면. 한편, Dapper Labs가 발행한 NFT의 판매가 투자계약에 해당하는지에 대한 소송에서 동사가 제기한 소송각하신청(motion to dismiss)에서 뉴욕남부지방법원도 투자자의 구매경로가 발행시장인지 유통시장인지를 구분하지 않고 투자계약임을 인정하였다(Friel v. Dapper Labs, Inc. et al, Case 1:2021cv05837).

이 있으나, 이러한 판례 간 견해 대립은 적어도 판매 단계에 따라 일괄적으로 증권성을 판단하는 것이 아니라 발행인 등의 노력으로 인한 이익 및 그에 대한 기대 요건의 해당 여부를 구체적인 사실관계를 종합적으로 감안하여 개별적으로 살펴야 한다는 것을 시사한다.¹²¹⁾ 자본시장법의 맥락에서도 어떤 가상자산이 유통시장을 통해 투자자에게 판매되었더라도, 구체적, 개별적 사실관계 검토 시 타인의 노력에 따라 수행되는 공동사업의 결과에 따른 손익이 투자자에게 귀속되고 그러한 권리에 대한 표시가 투자자에게 충분히 이루어져서 투자자가 합리적으로 이를 기대할 수 있었다면 증권성을 인정함이 타당하다고 생각된다.

(3) 소결

투자계약증권과 관련한 법원 판례 및 수사사례는 가상자산의 증권성 판단과 관련한 사안이 대부분이다. 서울남부지방법원 2019가단225099 판결에서 법원은 가상자산에 거래소 수익 분배 등의 기능이 있더라도 부수적으로 제공하는 이익에 불과하다고 하여 전매차익형 공동사업을 투자계약증권에서 배제한 것으로 보인다. 그러나 수익분배가 부수적인 것으로 판단하는 근거, 수익분배 부분만을 투자계약증권으로 볼 여지, 수익분배와 전매차익이 혼재된 경우 증권성 충족을 위해 수익분배가 차지하여야 하는 비중 등이 설명되지 못한 한계점이 존재한다.

한편, “루나 코인” 사건에서 검찰은 루나 코인이 자본시장법상 투자계약증권에 해당한다고 판단한 바 있고, 뉴욕 남부 연방지방법원 역시 루나 코인이 미국 증권법상 투자계약에 해당한다고 판단하였다. 서울남부지방법원 2019가단225099 판결 사안과 달리 루나 코인의 기능(테라 코인의 가치고정 목적)을 고려하면 루나코인 보유로 인해 발생하는 수수료 수익 또는 주조차익은 “내재된 계약상 권리가거나 본질적 기능”이라고 볼 여지가 커 보여서, 동 판결의 논리에 따르더라도 루나코인의 투자계약증권성을 간단히 배척하기는 어려워 보인다. 그리고 거래소를 통한 루나 판매분에 대해서도 구체적, 개별적 사실관계를 검토하였을 때 투자계약증권의 요건을 충족한다면 투자계약증권성을 인정하는 것이 타당하고, 유통채널에 따라 증권성을 일괄적으로 판단하는 리플 사안에서의 미국 재

121) 김갑래, 2024, 미연방법원의 루나 증권성 판결의 시사점, 자본시장포커스(2024-08호), 5면도 유사한 취지이다. 또한 2026.3.17.자 SEC 유권해석도 유통시장에서 본질적인 경영상 노력으로 인한 이익에 대한 합리적 기대 요건이 유지되는 경우 증권성이 인정될 가능성을 배제하지 않고 있다.

판부의 논리를 그대로 수용하기는 어렵다고 생각된다.

3. 증권성 판단 관련 실무상 쟁점

투자계약증권성이 인정된 뮤직카우 및 한우·미술품 조각투자 사례에서는 발행인 외에도 공동사업에 참여하는 제3자가 존재하는 경우들이 있었으며, 실무상 증권성 검토 단계에서도 공동사업 구조상 제3자가 특정한 역할을 수행하는 경우가 발생하고 있다. 이와 관련하여 “주로 타인이 수행” 요건에서 “제3자”의 범위가 문제가 된다. 그런데 “제3자”의 범위를 확장하게 되면 발행인이 여러 개의 상이한 공동사업을 수행하는 플랫폼화 현상이 발생할 것으로 예상되고, 실무상 유사한 우려가 존재하는 사안들이 발생되고 있는바 관련 법률상 쟁점을 검토한다.

(1) “주로 타인이 수행” 요건에서 타인의 범위

자본시장법은 “타인”에 다른 투자자가 포함된다고 할 뿐 타인의 범위에 대하여 별다른 언급을 하고 있지 않으므로, 이는 해석상의 문제에 해당한다. 토큰증권 가이드라인에서는 위 요건과 관련하여, 타인(발행인)의 노력이 부정할 수 없을 정도로 중대하여 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상 노력이 있어야 한다고 하면서도, 발행인이 모든 사업을 직접 수행하지 않더라도 투자자 외에 사업주체의 공동적·집단적 노력이 있는 경우를 포함한다고 하고 있다. 이는 타인이 발행인에 국한되지는 아니하고 “투자자 외 사업주체”를 포함하는 개념인 것은 인정된 것으로 보이며, 다만 그 노력의 정도에 있어 발행인의 (독자적) 노력은 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상 노력이어야 한다는 것으로 이해된다. 그러나 토큰증권 가이드라인은 “투자자 외 사업주체”의 외연에 대하여 구체적으로 언급하고 있지는 않으며, 금융당국이 판단하는 투자자 외 사업주체(제3자)의 외연은 증선위의 증권성 판단사례를 통해 추측해 볼 수 있다.

예컨대 뮤직카우의 청구권 사례에서 뮤직카우의 자회사인 뮤직카우에셋은 저작권의 매입, 신탁 및 저작권 수탁자(저작권협회)로부터의 수익권 취득 및 뮤직카우에 대한 청구권 발행 업무를 담당하였는데, 증선위는 뮤직카우와 뮤직카우에셋의 업무를 구분하지

않고 “주로 타인 수행” 요건을 충족한다고 보았다. 미술품 조각투자 사례에서도 테사는 완전자회사인 테사에셋이 작품을 선매입 후 투자자에 매각하며, 미술품의 관리, 매각 업무도 테사에셋이 수행하고 사업 관련 인적조직(아트리서치팀) 역시 테사에셋 내에 위치¹²²⁾하였음에도 테사가 “주로 타인 수행” 요건을 충족한다고 보았다. 그리고 증선위는 옥션, 갤러리 등의 협력사 네트워크도 발행인의 “주로 타인 수행” 요건을 충족하는 요소로 판단한 바 있다. 한편 한우 조각투자(스탁키퍼) 사례에서는 한우의 사육은 농가회원에게 위탁되어 있었음에도 발행인이 “스탁키퍼”가 해당 요건을 충족한다고 보았다.

이러한 점을 고려하면, 금융당국은 ① 회사가 이사의 임면 등 주요 사항을 통제할 수 있는 자회사의 경우에는 공동사업의 주된 업무의 대부분(예컨대 기초자산의 매입, 운용, 관리, 매각업무 등)을 수행하더라도 해당 요건을 충족한다고 보는 것이 주류인 것으로 보이며, ② 회사가 경영상 유의적인 영향력을 행사(관계사)하거나 계약상 감독관계에 있는 자의 경우에는 공동사업의 주된 업무의 일부분(계약상 내용대로의 사육 위탁)¹²³⁾을 수행하고, 그에 대한 적절한 통제 및 감독 권한을 보유한 경우에 해당 요건을 충족하는 경향이 있었던 것으로 보인다.

학설상으로는 “타인”이 사업자 이외의 제3자도 포함하나, 이는 제3자에 의하여 사업 수익이 영향받을 수 있음을 의미하는 것이지 사업자의 노력은 배제된 채 그 밖의 제3자에 대해서만 사업의 수익이 결정되는 것은 아니라는 견해¹²⁴⁾, 타인은 투자자에게 공동사업의 손익을 귀속하는 내용의 계약을 한 직접 상대방과 그 자에 대하여 공동사업상 손익을 귀속시키도록 구속할 수 있는 자, 그리고 투자자와의 사이에 그러한 계약을 체결하도록 주선한 자를 포함한다는 견해¹²⁵⁾ 등이 존재한다. 미국 법원의 판례나 미국 금융당국의 유권해석에서는¹²⁶⁾ 권유자 또는 제3자의 노력(efforts of the promoter or a third

122) 넘버스, 2022, 미술품 천원 투자 가능한 ‘테사’의 수익모델은? 비상장 투자노트, (12.14.) ([https:// numbersmoney.co.kr/2022121408/](https://numbersmoney.co.kr/2022121408/)). 동아일보, 2022, “미술품 가치를 ‘데이터’로 분석합니다” 테사 에셋의 아트 애널리스트 이야기, (6.10.) 참조.

123) 스탭키퍼의 한우 조각투자는 농가가 아닌 스탭키퍼가 사료를 공급하고, 사육환경, 개체상태 등을 스탭키퍼가 보유한 전문인력이 수시로 확인하므로, 농가의 재량이 축소된 형태로 보여진다.

124) 이정수, 앞의 논문(2023), 144면.

125) 심인숙, 앞의 논문(2008), 85면. 다만, 이 견해에서 제안한 정의는 “발행인(즉 투자자와의 계약의 직접 상대방)”이 공동사업의 수행을 위하여 법률상, 계약상 권리를 행사하는 상대방(즉 자회사나 발행인과 공동사업 업무의 일부 수행을 위한 위탁계약을 체결한 상대방 등)을 포섭하지 못하는 문제가 있어 보인다.

126) 미국 증권거래위원회(SEC)는 2019.4. 가상자산에 대한 투자계약증권성 분석 프레임워크(Framework for “Investment Contract” Analysis of Digital Assets)를 발표하여 디지털

party) 판단 시 제3자의 요건을 구체적으로 제한하고 있지는 않으며, 적어도 권유자가 독자적으로 위 요건을 충족하여야 한다는 등의 제한사항도 부과하고 있지 아니하다.

그러나 대부분의 사안에서 발행인(promoter)과 제3자 사이에는 계열관계나 계약관계 등 법률상·계약상 연관관계가 존재하고¹²⁷⁾, 미국에서도 권유자와 제3자 간에는 계열관계, 계약관계, 기타 합의 등의 구속력과 같은 견련성(Nexus)을 요구하는 견해가 유력한 것으로 보인다.¹²⁸⁾

이러한 점을 고려하면 “주로 타인 수행”의 요건에서 “타인”은 발행인에 국한되지는 아니하고, 투자자 외 다른 제3의 사업주체를 포함하는 개념이라고 봄이 타당하다. 그리고 그 제3의 사업주체는, 최소한 발행인과 지분관계 또는 계약관계 등으로 법률상·계약상 연관관계가 존재하여 공동적·집단적 노력이 있다고 평가할 수 있을 정도여야 한다고 봄이 타당하다고 생각된다. 다만 토큰증권 가이드라인에서 밝힌 “발행인의 노력이 부정할 수 없을 정도로 중대하여 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상 노력이어야 한다”는 원칙은 앞서 살펴본 우리나라 및 미국의 학설과 유권해석, 판례 등에 비추어볼 때 다소 엄격한 측면이 있어 보이고, 그간 증권성 판단사례에서 보인 경향과도 일치하지 않는 측면이 있다. “발행인 및 제3의 사업주체의 공동적·집단적 노력이 부정할 수 없을 정도로 중대하여 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 경영상 노력이어야 한다” 정도로 완화하는 것이 바람직해 보인다. 그리고 발행인의 고유의 노력이 요구되는 점은 인정하되 공동사업과 관련하여 제3자에 대한 법률상·계약상 연관관계의 보유·관리의 관점에서 평가하는 것이 적절하다고 생각된다.

자산의 증권성 판단을 위한 기준을 제시하였는데(SEC, 2019, Framework for “Investment Contract” Analysis of Digital Assets, (4.3.)), Howey 요건 중 “타인의 노력” 및 “이익 기대” 요건의 판단 기준을 상세히 제시하였다. 이에 따르면, 가상자산 발행을 주도한 적극참가자(Active Participant)가 사업의 성공에 영향을 미치는 결정적인 경영상 노력을 제공하는 경우에는 “타인의 노력” 요건을 충족하는데, 여기서의 적극참가자는 권유자(promoter), 후원자(sponsor) 또는 제3자(third party)(또는 그 제3자의 계열사)로 열거하고 있고 제3자를 구체적으로 정하고 있지는 아니하다.

127) 가령 Howey 사건에서도 농장관리, 재배, 과일 판매 등의 핵심업무는 권유자(W.J. Howey Company)가 아닌 계열사(Howey-in-the-Hills Service)가 운영하였다.

128) Robert C. Art, Sell A condominium, Buy A Securities Lawsuit: Unwarranted Liabilities in the Secondary Market, 53 Ohio St.L.J. 413(1992) 참조. 이에 의하면, 견련관계는 계열관계, 계약관계, 기타 합의 등의 구속력을 의미한다.

(2) 조각투자의 플랫폼화 현상 검토 및 발행인 인가제 도입 필요성

현재 발행된 투자계약증권은 발행인이 어느 특정 기초자산(미술품, 한우)의 매입·관리·운용업무를 전문성을 가지고 수행하는 구조이나, 투자계약증권 시장이 성숙화되고 발행인 외 제3자의 참여가 증가할수록, 발행인(플랫폼 운영자)이 여러 개의 상이한 공동사업(플랫폼에 입점한 제3자들의 노력에 따라 수행됨)에 대한 투자계약증권을 발행하는 플랫폼 구조에 대한 유인이 커질 것으로 보인다.¹²⁹⁾ 이러한 플랫폼 구조는 플랫폼 사업자가 수행하는 역할에 따라, (i) 플랫폼 사업자가 투자자로부터의 청약 접수 및 청약증거금 수납, 증권발행의 중개¹³⁰⁾, 사업손익 정산 등 증권관련 사무만을 영위하고(공동사업의 주된 내용에 대해 제3자와의 법률상·계약상 연관관계는 없음) 공동사업은 실질적으로 제3자가 영위하는 구조, (ii) 플랫폼 사업자가 증권관련 사무 수행은 물론 공동사업의 주된 내용에 대해 제3자와의 법률상·계약상 연관관계를 보유·관리하는 구조로 구분할 수 있다.

위 (i)의 구조에서 플랫폼 업체는 제3자가 발행한 투자계약증권에 대한 중개·주선 업무를 수행할 것이므로, 투자계약증권의 발행에 대한 투자중개업을 영위하는 것으로 판단되는바 관련 인가를 취득할 필요가 있다.¹³¹⁾ 그리고 제3자는 투자계약증권의 발행인으로서 증권신고서를 제출할 의무가 있을 것이나 자본시장법은 자기가 증권을 발행하는 것은 동법이 정한 예외에 해당하지 않는 한 투자매매업으로 보지 않으므로(제7조 제1항),

129) 공모 투자계약증권 발행인 중 실제 플랫폼 구조를 가진 경우는 없는 것으로 보인다. 참고로 스타키퍼의 한우 조각투자에서 자금 모집 및 사업 수행의 주체가 사육농가 역시 투자계약증권의 발행인에 해당한다는 견해도 존재하는데(성희환, 앞의 논문(2022, 53면)), 이 견해에 의하면 한우 조각투자는 위 플랫폼 구조에 해당할 수 있을 것이다. 그러나 현재 발행되는 한우 조각투자에서 농가는 발행인이 정한 기준에 의하여 선정되고, 사료 역시 발행인이 공급하며, 주기적으로 사육관리를 발행인 소속 인력이 평가하는 등, 농가가 주도적으로 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 노력을 하여 독자적으로 발행인의 지위에 있다고 보기에는 어려운 측면이 다수 존재한다고 생각된다. 다만, 투자계약증권 발행업체 중 투자계약증권의 대상이 되는 기초자산의 변경·확장을 검토한 경우는 존재하는 것으로 보인다.

130) 제3자와의 법률상·계약상 연관관계가 없는 이상 플랫폼 사업자는 “주로 타인이 수행” 요건을 충족하기 어려우므로, 플랫폼 사업자는 투자계약증권에서의 사업자의 자격이 있다고 보기 어려우나 투자계약증권을 발행하기는 어려울 것이다.

131) 현행 자본시장법상 투자계약증권에 대한 발행 단계에서의 투자중개업의 인가단위(이른바 발행플랫폼)는 존재하지 않고 토큰증권 가이드라인에서도 투자계약증권의 유통플랫폼(장외거래 중개) 계획만을 발표하였을 뿐이므로(금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2023.2.3.), 별첨 10면), 현 시점에서 이러한 투자중개업의 실현가능성에 다소 의문은 있으나, 앞서 언급한 토큰증권 협의체 등에서의 논의 결과에 따라 이러한 내용의 투자중개업 인가단위가 추가될 가능성은 존재한다. 이 경우 그러한 인가단위의 영업의 내용은 한국ST거래의 혁신금융서비스(소상공인 투자계약증권 장외거래플랫폼) 구조에서 소상공인의 투자계약증권 발행을 중개하는 증권사의 역할과 유사할 것으로 보인다.

제3자가 투자매매업 인가를 취득할 필요는 없다. 한편 (ii)에서는 투자계약증권 발행이 플랫폼화 되더라도, 플랫폼 업체가 단독으로 또는 입점한 제3자와 함께 사업자(발행인)의 지위를 유지하는데, 이 경우에 플랫폼 업체는 자신이 투자계약증권을 발행하는 것이므로 금융투자업 인가를 취득할 필요는 없다. 즉 전자의 구조에서 제3자, 후자의 구조에서 플랫폼 업체는 자본시장법상 금융투자업 규제를 받지 않는다.

그러나 (i) 자금조달을 위한 통상적인 증권의 자기발행과 달리 증권발행 자체로 발행인이 이익을 수취하게 되는 점, (ii) 투자계약증권은 기본적으로 금융투자업(집합투자업)의 요소가 존재하는 점, (iii) 조각투자의 특성상 조각투자 사업자에 대한 투자자들의 의존이 절대적인 점¹³²⁾, (iv) 플랫폼화 현상에 따라 플랫폼업자 및 공동사업 참여자(제3자)가 증가할 것인데, 현재 실무상 운영되는 증권성 판단에 대한 당국의 견해 질의 절차로는 부적격 발행인의 난립을 제어하기 어려운 점, (v) 당국의 위 증권성 판단이 현재도 기능적으로는 투자계약증권 발행에 대한 인허가 역할을 수행하고 있는 점 등을 고려하면, 자본시장법상 개별 증권의 공모규제만을 적용하는 것은 금융투자업 규제의 형평이나 투자자 보호체계 구축 차원에서 다소 부족한 측면이 있다고 판단된다. 이러한 점을 고려하면, 투자계약증권을 일정 규모 이상 발행하거나 상이한 특성의 공동사업을 일정 종류 이상 영위하는 발행인에 대해서는 투자매매업 인가 및 영업행위 규제 등의 업자규제를 적용할 필요가 있다고 생각된다.¹³³⁾

그리고 인가 및 영업행위규제의 구체적인 내용은 세심한 고려가 필요하겠으나, 최소한 비금전신탁 수익증권의 발행 관련 투자중개업의 인가규제 및 영업행위 규제 내용¹³⁴⁾

132) 이한준, 앞의 논문(2023), 151-152면.

133) 인가제도 적용이 투자계약증권 활성화에 제약으로 작용할 수 있다고 보는 견해도 존재할 수 있다. 그러나 (1) 아래에서 살펴보는 바와 같이 토큰증권 관련 자본시장법 시행에 따라 투자계약증권에 대하여 금융소비자보호법이 적용되는 이상(인가제 미도입시) 금융상품판매업자 등록의무가 발생할 수 있는바(이영경, 2022, 조각투자의 거래구조와 투자자 보호, 선진상사법률연구 통권 제99호, 50면도 같은 취지) 인허가 부담이 과도하다고 보기 어려운 점, (2) 인가 과정에서 현재와 마찬가지로 투자계약증권의 증권성 판단 및 투자자보호장치 마련이 핵심적인 심사기준이 될 것인 점, (3) 현재의 증권성 판단절차도 실무상 적지 않은 기간이 소요되고 있고, 절차 진행과 관련한 규정이 마련되어 있지 않아 불확실성도 적지 않은 점 등을 고려하면 인가제도가 시장을 과도하게 위축하지는 않을 것으로 예상된다. 다만, 최저자본, 인적구성 등의 사업자와 관련한 인가기준을 적절한 수준으로 설정하여 발행인의 시장진입 자체가 원천적으로 차단되지 않을 필요는 있을 것으로 판단된다.

134) 비금전신탁 수익증권 투자중개업(발행플랫폼 스톡라이센스)의 자기자본 요건은 펀드 투자중개업과 같은 10억원(전문투자자 5억원)이며, NCR 등 규제는 기존 증권사와 모두 동일하게 적용되며, 샌드박스 지정 당시와 달리 발행-유통 분리원칙이 적용된다(금융위원회, 앞의 보도자료(2025.2.3.), 8면).

과 유사한 정도일 필요는 있을 것으로 생각되며, 일본의 사례를 참고할 수도 있을 것으로 보인다. 일본 금융상품거래법은 간주유가증권의 자기발행을 “자기모집”으로 규율하여, 이를 업으로 행할 경우 제2종 금융상품거래업에 해당하여 등록의무가 발생하며, 이러한 구조에서 모집하는 자금을 주식등의 유가증권에 투자하는 방식으로 운영한다면 투자운용업 등록까지 필요하다.¹³⁵⁾ 제2종 금융상품거래업 등록 시에는 법인의 경우 최저자본액의 규제를 받으며, 충분한 인적 구성의 보유의무도 존재한다(일본 금융상품거래법 제31조의2, 제29조의4).

IV. 투자계약증권 증권신고서 심사 및 유통 관련 쟁점

1. 증권신고서 심사체계 개관

(1) 투자계약증권 심사절차

투자계약증권을 공모발행하고자 하는 사업자는 먼저 발행하고자 하는 증권이 투자계약증권인지 판단할 필요가 있으며, 그 과정에서 사전에 당국에 증권성 판단여부를 질의할 수 있다.¹³⁶⁾ 이는 법률상 요구되는 절차는 아니나, 투자계약증권의 요건이 미충족될 가능성이 있는 상태에서 증권신고서가 제출되는 경우, 이는 중요사항의 기재누락 또는 기재 불분명으로서 정정신고서 제출 요구(정정요구)(자본시장법 제122조 제1항) 사항이 되고 그 시정이 불가능할 경우 자체가 불투명해질 가능성이 있다. 그렇기 때문에 기존 발행사례와 기초자산, 사업구조 등 공동사업 구조가 상이한 투자계약증권을 발행하고자 하는 사업자는 증권성 판단 소관부서에 해당 공동사업이 투자계약증권에 해당하는지

135) 일본 금융상품거래법은 원칙적으로 간주유가증권이 공모에 해당하더라도 증권의 공시규제를 적용하지 않는다는 차이가 존재하며(이한준, 앞의 논문(2023), 134면), 집단투자스킴이 주로 유가증권에 대한 투자를 하는 등 예외적인 경우에만 공시규제가 적용된다(제3조 제3호). 그러나 발행인 인가제도를 도입하더라도 이를 이유로 증권신고서 등 공시제도의 적용을 배제한다면 개별 증권발행에서의 투자자보호 및 투자자에 대한 정보제공이 소홀해질 가능성이 있는바, 이러한 입법 방향이 타당한지는 의문이다.

136) 금융위원회·금융감독원, 앞의 보도자료(2022.4.28.)(별첨, 6면)

를 문의하는 것이 일반적이다.

한편, 투자계약증권의 발행이 모집 요건에 해당하는 경우, 증권 발행 규모와 관계 없이 증권신고서 제출 의무가 발생한다(자본시장법 시행령 제120조 제1항 제3호).¹³⁷⁾ 이는 과거 1년간 증권 발행 또는 매출 금액의 합계액이 10억원 이상인 경우를 기준으로 하는 일반적인 증권신고서 제출 의무의 특례규정에 해당한다. 따라서 공모 투자계약 증권 발행에 있어서는 소액공모공시서류(자본시장법 제130조)의 제출 없이 모두 금융감독원의 증권신고서 심사를 받게 된다. 구체적인 증권신고서 심사절차는 다른 종류의 증권과 유사하다. 우선 증권신고서 제출 후 효력발생기간은 15일이나(자본시장법 시행규칙 제12조 제1항 제4호), 중요사항의 거짓기재·기재누락·기재불분명 등 정정요구 요건에 해당하는 경우 금융당국은 증권신고서의 정정요구를 할 수 있고(자본시장법 제122조 제1항), 이 경우 그 증권신고서는 정정요구일부터 수리되지 않은 것으로 간주된다(동조 제2항). 발행인이 증권신고서를 자진정정하는 경우에도, 발행조건, 납입기일 등 중요사항(자본시장법 제122조 제3항 후단, 동법 시행령 제130조 제1항 제1호)을 정정하는 경우, 증권신고서의 기재나 표시내용이 불분명하여 증권신고서를 이용하는 자로 하여금 중대한 오해를 일으킬 수 있는 내용이 있는 경우 등 투자자 보호를 위한 기재 정정(자본시장법 제122조 제3항, 동법 시행령 제130조 제2항)이 있는 경우에는 그 정정신고서가 수리된 날에 그 증권신고서가 수리된 것으로 간주되어 효력발생일을 다시 계산한다(자본시장법 제122조 제5항). 증권신고서의 효력이 발생한 후에는 증권 취득·매수에 대한 청약의 승낙을 할 수 있으며(자본시장법 제120조 제1항), 이 때 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도할 수 없다(자본시장법 제124조 제1항).

(2) 증권신고서 기재내용 및 첨부서류

한편 투자계약증권 증권신고서의 서식 및 작성방법은 증권 발행 및 공시 등에 관한 규정(이하 “증발공 규정”)의 위임(제2-6조 제11항)에 따라 금융감독원이 기업공시서식 작성기준을 정하도록 하고 있고, 투자계약증권 증권신고서 서식은 2023.7.31. 전면개정되면서 그 내용이 구체화되었다. 그 주요 내용을 살펴보면, 첫째, 증선위 사업개편에서

137) 2023.6.13. 자본시장법 시행령이 개정되어 투자계약증권과 금융소비자 보호에 관한 법률(이하 “금융소비자보호법”)상 적정성 원칙이 적용되는 증권을 모집·매출하려는 경우 증권 발행 규모와 관계 없이 증권신고서 제출 의무를 부과하였고, 이는 투자자보호의 강화 취지이다.

사업자들에게 요구되었던 조건이 신규사업자에 적용할 수 있도록 서식에 반영하였다.¹³⁸⁾ 기업공시서식 작성기준 제2-6-9조(투자계약증권 관련 투자자 보호)를 신설하여, 증권신고서 목차 중 “VI. 그 밖의 투자자 보호를 위해 필요한 사항”에 (i) 투자자별 공유지분 입증 및 기초자산 보관위치 확인수단 제공 또는 발행인의 도산위험과 법적 절연 관련, (ii) 투자자 예치금 보관 관련, (iii) 유통시장 관련, (iv) 투자판단에 중요한 사항에 대한 설명자료 및 광고 기준 마련, (v) 투자자 피해보상체계 및 분쟁처리절차, (vi) 회사의 사업중단 시 독립된 제3자의 업무수행에 관한 사항을 기재하도록 정하고, 그에 대한 작성지침을 기재하였다.

둘째, 발행인이 제출하여야 하는 필수첨부서류를 추가하고, 발행 이후에도 발행인이 투자자에게 제공하는 자체적인 정기·수시공시 내용을 명시하도록 하였다. 추가된 필수첨부서류는 최근 사업연도 회계감사인의 감사보고서 및 (분·반기 결산일이 지난 경우) 분·반기 검토보고서이며, 이는 증발공 규정상 필수첨부서류에 해당 서류가 명시되어 있지 않은 점을 보완하기 위한 것으로 보인다. 또한 자본시장법상 투자계약증권 관련 공시는 모집·매출 시 제출하는 증권신고서만 규정되어 있고, 주요사항보고서(자본시장법 제161조) 등의 수시공시사항이 정해져 있지 않기 때문에, 발행인이 자체적으로 정기·수시공시 제도를 운영·시행하도록 한 것으로 이해된다.

셋째, 동일 신고서 내 복수의 증권 발행(이른바 합산발행)과 복수 자산을 기초로 한 1개의 증권 발행(이른바 패키지발행)이 가능함을 명시하여 발행인의 증권발행 편의를 제고하였다. 넷째, 기초자산의 가치평가 원칙(외부평가 원칙, 예외적인 경우 사유 및 타당성을 제시하여 내부평가 가능)을 제시하였다(기업공시서식 작성기준 제2-1-3조). 다섯째, 기초자산에 대한 정보(취득, 보관·관리, 처분 관련 사항 등) 및 공동사업 참여자간 간 법률관계(투자자의 법적 지위, 증권이 표창하는 권리내용 등)에 대한 설명을 기재하도록 하였다(기업공시서식 작성기준 제2-2-3조 제1항, 제2항, 제2-3-2조).

투자계약증권의 증권신고서 제출 시에는 모집·매출 관련 주선계약 사본, 자금모집자와 투자자간 체결된 투자계약관계서류, 외부 업무위탁 존재 시 업무위탁계약서 사본, 변호사의 법률검토의견을 필수적으로 첨부하여야 한다(증발공 규정 제2-6조 제8항 제7호). 기업공시서식 작성기준 제2-6-5조 제1항은 법률검토의견의 경우 투자계약증권 해당여부, 공동사업의 목적이 다른 증권발행으로 가능한지 여부, 공동사업 구조의 관련 법

138) 금융감독원, 앞의 보도자료(2023.7.31.), 2면.

규 준수여부, 공동사업 구조상 법적 분쟁소지, 투자계약 관계서류의 적정한 작성여부, 투자자의 권리가 관련 법규 또는 계약에 따라 보장되는지 여부 등을 포함하도록 하고 있다. 이는 투자계약증권의 요건해당성, 보충성, 공동사업의 법규 준수 등 “신중증권 가이드라인”에서 적시한 요소들의 확인을 목적으로 한 것으로 이해된다.

2. 증권신고서 발행심사 단계에서의 법률상 쟁점

(1) 기초자산 매입 및 가치평가 적정성 관련

현재 발행된 미술품 및 한우 투자계약증권은 발행인이 기초자산을 선매입한 후, 제반 비용 및 각종 수수료(발행인이 수취하는 보수 포함)를 가산하여 모집금액을 정하는 구조를 취하고 있다. 따라서 기초자산 취득(선매입) 가격 또는 공동사업 운영비용¹³⁹⁾의 적정성 또는 기초자산의 가치평가 내용의 적정성은 투자자의 투자수익률과 직결되는 부분으로서 투자판단에 중요한 사항이라고 볼 수 있다. 이와 관련하여 기업공시서식 작성기준은 공모가격 결정시 객관적 외부평가기관(회계법인, 감정평가법인 등)의 가치평가(발행인의 2차검증 포함)를 근거로 결정하되, 기초자산 특성에 따라 예외적으로 내부평가를 한 경우에는 그 사유 및 타당성¹⁴⁰⁾을 제시하도록 하고 있다(제2-1-3조 제1항). 한편, 기초자산 취득정보 부분에서도 해당 기초자산의 과거 거래사례, 비교 기초자산 거래사례(비교사례 선정기준 포함), 해당 기초자산에 대한 가치평가(외부평가기관, 자체평가), 기초자산의 현재 상태 등을 고려한 취득가격의 적정성을 기재하도록 하고 있다(제2-2-3조 제1항).¹⁴¹⁾ 또한, 기초자산 매도인에 대한 정보를 기재하되, 매도인과 공동사업자와의 관계가 특수관계인에 해당할 경우 이를 반드시 명시하도록 하고 있는 점(제2-2-3조 제1항)도 취득가격의 적정성 평가를 위한 요소로 생각된다.

이와 관련하여 금융감독원은 외부평가법인이 기초자산 매도인 소속 직원의 자문의견을 근거로 기초자산 가치를 감정하는 경우, 외부평가에 참여한 전문가의 세부 정보가

139) 한우 조각투자에서 모집금액에 포함된 사료비 및 농가에 지급할 사육관리비가 그러한 예이다.

140) 전문인력 등 내부 전문성 및 객관적인 근거(내부평가에 대한 외부기관 검증내역, 신뢰할 수 있는 통계적 자료 등)를 제시하도록 정하고 있다.

141) 이때 외부평가기관이 아닌 내부적으로 가치평가를 실시한 경우 회사가 기초자산에 대해 보유하고 있는 전문성, 전문인력 등을 상세히 기재하고, 이에 대한 객관적인 근거(외부기관 검증, 신뢰할 수 있는 통계적 자료 등)를 제시하도록 정하고 있다.

미기재한 경우에 대해 보완을 요청하여 외부평가에 매도인이 참여하지 않고 외부평가 참여 전문가의 정보를 공개하도록 보완하였다고 밝힌 바 있는데¹⁴²⁾, “객관적” 외부평가기관의 가치평가 요건을 미충족할 가능성을 염두에 둔 것으로 보인다. 또한 기초자산의 취득이 공개경매와 같은 객관적인 방법이 아닌 경우에는, 기초자산 취득 상대방에 대한 정보를 기재하고 매도인의 입수경위 등 유통경로(예컨대 미술품에서의 provenance)를 구체적으로 제시하는 것이 바람직하다고 생각된다.¹⁴³⁾ 또한, 내부평가를 거래사례비교법으로 수행하더라도, 그것만으로 내부평가의 적정성이 담보되지는 않으며, 가격범위 추정을 위한 변수 추정 시 변수별로 산출기간을 달리하는 등 객관성이 담보되지 않는 경우에는 증권신고서 정정요구의 대상이 될 수 있는 점에 유의할 필요가 있다.¹⁴⁴⁾

(2) 사업자 도산위험 절연 관련

증권위 사업개편 요건은 “물건에 대한 투자자별 소유권 공유지분을 입증할 수 있는 법적 수단과 물건의 보관 위치를 수시로 확인할 수 있는 수단을 제공하거나, 투자자의 권리·재산을 사업자의 도산위험과 법적으로 절연시킬 것”, “투자자에치금을 받는 경우 외부 금융기관에 별도 예치 또는 신탁하고 사업자 도산 시 예치금이 반환될 수 있도록 조치”할 것을 요구하고 있고, 앞서 본 바와 같이 이는 기업공시서식 작성기준(제2-6-9조)에도 반영되어 있다.

미술품 및 한우 조각투자의 경우 투자자가 납입 이후부터 기초자산의 처분 이전까지 기초자산의 소유권을 민법상 공유의 형태로 보유하는데, 사업자가 파산하거나 회생결자에 들어가더라도 투자자가 기초자산에 대하여 환취권을 행사하여 기초자산을 반환받을 수 있다는 점(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제70조, 제407조)에서, 채무자 투자자의 재산(공유지분)을 사업자의 도산위험과 절연하기 위한 방법으로 평가할 수 있다. 그런데 동산의 물권변동은 인도로서 이루어지므로(민법 제188조 제1항), 문서상 공유지분을 법적으로 입증할 수 있는 보조적 수단을 제공할 필요가 있다. 이에 따라 현재 투자계약증권

142) 금융감독원, 앞의 보도자료(2023.12.15.), 4면.

143) 예컨대, 2024.12.20. 투게더아트가 제출한 투자계약증권 증권신고서(II. 증권의 주요 권리 내용)의 기초자산은 개인(2인)으로부터 매입한 것인데, 작품의 유통경로 및 전시내역, 진위 등에 대한 설명이 기재되어 있다.

144) 금융감독원, 2024, 2023년 증권신고서 정정요구 사례, 금융감독원 공시유의사항, 27면 참조. 기초자산 가치의 상단가 및 하단가를 추정하기 위한 변수별로 산출기간이 상이한 점에 대하여 정정요구를 수행한 사례를 소개하고 있다.

발행인들은 기초자산별로 투자자 공유지분이 표시된 투자자명부를 작성하여 공증을 받고, 투자자가 공증 내역을 열람할 수 있도록 하고 있으며, 보관위치 및 보관상태를 확인할 수 있는 절차도 구비하고 있다.¹⁴⁵⁾ 또한 청약 및 납입 단계에서, 투자자들이 지급한 투자계약증권 청약증거금 또는 납입금(별도 청약증거금 지급절차가 없는 경우)은 청약증거금 관리기관 명의의 계좌, 특정금전신탁 계좌 또는 에스크로 계좌 등에 예치되고 있다.¹⁴⁶⁾

한편, 증선위 사업개편 요건이나 기업공시서식 작성기준 모두 기초자산 처분 및 공동사업 정산 단계에서의 도산절연을 명시적으로 언급하고 있지는 않다. 그러나 투자자의 권리·재산이 사업자의 도산위험과 절연되어야 하는 원칙은 정산 단계에서도 적용된다고 보는 것이 타당하기 때문에, 기초자산의 매각대금은 사업자의 도산 위험과 분리될 필요가 있다. 이러한 점에서, 현재 투자계약증권 발행인들은 기초자산의 매각대금을 청약증거금과 마찬가지로 계좌관리기관 명의의 계좌, 특정금전신탁 계좌 또는 에스크로 계좌에 분리하여 보관한 후 정산금을 투자자에게 지급하는 구조를 취하고 있다.

그런데 발행인의 채권자가 이와 같이 예치된 청약증거금 또는 매각대금이 발행인의 재산임을 주장하며 강제집행절차를 개시할 수 있는가? 특정금전신탁의 경우 대외적으로 수탁자의 소유이므로 그러한 우려가 낮으나, 계좌관리기관 명의 계좌 또는 에스크로 계좌의 경우 발행인의 채권자가 발행인이 계좌관리기관에 대하여 그 금전의 소유권 또는 금전의 반환채권을 보유할 수 있다고 주장할 가능성을 상정해볼 수 있다. 그러나 발행인과 계좌관리기관이 체결한 계좌관리계약에서 청약증거금 및 매각대금이 투자자 재산임을 인지하고 발행인의 채권자가 강제집행절차를 개시하는 경우 계좌관리기관이 동 자금이 투자자의 소유임을 진술하고 대응하도록 하거나¹⁴⁷⁾, 에스크로계약에서 납입금 및 매

145) 예컨대, 스타키피의 경우 측사 영상시스템의 열람을 요청하여 확인할 수 있다(2025.10.10.자 증권신고서 참고).

146) 예컨대, 투게더아트의 경우 청약증거금을 특정금전신탁 계좌에, 스타키피의 경우 청약증거금을 계좌관리기관 명의의 별도계좌에, 열매컴퍼니의 경우 납입금이 계좌관리기관의 에스크로 계좌에 보관된다(투게더아트의 2024.12.20.자 증권신고서, 스타키피의 2025.10.10.자 증권신고서, 열매컴퍼니의 2025.6.26.자 증권신고서 등 참조).

147) 예컨대 스타키피의 2025.10.10.자 증권신고서의 첨부서류 중 농협은행과의 NH오픈플랫폼 <온라인조각투자API서비스> 추가약정서 제7조, 신한투자증권과의 투자자 예치금 관리서비스 업무제휴 약정서 제10조 참조. 위 조항은 계좌관리기관이 예치된 청약증거금 및 매각대금에 대하여 담보제공, 제3자 양도, 발행인 또는 제3자에 대한 채권과 상계하거나 압류하는 행위 금지, 발행인의 사업중단 시 사전에 선임된 업무대행법인의 기초자산 처분업무 수행에 협조할 의무 등 예치된 자금의 투자자 보호와 관련한 내용도 포함하고 있다.

각대금이 담보제공, 제3자 양도 및 제3자에 대한 채권과 상계가 불가하다는 점을 명시하도록 하였는바¹⁴⁸⁾, 그러한 주장이 타당하다고 보기 어려우며 그러한 상황이 발생할 가능성도 낮다고 보인다.¹⁴⁹⁾

(3) 기초자산의 소유, 보관 및 처분방법 관련

현재 투자계약증권은 발행인이 발행 전 기초자산을 선매입하여 보유한 후, 투자계약증권 발행 완료 시에 투자계약에 따라 기초자산의 소유권(공유지분)을 투자자들에게 투자계약증권의 수에 비례하여 양도하는 형태를 취하고 있다. 그런데 소유권의 이전에도 불구하고 기초자산은 발행인이 점유¹⁵⁰⁾하게 되는데, 동산의 물권 양도에 필요한 인도는 점유개정(민법 제189조)을 통하여 이루어진다.¹⁵¹⁾ 그리고 기초자산의 관리와 관련하여 공유물의 관리에 관한 사항은 공유자의 지분의 과반수로써 결정하고, 보존행위는 각자가 할 수 있는 것이 원칙이나(민법 제265조), 사업자(발행인 등)가 공동사업을 운영하는 투자계약증권의 특성상, 투자자와 사업자 간 투자계약에서 기초자산의 관리에 관한 내용을 사업자에게 위임하는 것이 일반적인 것으로 보인다.¹⁵²⁾ 그러나 발행인 또는 발행인으로 부터 관리를 위탁받은 제3자가 기초자산의 관리를 해태하거나, 기초자산을 투자계약에 따른 처분절차를 위반하여 처분하는 경우에 투자자 보호에 공백이 발생할 수 있으므로, 투자자가 기초자산의 관리상황을 확인할 수 있는 수단이 필요하다. 이러한 차원에서 현재 발행된 투자계약증권에서는, 공동사업에 대한 정기 및 수시공시 사항 이외에, 투자자가 투자계약상 기초자산의 물색, 취득, 사육, 관리, 매각, 정산과 관련한 서류를 열람할 권리를 정하고, 증권신고서에 청약 이후 기초자산의 열람·확인과 관련한 정책 및 절차를 기

148) 예컨대 2025.7.16.자 열매컴퍼니의 증권신고서의 VI. 그 밖의 투자자 보호를 위해 필요한 사항, 5. 투자자 보호장치에 관한 사항, 나. 투자자 예치금 보관 관련 참조.

149) 스타키퍼의 2025.10.10.자 증권신고서, 2025.7.16.자 열매컴퍼니의 증권신고서 등에 첨부된 법률검토의견 역시 유사한 취지의 의견을 개진하고 있다.

150) 발행인이 자체 수장고를 통하여 직접점유하는 경우도 있고, 보관의 위탁계약을 체결한 상대방(예컨대 미술품 수장고를 운영하는 업체) 또는 기초자산을 관리(사육)하는 상대방(예컨대 투자계약증권의 공동사업참여자인 농가)을 통하여 간접점유(민법 제194조)하는 형태도 존재한다.

151) 한서희, 2023, 조각투자를 둘러싼 법적 쟁점에 관한 연구, 금융법연구 제20권 제3호, 91면. 이영경, 앞의 논문(2022), 51면.

152) 예컨대, 스타키퍼가 제출한 2025.10.10.자 증권신고서에 첨부된 투자계약(이하 “스타키퍼 투자계약”) 제17조, 제20조, 제23조(사육 시 준수사항을 정하고 있다), 투게더아트가 제출한 2024.12.20.자 증권신고서에 첨부된 투자계약(이하 “투게더아트 투자계약”) 제22조, [별첨 3] 등 참조.

재하고 있다.¹⁵³⁾

현재 발행된 미술품·한우 투자계약증권의 공동사업 구조는, 그 청산 시 기초자산의 처분이 요구되는 형태이다. 공유물의 처분은 공유자의 전원 동의가 있어야 하는데(민법 제264조), 투자자가 불특정 다수인 조각투자의 특성상 민법상 원칙을 그대로 적용하는 경우 공동사업의 청산이 무한정 지연되거나 불가능하게 될 가능성이 있다. 이에 따라 미술품·한우 투자계약증권에서 투자자는 투자계약을 통해 사업자(발행인)에게 기초자산의 처분에 대한 권한을 위임하도록 하여, 사업자가 (투자계약상 위임 범위를 준수하는 범위 내에서) 기초자산의 처분 시점과 처분 가격을 적법하게 결정할 수 있도록 하고 있다. 다만, 공동사업의 취지를 고려할 때 사업자의 처분권한을 무한정으로 확장하는 것은 바람직하지 않은바, 통상적으로 투자계약상 기초자산의 처분권한의 위임 범위를 특정하고 있다. 예컨대, 기초자산의 매각방법을 한정(경매매각 또는 수의계약매각)하거나 기초자산의 매각시기의 범위 또는 시한을 규정하는 방식¹⁵⁴⁾, 최소 청산목표액을 하회하는 가격에 기초자산의 가격을 처분하는 경우에는 민법상 원칙에 따른 공유자 전원동의에 따르도록 하는 방식¹⁵⁵⁾ 등을 사용하고 있다.

한편, 민법상 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있는 것이 원칙이나(민법 제268조 제1항), 예외적으로 5년 내 기간으로 이를 분할하지 않을 것을 약정할 수 있고, 그러한 분할금지약정은 5년을 초과하지 않는 기간에서 갱신할 수 있다(민법 제268조 제1항, 제2항). 투자계약증권에서 일부 투자자가 공유물을 분할하는 경우 전체 공동사업의 시행에 중대한 지장을 초래할 수 있으므로, 투자계약에 기초자산의 분할금지약정 및 동 분할금지약정의 증권의 양수인에 대한 승계 조건을 추가하는 것이 일반적이다.

(4) 투자자 보호장치 및 금융소비자보호법 적용 필요성

투자계약증권의 청약 과정에서 일반투자자를 보호할 수 있는 대표적인 장치는, 발행인 선배정 및 발행인의 청약미달 물량 인수, 청약 전 투자적합성 확인, 적정 수준의 1인당 청약한도 설정 등을 들 수 있으며, 이러한 사항은 증권신고서의 “제1부 I. 모집 또는 매출

153) 스타키퍼 투자계약 제16조, 투게더아트 투자계약 제20조의2 참조. 또한 투게더아트가 제출한 2024.12.20.자 증권신고서에서는 청약 이후에도 홈페이지를 통한 사전 관람신청을 통해 기초자산 관람이 가능하다는 점을 명시하고 있다.

154) 스타키퍼 투자계약 제24조 참조.

155) 투게더아트 투자계약 제8조의3 참조.

에 관한 일반사항”에 기재하는 것이 일반적이다. 이러한 장치들은 자본시장법 또는 금융 소비자 보호에 관한 법률(이하 “금융소비자보호법”)상 정해진 의무는 아니지만, 금융감독원은 “투자계약증권 투자자 보호 모범규준”에 이러한 사항을 기재하여 모범적 기준에 대한 입장을 제시하고 있다.¹⁵⁶⁾ 한편, 투자자가 연간 누적하여 청약할 수 있는 한도가 제한되어 있지는 아니하며, 증권신고서에서 적정한 투자범위를 권고하는 것이 일반적이다. 즉 기업공시서식 작성기준 별지(<별지 제1호 서식> : 증권신고서)에 의하면, “【투자결정시 유의사항】”의 예시문에서 일반투자자가 여유자산의 10%를 초과하여 투자계약증권 등 비시장성 자산에 투자하는 것을 자제하도록 당부¹⁵⁷⁾하도록 하고 있고, 대부분의 발행인은 이러한 예시 문구를 그대로 사용하고 있다.

증권의 투자한도에 대한 제한은, 투자계약증권과 유사한 상품을 비교하면 그 필요성이 인정된다.¹⁵⁸⁾ 예컨대 자본시장법상 크라우드펀딩(온라인소액투자중개업)(제117조의10 제6항) 관련 규정, 비금전신탁 수익증권 혁신금융서비스 지정조건, 온라인투자연계 금융업 및 이용자 보호에 관한 법률상 P2P투자(제32조, 동법 시행령 제27조)에서도 중복별, 누적 투자한도¹⁵⁹⁾를 정하고 있다.

또한 (혁신금융서비스 종료 이후) 비금전신탁 수익증권 발행플랫폼의 수익증권 발행과 관련하여, 금융당국은 투자 한도 등에 대한 감독은 증권신고서 심사를 통하여 종래 혁신금융서비스 지정과 동일한 강도로 진행한다고 밝히면서 적정한 청약한도의 설정을 투자자 보호장치로 예시하였다.¹⁶⁰⁾ 다만 그 투자한도 규제의 구체적인 내용을 어떻게 설정하는 것이 적절한지를 고민할 필요가 있다. 즉 투자한도를 (1) 투자액수를 기준으로 할

156) 위 모범규준에서는 선배정 비율의 하한이나 1인 청약한도의 상한을 정하고 있지는 아니하나, 예시된 사례에서 발행인 선배정 비율은 전체 발행예정 물량의 10%이며, (증권당) 1인 청약한도는 3,000만원이다.

157) 시장 규모가 비교적 작은 점, 시장활성화의 필요성, 발행인이 투자자 개인의 누적한도를 개별적으로 검토하는 것이 현실적으로 어려운 점 등을 고려하여 이를 권고사항으로 정한 것으로 보인다.

158) 증권에 투자한도와 관련한 규제는 조각투자 관련 시장이 초기 형성단계이므로 과도한 한도 규제가 시장 성장을 저해할 우려가 있는 점 등을 고려하여 투자한도 규제가 부적절하다고 보는 관점도 존재할 수 있다. 그러나 투자계약증권의 비정형성으로 인한 높은 투자위험을 고려할 때 투자한도 규제의 필요성이 존재하는 점, 미국의 소액공모규제(Regulation A+)에도 Tier2 단계 모집 시에는 일반투자자의 경우 소득기준 투자한도(연소득의 10% 이하)가 존재하는 점 등을 고려하면, 그 필요성 자체를 쉽게 부정하기는 어렵다고 생각된다. 다만 조각투자 시장의 잠재성 및 성장가능성을 고려하여 투자한도의 내용을 유연하게 판단할 필요는 있을 것으로 생각되며, 추후 발행시장이 안정화될 경우 투자한도 규제의 적용을 완화하거나 해제하는 것도 고려할 수 있을 것이다.

159) 상기 상품의 투자한도 제도를 간단히 비교한 내용은 아래와 같다.

지 아니면 청약금액을 기준으로 할지, (2) 투자계약증권의 연간 총 투자(청약)한도를 설정할지, (3) 종목별 또는 발행인별 한도를 설정할지, (4) 적격투자자 기준을 별도로 설정할지 등이다. 생각건대 이는 정책적 판단의 영역이기는 하나 (1) 예측가능성, 발행시장의 환경¹⁶¹⁾ 등을 고려하여 청약금액을 기준으로 하고, (2) 조각투자 및 토큰증권 시장의 균등한 투자기회 제공, 예탁결제원 등 중앙기록관리기관의 부존재¹⁶²⁾, 과도한 투자한도 규제로 인한 시장침체 가능성 등을 고려하여 연간 총 (누적)청약한도나 발행인별 연간 (누적)청약한도를 구체적으로 제한하기보다는 현행과 같이 증권별 한도를 정하도록 하며, (3) 높은 투자위험을 이해하고 그 위험을 부담할 수 있는 적격투자자¹⁶³⁾에 대해서는 별도의 한도규제를 설정함이 타당하다고 판단된다.

투자적합성 테스트의 경우, 원칙적으로 금융상품 판매 시 투자적합성의 확인은 금융소비자보호법상 적합성원칙(제17조)을 준수하여야 한다. 2025.6.2. 개정 자본시장법 시행령에 따른 비금전신탁 수익증권 발행플랫폼이 발행하는 수익증권은 금융소비자보호법상 금융상품에 해당하므로 적합성원칙이 직접 적용되며, 클라우드펀딩의 경우 투자자에 대한 투자적합성 확인을 받을 의무를 영업행위규제에도 적용하고 있다(자본시장법 시행령 제68조 제5항 13의5). 투자계약증권의 경우 종래에는 증권신고서 심사를 통해 투자적합성 확인여부를 심사하였으나, 토큰증권 관련 자본시장법 시행(2027.2.4.) 이후에는

구분		클라우드펀딩	P2P	샌드박스	
				뮤직카우	카사
일반	총한도	연간 1천만원	잔액 4천만원 (부동산 등 별도한도)	연간 1천만원	연간 2천만원
	종목 또는 발행인별	연간 5백만원	잔액 5백만원 (SOC 3천만원)	연간 3백만원	—
적격	총한도	연간 2천만원	잔액 1억원	연간 3천만원	연간 4천만원
	종목 또는 발행인별	연간 1천만원	잔액 2천만원 (SOC 4천만원)	연간 1천만원	—

160) 금융위원회, 앞의 보도자료(2025.2.3.), 3면, 9면.

161) 현재까지 발행된 투자계약증권의 경우 청약 경쟁률이 높지 않은 편인바, 청약금액 기준으로 한도를 설정하더라도 투자금액과의 괴리가 크지 않은 편이다.

162) P2P 대출이나 클라우드펀딩의 경우 투자신청의 내용, 이용자 정보 등을 관리할 중앙기록기관이 존재하나(온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 제33조, 자본시장법 제117조의13), 투자계약증권의 경우에는 그러한 기관이 없고 투자계약증권의 양도제한 문제 등으로 인해 전자등록조차 활성화되지 않고 있다.

163) 적격투자자의 기준은 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령상 적격투자자 개념(제27조 제6항) 또는 자본시장법 시행령상 클라우드펀딩에서의 적격투자자 개념(제118조의17 제3항)을 참고할 수 있을 것이다.

금융소비자보호법 적용된다고 볼 여지가 충분한바¹⁶⁴⁾, 금융소비자보호법에 따른 투자적합성 확인이 필요할 것으로 생각된다.

한편, 증선위 사업개편 요구사항을 반영하여, 투자계약증권 발행인들은 공시, 광고, 분쟁처리 절차, 피해보상에 대한 규정을 마련하여 그 내용을 증권신고서에 기재하고, 사업자 과실로 인한 피해 발생에 대비하여 발행가액의 일정 비율을 투자자보호기금으로 예치¹⁶⁵⁾하고 있다. 자본시장법상 투자계약증권에 대해서는 정기·수시공시 제도에 대한 자본시장법상 규제가 적용되지 않고 있고, 투자계약증권의 상장사례가 존재하지 아니하여 거래소 규정(신종증권시장 운영규정)에 따른 공시도 이루어지지 않고 있는바, 발행인에 의한 자율적 공시를 진행할 필요가 있다. 또한, 금융상품의 광고, 금융상품과 관련한 분쟁처리 및 손해배상책임에 관한 내용은 금융소비자보호법이 정하고 있는데, 종래에는 투자계약증권의 금융소비자보호법 적용여부가 불투명한바 자율규제 형태로 이를 운영하여 왔으나, 토큰증권 관련 자본시장법 시행 이후에는 금융소비자보호법을 준수할 필요가 있을 것으로 생각된다.

요컨대 현재 투자계약증권 발행 시 증권신고서에 기재하고 있는 투자자 보호조치들은 자본시장법 및 금융소비자보호법상 규제 적용이 배제됨에도 불구하고 높은 투자위험이 존재함으로 인해 투자자 보호의 필요성이 인정됨에 따른 임시적인 조치로 생각된다. 토큰증권 관련 자본시장법 개정으로 금융소비자보호법 적용과 관련한 난점은 해소되었으나, 금융소비자보호법이 다루지 않는 투자자보호 관련 영역은 증권신고서 심사에 의존하고 있는바, 규제의 일관성을 담보하기 어렵거니와 위반 시 적절한 제재수단을 통해 발

164) 토큰증권 관련 자본시장법 개정 이전 금융소비자보호법 적용여부가 불명확하다고 보는 관점에 대하여 부연하여 소개하면 다음과 같다. 금융소비자보호법상 금융상품에는 자본시장법상 금융투자상품이 포함되고(제2조 제1호 나목), 투자계약증권은 자본시장법상 증권에 포함된다. 그러나 앞서 본 바와 같이 종래 자본시장법상 투자계약증권은 증권신고서 제출 및 불공정거래행위에 대해서만 증권으로 간주되었던 점(제4조 제1항), 금융소비자보호법 제정 이전 구 자본시장법에서는 적합성 원칙 등의 판매규제에 대하여 (자본시장법 제4조 제1항에 따라) 투자계약증권의 적용을 배제하였던 점 등을 고려하면 투자계약증권에 대하여 금융소비자보호법이 적용되는지가 명확하지 않은 측면이 존재하며 이에 대한 유권해석 등 금융당국의 입장을 찾기도 어려워 보인다.

그런데 2026.2.3. 자본시장법 개정에 따라 위 자본시장법 제4조 제1항 단서규정이 삭제되었는바, 투자계약증권이 금융소비자보호법 적용대상이 아니라는 견해의 타당성은 감소할 것으로 보인다.

165) 투자자보호기금의 유용을 막기 위하여, 투자자보호기금을 특정금전신탁으로 신탁하거나 예치기관과 인출사유를 제한하는 계약을 체결하고, 인출 시 이사회 결의 필요 등의 내부통제정책을 수행하고 있으며, 그 내용을 증권신고서에 기재하고 있다.

행인을 통제하기 어려운 측면도 존재할 것으로 생각된다. 이에 따라, 입법론상으로는 ① (앞서 언급한) 투자계약증권 발행인에 대한 인가제를 도입함과 함께 발행인에 대한 영업 행위 규제, 공시규제, 투자한도 규제 등 투자자 보호 관련 규제를 도입함이 타당하다.¹⁶⁶⁾ 다만 법령개정 전까지는 기존에 발표한 “투자계약증권 투자자 보호 모범규준”의 내용을 지속적으로 보완하여 당국의 입장을 시장에 알리고, 새로 제기된 투자자 보호 관련 쟁점을 자율규제에 적절히 반영하도록 할 필요가 있다고 생각된다.

(5) 투자자 권리행사 관련

현재 발행된 미술품·한우 투자계약증권은 투자자들에게 투자자총회를 통한 공동사업의 운영에 대한 집단적 권리행사를 인정하거나, 특정 수익률에 미달하는 경우에는 기초자산의 처분권한을 발행인에게 위임하지 않는¹⁶⁷⁾ 등 단순히 공동사업에서 발생한 수익을 귀속받는 소극적 투자자의 범위를 넘어서 공동사업의 운영에 관여할 수 있는 수단이 마련되어 있다. 투자자총회의 소집절차, 결의사항 및 정족수에 대한 내용은 투자계약증권별로 상이하나, (i) 투자자총회는 일정지분 이상(예컨대 10%)의 투자자가 소집 가능하며, (ii) 투자자총회의 일반적인 결의사항(통상적인 정족수는 증권 과반수)은 이행결과의 보고, 공시 요구, 공동사업의 운영방향의 권고 등이 있으며, 특별 결의사항(통상적인 정족수는 증권 전부)으로는 기초자산의 처분, 공동사업의 조기종료, 사업자에 대한 위임의 해지, 공유물 분할 등이 있다.

공동사업에 대한 투자자의 권리행사는 투자자 보호와 관련한 사항이면서 동시에 투자계약증권과 집합투자를 구분하는 요소라고 할 수 있다. 집합투자적 요소를 가진 계약 중 집합투자기구를 사용하지 않는 투자구조가 투자계약증권의 전형적인 사업구조인데, 그와 동시에 집합투자(자본시장법 제6조 제5항)의 요건을 충족하지 아니하여야 한

166) 참고로, 투자계약증권 발행인에 대한 인가제 또는 등록제가 도입되지 않는 경우에는, 투자계약증권에 금융소비자보호법이 적용되는 경우 발행인은 금융상품판매업자 등록의무가 발생할 것으로 생각된다(같은 견해로, 이영경, 앞의 논문(2022), 50면).

167) 예컨대 열매컴퍼니가 2023.11.23. 첨부·제출한 투자계약서 [별첨 3]에 의하면, 매각차익이 8% 이상인 경우에만 미술품의 처분권한이 위임되며, 투게더아트가 2025.10.22. 첨부·제출한 투자계약서 [별첨 3]에 의하면 공모총액 대비 100% 미만 가격으로 처분 시 투자자총회의 전원결의가 필요하다. 다만, 이와 같은 처분가격의 제한 없이, 처분방식만을 제한(기초자산을 수익계약을 매각하는 경우 매각단가를 동급의 전국경매단가 7일 평균가격으로 처분)하는 경우도 있다(2025.10.10. 스타키피가 첨부·제출한 투자계약서 제24조).

다.¹⁶⁸⁾ 집합투자의 가장 중요한 요건은 “투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니할 것”인데, 투자계약증권을 발행하기 위해서는 이 요건을 충족하지 않아야 하는 것이다. 그런데 현재 투자계약증권에서의 투자자의 권한은 “일상적인 운용지시”를 하는 정도라고 볼 수 있을 것인가? 투자계약증권의 증권신고서에 첨부되는 법률검토의견에서는 (i) 기초자산의 처분권한에 대한 위임이 일정한 조건(처분가격에 대한 제한 등)에서만 유효하다는 점, (ii) 투자자 전원의 합의에 따라 처분권한의 위임을 철회하거나, 공동사업을 조기종료하는 등 공동사업의 중요사항을 결정할 수 있어 자본시장법상 집합투자의 제외규정(자본시장법, 제6조 제5항 제3호, 시행령 제6조 제4항 제13호)에 해당할 수 있는 점, (iii) 투자자에게 기초자산의 소유권을 이전하는 점 등에 주목하여 자본시장법의 집합투자에 해당하지 않는다고 판단하고 있다.¹⁶⁹⁾ 각각의 요소는 일응의 타당성이 있다고 판단되나, 현재 발행된 투자계약증권에서 이러한 권한은 공동사업에서의 최소한의 거부권의 기능만을 수행하고 있는바 통상적인 공동사업의 관리와 운영, 청산업무는 발행인이 전적으로 수행하고 있다고 볼 여지도 충분하며, 이러한 점에서 투자자들에 의한 “일상적 운용지시”에 대해 의문을 제기하는 시각도 존재한다.¹⁷⁰⁾

이러한 의문점을 종식하기 위한 대안으로서, 투자계약증권이 집합투자로 분류될 위험을 배제하고 예측가능성과 안정성을 제고하기 위하여 감독당국이 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제15호에 의해 부여된 권한을 사용하여 공모 규제를 준수한 투자계약증권 발행을 집합투자에 해당하지 아니한다고 명시적으로 정하는 것이 타당하다는 견해¹⁷¹⁾가 있는데, 충분히 고려할 만한 방안이라고 생각된다. 무인가 집합투자업 해당여부는 사업자가 증권신고서 제출 전 당국에 투자계약증권의 증권성 판단을 문의하는 단계 또는 증권신고서 제출 이전 필수첨부서류(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(이하 “증발공 규정”) 제2-6조 제8항 제7호)인 법률의견 준비¹⁷²⁾ 단계에서도 개별적으로 판단할 수 있기 때문에, 무인가 집합투자업을 위한 우회 수단으로 활용될 우려는 상대적으로 적을 것으로 보이고, 이미 투자계약증권에 대해 증선위 사업개편 단계에서 도산절연 등 다양한 투

168) 이 경우 집합투자업 인가를 받을 필요가 있기 때문이며, “조각투자 등 신종증권 사업 관련 가이드라인”에서도 인가가 필요한 집합투자업에 해당하는지 여부를 검토·확인하여야 한다고 한다.

169) 2025.6.26.자 열매컴퍼니의 증권신고서, 2025.10.10.자 스타키퍼의 증권신고서, 2025.10.22.자 투게더아트의 증권신고서에 각 첨부된 법률검토의견 참조.

170) 이한진, 앞의 논문(2023), 150면.

171) 이한준, 앞의 논문(2023), 150면.

172) 통상적으로 투자계약증권의 증권신고서에 첨부되는 법률의견에는, 투자계약증권 해당여부에 대한 의견을 개진하면서 투자계약증권의 보충성 원칙에 따라 타 유형의 증권에 해당하지 않는다는 점을 검토하고 있다.

자자 보호사항을 요구한 바 있으므로 투자자 보호가 곤란하게 될 여지도 크지 않다고 생각된다.

(6) 소액공모 등 간이한 자금조달제도 도입 필요성

미국의 경우 (증권성이 인정되는) 토큰증권의 발행 시 증권신고서(Form S-1)를 제출하는 경우는 거의 없으며, 실무상 사모조항(Regulation D), 소액공모(Regulation A+) 또는 크라우드펀딩(Regulation CF), 역외면제(Regulation S)의 요건을 충족하여 증권신고서 제출을 면제받도록 하는 것이 일반적이다.¹⁷³⁾ 자본시장법상 투자계약증권 발행에 있어서도 사모발행 또는 소액공모요건, 크라우드펀딩 등을 적극 활용할 필요가 있는가? 이와 관련하여 토큰증권 가이드라인에서는 전문투자자 사모(청약자가 모두 전문투자자인 경우 사모로 인정), 소액공모 한도 상향(30억), 투자자 보호장치를 추가하되 한도를 높이는(100억) 신유형의 소액공모(소액공모 Tier II) 신설 등의 방향을 제시하였으나 관련 입법이 구체적으로 추진되지는 않고 있다.

생각건대 우리나라의 투자계약증권 발행시장의 단계와 규모, 제도 구축의 정도를 고려할 때 사모발행, 소액공모요건, 크라우드펀딩 등의 활용은 시기상조인 측면이 있다고 생각된다. 이론상 투자계약증권도 모집요건에 해당하지 않으면 사모 방식의 발행이 가능하고 크라우드펀딩(온라인소액투자중개)의 방법으로도 일정 규모 이하로 발행하는 경우에는 증권신고서 제출이 불필요하나(자본시장법 제117조의10 제1항), 투자자보호를 위한 제도와 실무가 갖추어지지 않은 상황에서 이러한 방식의 발행을 장려하기는 어렵다. 소액공모 역시, 최근 자본시장법 시행령으로 투자계약증권의 소액공모공시서류 규정의 적용을 배제한 취지를 고려하면 급격한 정책변화는 어렵다고 생각된다. 먼저 발행인 인가제도 도입, 투자자 보호제도 정비 및 법제화 등 금융소비자 보호를 위한 전반적인 인프라가 정리된 후에 이러한 발행방식을 정비하는 것이 타당하다. 그리고 소액공모공시서류 제도를 재도입하더라도, 투자계약증권이 발행규모가 작고 권리의 내용이 비정형적인 점을 고려하여 별도의 발행요건(예컨대, 증권 양도금지요건이 있거나, 동일한 내용의 공동사업의 발행실적이 다수 존재하는 증권 등)을 마련하는 것이 합리적이라고 생각된다.

173) 김갑래, 2021, 미국의 증권토큰발행(STO)에 관한 고찰, 자본시장포커스(2021-13호) 연구의견, 5면.

3. 투자계약증권 유통플랫폼 및 신종증권 시장 개설 관련 쟁점

(1) 투자계약증권의 양도방법

투자계약증권 자체의 양도방법은 일반적인 증권의 양도방법과 동일하다.¹⁷⁴⁾ 그러나, 현재 발행된 투자계약증권은 사업자의 도산위험과의 절연을 위하여 발행에 참여한 투자자들이 기초자산의 소유권을 공유지분의 형태로 보유하고 있는바, 투자자가 투자계약증권을 양도하는 경우에는 그 투자자가 보유한 기초자산의 공유지분도 함께 양도할 필요가 있다. 그러나 투자계약증권 자체의 양도만으로는 당연히 기초자산의 공유지분권의 변동효과를 발생시키지는 아니하므로¹⁷⁵⁾, 기초자산의 소유권 이전요건(즉 동산의 인도요건)을 갖추는 필요가 있다.

그런데 앞서 본 바와 같이 투자자는 발행인으로부터 점유개정(민법 제189조)의 방법으로 기초자산의 소유권을 인도받는바, 그 투자자는 기초자산을 (직접 또는 간접)점유하고 있는 발행인에 대하여 목적물반환청구권을 보유하고 있어서, 그 기초자산의 공유지분권을 양도하기 위한 방법(인도)으로서 발행인에 대한 목적물반환청구권의 양도(민법 제190조)를 취할 수밖에 없다. 이 때 목적물 반환청구권의 양도방법은 지명채권 양도방법(민법 제450조)에 의하여야 하는바, 채무자 및 제3자에 대한 대항력을 얻기 위해서는 확정일자 있는 증서에 의하여 채무자(발행인)의 통지·승낙을 받을 필요가 있으며, 투자계약증권 및 기초자산의 양도와 직접적인 관련은 없으나 그러한 증권 및 물권의 권리변동을 증명하기 위한 투자자명부의 공증 작업도 실무상 요구될 것으로 생각된다.

174) 그러나 앞서 본 바와 같이 현행 예탁결제원 주식·사채 등의 전자등록업무규정(제36조 제1항 제9호) 및 동 시행세칙(제36조 제2항 제6호)상 기초자산의 소유권을 분할하여 취득하는 구조의 투자계약증권을 발행하는 경우에는 계좌부의 대체기재(전자증권법 제30조)가 제한되는바, 현재 발행되고 있는 미술품, 한우, 한돈 투자계약증권이 전자등록되더라도 계좌간 대체의 전자등록은 제한될 수 있다.

본고에서 투자계약증권의 장외거래플랫폼 및 신종증권 시장 개설과 관련한 쟁점은, 이러한 제한이 해소되어 장외거래 또는 장내거래가 가능한 제도적 환경이 조성된 것을 전제로 한다.

175) 예컨대 화물상환증(상법 제132조, 제133조)은 증서의 교부가 그 증서가 표창하는 물건(운송물)의 인도와 동일한 효력이 있고(이른바 화물상환증의 인도증권성) 이는 선하증권에서도 동일하나(상법 제861조), 투자계약증권에 대해서는 그러한 규정이 없다.

(2) 투자계약증권의 유통 관련 쟁점

(가) 투자계약증권 양도 시 기초자산의 양도방법에 대한 특례 필요성

동산을 기초자산으로 한 투자계약증권에서는 증권상의 유통을 위해서는 그 기초자산의 소유권변동이 함께 이루어져야 하며, 이를 위해 발행인은 유통이 발생할 때마다 목적물반환청구권의 확정일자 있는 증서에 의한 채권통지·승낙 및 변경된 투자자명부 공증을 하여야 한다. 채권통지·승낙 절차를 사업자가 운영하는 조각투자 플랫폼에서 제공하는 경우가 존재하나, 이 경우에도 확정일자를 부여하여야 하는 문제 및 투자자명부를 정기적으로 갱신하여야 하는 문제는 여전히 남는다.¹⁷⁶⁾ 그리고 이러한 문제는 투자계약증권이 전자등록되더라도 달라지지 않는다. 전자증권법상 계좌간 대체의 전자등록의 효력은 기초자산에 대한 권리에 미치지 않기 때문이다. 따라서 투자계약증권의 장외거래 플랫폼(유통 플랫폼) 또는 거래소가 운영하는 상장시장이 개장하더라도, 매 거래마다 기초자산의 제3자에 대한 대항력 있는 소유권 양도 구비 여부를 확인하여야 하는 점 때문에 시장이 활성화되기는 어려울 것으로 생각된다.

이러한 문제를 타개하기 위해서, 우선 ① 투자계약증권의 양도 시 기초자산의 물건 양도의 효력이 동시에 발생하도록 하는 특례규정을 자본시장법에 신설하는 방안, ② 기초자산 반환청구권의 채권양도 방식에 대한 특례규정을 자본시장법에 신설하여 플랫폼 또는 거래소가 운영하는 시스템을 통한 채권양도 통지에 지명채권의 확정일자 있는 통지의 효력을 부여하는 방안을 고려할 수 있을 것으로 생각된다.¹⁷⁷⁾ 전자는 투자계약증권에 대하여 앞서 언급한 상법상 화물상환증의 처분증권성 및 화물상환증교부의 물권적 효력(상법 제132조, 제133조)과 유사한 효력을 부여하는 것이다. 후자의 경우 일본의 “산업

176) 가령 투게더아트가 제출한 2025.10.22.자 증권신고서의 “VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 8. 증권 양도시 필요한 절차” 참조. 양도 통지와 양도 승낙의 방법과 절차를 투게더아트가 운영하는 홈페이지를 통해 전자적 방식으로 제공한다고 안내하고 있으나, 투자계약서상 확정일자의 부여는 그와는 별개로 투자자가 자신의 비용을 부담하여 발행인(공동사업 운영자)에게 확정일자를 부여해 줄 것을 요청할 수 있도록 하고 있다(제18조 제3항).

177) 우리나라의 법제상 채권양도의 특례에 관한 제도로는 자산유동화에 관한 법률(이하 “자산유동화법”)상 채권양도의 대항요건에 관한 특례(제7조)를 들 수 있다. 그런데 위 특례에 따르면 제3자에 대한 대항요건 구비를 위해서는 자산보유자 또는 유동화전문회사가 금융위에 자산양도 사실을 등록하여야 하는바(자산유동화법 제7조 제2항), 이를 투자계약증권의 거래에 적용한다면 개별 매매거래에 대하여 자산양도 등록 의무가 발생하게 될 것인바, 투자계약증권의 장내 또는 장외매매에 위 규정의 특례를 준용하기는 실무적으로 어려울 것으로 생각되어 별도의 대안으로 검토하지는 않았다.

경쟁력강화법”에서 정한 채권양도의 통지 관련 특례 사례를 참고할 수 있을 것인데, 동법(제11조의2)에 의하면 채권의 양도통지 또는 승낙이 신사업활동실시자가 신사업활동계획에 따라 제공하는 정보시스템을 이용하여 이루어지는 경우 그 채권양도통지를 일본 민법(제467조 제2항)에서 정한 확정일자 있는 증서에 의한 통지 또는 승낙으로 간주하고, 그 양도통지 등이 있었던 일자를 확정일자로 간주한다. 동법에 의한 인정신사업활동 실시자는 통지·승낙의 방법으로 SMS의 통신단말 또는 블록체인 시스템을 이용하고 있으며, 금전채권 외에도 신탁수익권, 익명조합 출자지분도 거래대상에 포함되고 있고, 이 중 익명조합 출자지분은 증권토큰(Security Token)의 형태로 거래가 이루어지고 있다.¹⁷⁸⁾ 생각건대, 전자의 경우 현재 투자계약증권의 발행규모가 크지 않은 점, 운송거래에서의 화물상환증이나 선하증권과 같은 상관습이 확립되어 있는 상황도 아닌 점 등을 고려하면, 민법상 물권의 양도방법 자체에 대한 중대한 예외를 인정하는 것은 다소 과도한 측면이 있다고 생각된다. 동산의 물권양도에 대한 민법상 양도방법(반환청구권의 채권양도방식)은 유지하되, 채권양도방식의 특례를 두는 후자의 방식이 법적안정성에 부합하며 실현가능성도 보다 높을 것으로 생각된다.

(나) 투자계약증권 유통시장 규제 검토

토큰증권 가이드라인에서 언급된 투자계약증권의 유통규제의 변화는, ① 자본시장법상 증권 유통제도의 적용, ② 투자계약증권의 장외유통플랫폼 제도화, ③ 투자계약증권 상장시장(KRX 디지털 증권시장) 개설로 요약될 수 있다. 자본시장법상 증권 유통제도의 적용과 관련해서는, 앞서 언급한 바와 같이 투자계약증권의 자본시장법 적용 배제규정(자본시장법 제4조 제1항 단서)을 삭제하는 내용의 자본시장법 개정이 2026.2.3. 완료되었다. 투자계약증권의 발행이 실제로 이루어지면서, 그 유통에 실무상 난점이 존재하기는 하나 유통가능성이 발생하여 투자자를 보호할 필요가 발생한 이상 이러한 개정 방향은 타당하다고 생각된다.

다음으로 투자계약증권의 유통플랫폼 제도화 방안의 경우, 장외거래 중개 인가단위가 신설되고 시장의 운영 관련 규제(발행-유통시장 분리, 일반투자자 투자한도 제한 등)가 신설된 비금전신탁 수익증권과 달리, 관련 규제의 신설 추진이 이루어지지 않고 있는

178) 신봉근, 2025, 채권양도의 디지털화에 대한 일본법의 현황, 재산법연구 제42권 제2호, 147면, 152면.

상황이며, 이는 앞서 언급한 기초자산의 양도와 관련한 난점으로 인해 투자계약증권의 유통이 활발하지 않은 점과 무관하지 않아 보인다.¹⁷⁹⁾ 만약 앞서 언급한 기초자산의 양도와 관련한 특례가 신설되어 투자계약증권의 유통가능성이 증대되는 경우, 유통플랫폼 규제의 내용은 어떠해야 하는가? 생각건대 규제차익 방지를 위하여 인가요건·업무기준·영업행위규제·발행/유통 분리 등과 관련한 비금전신탁 수익증권 유통플랫폼의 규제(자본시장법 시행령 제178조의2 제2항, 금융투자업규정 제5-2조의3 제6항, 제7항) 내용¹⁸⁰⁾ 및 토큰증권 관련 자본시장법 개정안에서 정한 일반투자자의 장외거래 한도 규제(제166조 제3항)를 동일하게 적용하고, 매출신고서 제출에 대한 특례(자본시장법 시행령 제137조 제3항)를 확장 적용하되, 거래한도를 정할 때 투자계약증권의 비정형성을 고려하여 비금전신탁 수익증권 대비 보수적으로 조정하도록 하는 등 세부 내용은 탄력적으로 정할 필요가 있다.

이와 관련하여 금융위원회는 2025.5.2. 투자계약증권 장외거래플랫폼에 대한 혁신 금융서비스를 지정하였는데, 그 부가조건 역시 비금전신탁 수익증권의 유통규제와 유사한 수준인바 당국의 인식도 유사한 것으로 보인다. 위 서비스는 소상공인의 사업을 기반으로 발행된 투자계약증권을 거래할 수 있는 유통 서비스로서, 소상공인 사업을 기반으로 발행된 투자계약증권의 발행을 전제로 한다.¹⁸¹⁾ 즉 투자계약증권이 공모를 통해 모집되어야 하고, 보충성 원칙의 충족 및 발행사의 일정비율(5%) 인수가 필요한데, 발행사의 인수비율은 비금전신탁 수익증권 발행 시에 적용되는 (자산유동화법에 의한) 의무인수

179) 다만, 토큰증권 관련 개정 자본시장법에서는 일반투자자의 장외거래금액, 장외거래 방법 및 결제 방법을 시행령에서 정하도록 규정하고 있으므로(제166조 제3항), 토큰증권 관련 법안 통과에 따른 시행령 정비 시 투자계약증권의 장외거래 규제와 관련한 내용도 포함될 수는 있을 것으로 보인다.

180) 비금전신탁 수익증권 유통플랫폼 관련 규제의 내용을 요약하면, ①다자간 매매체결 업무가 가능한 장외거래중개업자의 투자중개업 인가단위(2o-14-1, 2o-14-2) 신설 및 자기자본·인력 요건 신설, ②신탁재산 운용에 따른 정기·수시공시 항목 추가, ③ 장외거래중개업자의 업무기준(거래대상 수익증권 지정·해제, 공시, 매매·결제, 일반투자자 거래한도, 불공정거래 대응, 분쟁 조정, 거래정보 기록·유지·보고 등) 마련(금융위는 동 업무기준의 변경 요구 가능), ④ 장외거래업자 본인 또는 특수관계인이 발행인, 인수인, 주선인, 위탁자인 증권의 중개 금지, ⑤ 매출신고서에 대한 소액투자자(지분율 5% 미만)에 대한 증권신고서 제출 면제 특례, ⑥ 장외거래중개업자의 불건전영업행위(금융투자업규정 제4-20조 제1항 제18호)(업무기준 미준수, 투자자로부터의 재산 위탁, 공매도, 증권종목간 차별행위 등) 등이다(금융위원회·금융감독원, 2025, 자본시장 분야 주요 혁신금융서비스의 제도화를 추진합니다, 보도자료, (5.8.), 9-11면 참조).

181) 현재 투자계약증권은 투자자 보호를 위하여 투자자의 재산이 사업자로부터 도산절연될 것을 요구하고 있는데, 혁신금융서비스 지정 공고상 소상공인이 발행하는 투자계약증권의 내용이 명시되어 있지는 아니하나, 기초자산이 소상공인의 매출채권인 점을 고려할 때 현행법 및 실무상 도산절연의 방법을 강구하는 것이 가능할지에 대한 검토가 필요할 것으로 보인다.

비율과 유사하다. 물적설비 및 인적 요건, 각종규정(업무규정, 상장규정, 시장감시 및 공시규정 등) 마련, 분쟁조정 처리, 시가총액 한도, 거래한도, 회전율 및 보유한도 제한 등의 내용도 비금융전신탁 수익증권 장외거래의 규제 내용과 유사하나, 투자계약증권인 점을 고려하여 타 증권 관련 혁신금융서비스 지정 사례에 비해 다소 보수적으로 설정되어 있는 측면이 있다. 예컨대, 유통증권 시가총액의 한도, 1인당 증권 보유한도는 비금융전신탁 수익증권인 항공기엔진·부동산 조각투자의 한도보다 적고, 그러한 한도의 설정근거로는 토큰증권 가이드라인에서 투자계약증권을 수익증권 대비 낮은 투자한도를 적용할 방침으로 밝힌 점을 제시되었다. 또한 적격/일반투자자의 1인당 거래한도는 비상장주식 플랫폼 혁신금융서비스 지정 시의 거래한도보다 적다.

한편 투자계약증권의 상장시장 개설과 관련하여, 앞서 언급한 바와 같이 한국거래소가 신종증권 장내시장 개설에 대해서 혁신금융서비스 지정을 받은 바 있으며, 이와 관련한 거래소의 내부규정(신종증권시장 운영규정)이 제정되어 있다. 동 내부규정상 투자계약증권과 관련한 특징적인 내용을 간략히 살펴보면, ① 투자계약증권의 신규상장신청 시에는 발행인이 투자매매업 또는 집합투자업 인가를 받지 않는 한 필요적으로 지정자문인을 선임토록 하고(제6조), ② 상장요건 및 상장유지요건에서 도산위험 절연 요건을 갖추도록 요구하고 있으며(제11조, 제14조, 제15조), ③ 투자자 보호를 위한 결산보고 및 주요사항의 신고의무를 정하고 있다(제21조, 제22조). 이러한 신종증권시장 운영규정의 내용은 전반적으로 신종증권 유통시장의 규제취지에 부합하며, 특히 도산절연을 상장요건 및 상장유지요건과 결부시킨 것은 투자자보호 측면에서 긍정적이라고 평가될 수 있다. 그러나 동 규정은 상장요건으로서 증권의 양도에 제한이 없을 것을 요구하고 있으나(제11조 제2항 제2호 차목), 동산이 기초자산인 투자계약증권의 거래를 위해서는 기초자산의 양수도에 대한 지명채권양도절차를 거쳐야 하고 앞서 살펴본 바와 같이 예탁원 규정상 투자계약증권이 전자등록이 되더라도 계좌간대체가 제한될 수 있기 때문에 해당 요건을 충족하기 어렵다. 즉 현행 신종증권시장 운영규정에 의하면 현재 발행된 투자계약증권은 (발행인 자기자본 등 발행인 관련 요건이나 기준시가총액(30억)의 규모 요건 등을 차치하더라도) 상장 및 거래가 불가능한 측면이 있는바, 이는 한계점으로 지적될 수 있다.

(3) 토큰증권 관련 입법이 발행·유통 규제에 미치는 영향

토큰증권 관련 자본시장법 및 전자증권법 법안은 복수의 의원입법안이 존재하였으나, 이를 종합한 정무위원회 대안이 발의되어 2025.12.4. 정무위원회를 통과하였고, 2026.1.15. 동 대안이 본회의를 통과하여 2026.2.3. 개정되었다.¹⁸²⁾ 동 법안의 내용은 크게 ① 전자증권법상 분산원장을 이용한 전자증권 개념 도입 및 관련 규제 신설, ② 발행인 계좌관리기관의 신설 및 관련 규제(등록제도 운영, 분산원장 이용의무, 초과분 해소의무(전자증권법 제42조) 이행을 위한 재원적립 등) 신설, ③ 자본시장법상 투자계약증권 유통규제 적용(제4조 제1항 단서 삭제), 투자계약증권 장외시장 허용, 투자계약증권 투자자 장외거래투자한도 설정, 장외거래 방법 및 결제방법에 대한 시행령 위임 등의 내용을 포함하고 있다.

이러한 토큰증권 관련 법안은 증권의 발행형식 차원에서는 블록체인 기술을 이용한 분산원장 형식의 증권발행을 국내 법제에 도입함으로써 탈중앙화된 네트워크에서 중개인의 신뢰성 대신 기술적 신뢰성을 바탕으로 스마트계약에 기반한 자동화된 거래를 진행하여 투자자들에게 다양한 투자기회를 제공할 수 있다는 혁신성이 존재한다.¹⁸³⁾ 또한 전자증권도입법을 시행함으로써 분산원장인 암호증권등록부의 권리추정력을 인정한 독일의 법제와 유사한 경향이 있으며¹⁸⁴⁾, 미국과 일본 등 주요국에서 토큰증권의 발행이 활성화되는 상황에서 국제적인 토큰증권 법제화 방향¹⁸⁵⁾에 부합하는 측면도 존재한다.

그러나 인가규제나 영업행위규제 등 증권의 발행 및 유통과 관련한 자본시장법상 규

182) 정무위원회 대안(의안번호 : 2214886, 2214887)의 제안경위를 종합하면, 자본시장법 및 전자증권법 개정안과 관련하여 김재섭의원 등 11인이 발의한 안(의안번호 : 2204919, 2204921), 민병덕의원 등 10인이 발의한 안(의안번호 : 2205681, 2205683), 강준현의원 등 15인이 발의한 안(의안번호 : 2209210, 2209208), 조승래의원 등 12인이 발의한 안(의안번호 : 2208913)이 국회에 계류 중이었으나, 위 안을 종합한 정무위원회 대안(의안번호 : 2214886, 2214887)이 2025.12.4. 정무위원회를 통과하였다.

183) 김갑래, 2022, 국내 ICO 시장과 STO 시장의 당면 과제와 발전 방향, 자본시장연구원 이슈보고서(22-13), 12면.

184) 김갑래, 2024, 토큰증권 발행·유통제도 구축에 있어서의 주요 이슈 및 발전 방안, 자본시장연구원 이슈보고서(24-12), 11면.

185) 미국의 경우 토큰증권이 미국증권법상 증권에 해당하면 증권신고서를 제출하거나 증권신고서 제출이 면제되는 방식의 증권발행(사모발행(Reg D), 소액공모(Reg A+), 크라우드펀딩(Reg CF) 등)을 진행하도록 하고 있고, 일본의 경우 금융상품거래법상 토큰증권을 유가증권에 표시되는 권리를 전자정보처리 조직을 이용하여 이전할 수 있는 재산적 가치로 표기한 것으로 정의하고 있다(김갑래, 앞의 연구의견(2021), 자본시장포커스 연구의견, 여밀림, 2021, 일본의 증권토큰발행(STO) 현황과 시사점, 자본시장포커스(2021-19호) 연구의견 참고).

제 차원에서는, 앞서 “IV.3.”에서 언급한 유통시장에서의 쟁점이 그대로 적용될 것으로 판단된다. 예컨대 토근증권 형식으로 발행된 투자계약증권에 대해서는 전자등록된 투자계약증권과 마찬가지로 권리추정력(전자증권법 제35조 제1항)이 유지될 것이나¹⁸⁶⁾, 기초자산의 양도요건을 별도로 갖추어야 하는 문제, 기초자산의 물건 자체를 확인하기 위한 수단(공증된 투자자명부 등)을 확보하여야 하는 문제는 잔존하며, 자본시장법상 증권 유통제도의 적용, 투자계약증권의 유통플랫폼(장외거래) 제도화에 관한 문제도 동일하게 존재할 것으로 생각된다.

V. 감독정책상 시사점 및 맺음말

1. 투자계약증권 감독정책상 시사점

투자계약증권의 정의, 증권성 판단, 발행 및 유통 실무와 관련하여 앞서 검토한 주요 쟁점 중, 금융감독정책 수립 차원에서 시사점이 있는 내용을 요약하면 다음과 같다.

(1) 전매차익형 공동사업의 포함

자본시장법상 투자계약증권은 그 문언상 “공동사업의 결과에 따른 손익을 귀속받는 계약상의 권리가 표시”되어야 하기 때문에 이른바 “전매차익형 공동사업”은 투자계약증권의 범주에서 제외된다고 해석하는 것이 타당하다. 그러나 전매차익형 공동사업을 포함하는 미국 증권법상 투자계약증권보다 그 외연이 좁아지는 점, 전매차익적 요소가 어느 정도 포함되어야 증권성을 상실하는지 기준을 설정하기 어려운 점, 사업성과 분배를 줄임으로써 전매차익 실현 비중을 높여서 규제를 회피할 유인이 존재하는 점, 전매차익형 공동사업을 포함하더라도 “주로 타인이 수행” 요건의 탄력적 운용을 통해 투자계약증권

186) 개정 전자증권법상 분산원장등록주식등은 분산원장 및 그 연계장부인 전자등록계좌부에 전자등록된 주식등으로서 전자등록계좌부에 전자등록된 주식등에 해당하므로(전자증권법 제2조 제4호의2), 현행 전자증권법상 권리추정력 조항(제35조)이 그대로 적용된다.

외연의 과도한 확장을 방지할 수 있는 점 등을 고려하면, 전매차익형 공동사업도 투자계약증권에 해당할 수 있도록 자본시장법상 정의를 정비하는 것이 입법론상으로는 타당하다고 생각된다.

(2) 집합투자와의 구분기준 제시

한편 집합투자와 투자계약증권을 모두 도입한 우리나라의 법제상 투자계약증권은 집합투자적 성격을 가지면서도 집합투자의 요건을 충족하여서는 안 되기 때문에 그 영역이 비교적 좁은 측면이 있으며, 그 경계를 가르는 기준 역시 불확실한 측면이 존재한다. 따라서 예측가능성의 제고를 위하여 금융당국이 집합투자 미해당 판단을 할 수 있는 권한(자본시장법 시행령 제6조 제4항 제15호)을 활용하여 증권신고서를 제출하여 투자계약증권을 발행하는 경우를 집합투자에 해당하지 않는다고 인정하는 방안을 고려할 수 있다고 판단된다.

(3) “주로 타인 수행” 범위의 확장 및 발행인 인가제도 도입

토큰증권 가이드라인에서는 “주로 타인 수행” 요건과 관련하여 “발행인의 노력이 부정할 수 없을 정도로 중대하여 사업의 성패를 좌우하는 필수적인 노력”이어야 한다고 밝히고 있으나, 이는 우리나라 및 미국의 증권성 판단 사례나 학설에 비추어보면 다소 엄격한 측면이 존재하며, 법률상·계약상 존재하는 제3자의 노력까지 포함하는 것이 타당하다고 생각된다. 다만, 발행인은 그러한 제3자와의 법률상·계약상 관계를 유지·관리할 필요가 있다.

한편 제3자의 공동사업 참여 확장에 따라, 투자계약증권 발행플랫폼화 현상이 대두될 우려가 있는데, 이를 인가규제가 아닌 개별증권에서의 증권성 판단으로 다루는 것은 투자계약증권의 집합투자적 요소, 투자자의 발행인에 대한 의존성, 부적격 발행인의 난립에 대한 제어가능성 등을 고려할 때 다소 부족한 면이 있으므로, 투자계약증권 발행인 인가규제를 신설하여 특정 규모 이상 또는 상이한 공동사업을 다수 영위하는 플랫폼업자 또는 제3자에 대한 인가제도를 운영할 필요가 있다고 보인다.

(4) 발행 및 유통 단계에서의 투자자보호 장치 마련

투자계약증권의 발행 단계에서의 투자자보호제도(청약한도, 적합성 확인, 공시, 광고, 분쟁해결 및 피해보상 등)는 투자자보호를 위해 증권신고서 심사 등의 임시적인 조치로 운영되고 있는바, 투자계약증권 발행인 인가제 도입 시 투자자보호 관련 규제 추가 등의 방안을 강구할 필요가 있다.

유통 단계에서의 투자자 보호와 관련하여, 유통플랫폼의 제도화 추진 시 비금전신탁 수익증권 유통플랫폼 제도에 준하여 인가요건, 업무기준, 영업행위규제, 발행·유통 분리, 투자자 거래한도 등을 정하되, 투자계약증권의 비정형성을 반영하여 (투자계약증권 장외 거래플랫폼 혁신금융서비스 지정 부가조건과 같이) 다소 보수적인 태도를 견지할 필요가 있다.

(5) 기초자산 양도방법에 대한 특례 마련 필요

투자계약증권의 장외거래플랫폼 및 상장시장 거래의 활성화를 위해서는 근본적으로 투자계약증권 거래 시 기초자산의 공유지분권도 함께 거래되기 위한 특례규정 마련이 필요하다. 특례의 방법으로는 투자계약증권에 처분증권성의 성격을 부여하기보다는 기초자산 반환청구권의 채권양도 방법에 대한 특례를 두어 장외거래플랫폼 또는 거래소가 채권양도통지·승낙을 수행하도록 하는 것이 타당하다고 생각된다.

(6) 투자계약증권 한정 소액공모요건 도입 필요성

투자계약증권의 사모, 소액공모, 클라우드펀딩 발행과 관련하여, 우선 발행인 인가제도 도입, 투자자 보호제도 정비 및 법제화 등 금융소비자 보호를 위한 전반적인 인프라를 정리한 후에 공모규제를 정비하여 이를 활성화하는 것이 타당하다. 그리고 공모규제 정비 시에도 투자계약증권의 특성을 반영한 별도의 발행요건(예컨대, 증권 양도금지요건이 있거나, 동일한 내용의 공동사업의 발행실적이 다수 존재하는 증권 등에 특례 인정)을 마련하는 것이 합리적이라고 생각된다.

2. 맺으면서

투자계약증권은 자본시장법의 제정과 함께 도입되었으나 조각투자 개념의 활성화 및 토큰증권 도입 논의가 진행되면서 세부적인 규제체계가 수립되기 시작되었고, 2023.12. 최초의 공모 투자계약증권이 발행된 이후 지금까지 지속적인 발행이 이루어지고 있다. 본고에서는 투자계약증권의 요건 및 판단사례를 분석한 후 발행구조 설계(증권성 판단), 발행 및 유통 단계에서 쟁점이 되는 사항을 중점적으로 검토하였다. (1) 투자계약증권의 공동사업은 사업자와 투자자간 채권적 형태의 투자계약이 보편적인 공동사업 구조가 될 것으로 보이며, (2)“손익을 귀속받는 계약상 권리” 요건에서는 법률의 문언상 전매차익형 공동사업이 배제된다고 해석되고 금융당국의 태도도 유사한 것으로 보인다. 그러나 Howey 기준과의 괴리, 전매차익적 요소의 비중에 대한 모호성, 자본시장법 규제 회피 유인 발생 가능성 등을 고려하면 입법론상으로는 전매차익형을 포함하는 것이 타당하고, 미국의 리플, 테라·루나 사건 판례, 2026.3.17.자 SEC 유권해석에서와 같이 “타인의 노력”요건과의 유기적 해석을 할 필요도 있을 것으로 보인다.

증권위의 증권성 판단사례에서는 뮤직카우 및 미술품 사례에서 투자계약증권성을 충족하지 않는다는 의견도 있으나, “이익을 얻을 목적” 요건에서 전매차익이나 자산의 보유로부터 나오는 수익이 배제되기 어려운 점 등을 고려하면 투자계약증권에 해당한다고 보는 것이 타당하다. 한편, 투자계약증권과 관련한 법원 판례 및 수사사례는 가상자산의 증권성 판단과 관련한 사안이 대부분인데, 서울남부지방법원 2019가단225099 판결에서 법원은 전매차익형 공동사업을 투자계약증권에서 배제하였으나 세부적인 판단기준이 설명되지 못한 한계점이 존재한다. 또한 “루나 코인” 사건에서 검찰과 뉴욕 남부 연방지방법원은 루나 코인이 투자계약증권에 해당한다고 판단하였다. 루나 코인의 기능(테라 코인의 가치고정 목적)을 고려하면 루나코인 보유로 인해 발생하는 수수료 수익 또는 주조차익은 “내재된 계약상 권리가거나 본질적 기능”이라고 볼 여지가 커 보여서, 서울남부지방법원 2019가단225099 판결의 논리에 따르더라도 루나코인의 투자계약증권성을 배척하기는 어려워 보인다. 그리고 거래소를 통한 루나 판매분에 대해서도 개별적 사실관계의 검토에 의해 투자계약증권의 요건을 충족하는 것으로 판단되면 투자계약증권성을 인정하는 것이 타당하다. 한편 실무상 “주로 타인이 수행” 요건과 관련해서는 제3자의 범위가 주로 문제되는데, 미국 및 우리나라의 관련 논의 및 증권발행사례를 검토할 때 제3자는 사업자와 법률상·계약상 관계가 있는 자를 포함하는 것으로 해석함이 타당하다. 또한

그로 인해 우려되는 제3자의 공동사업참여 활성화로 인한 발행인의 플랫폼화 현상에 대해서는, 증권신고서 제출 및 심사 규제만으로는 금융규제 형평 및 투자자보호 차원에서 부족한 측면이 있고 투자계약증권 발행인 인가제도를 도입함으로써 이를 해결할 필요가 있다.

공모 발행되는 투자계약증권 증권신고서에 대해서는 자본시장법상 증권신고서에 대한 심사체계가 적용되며 그와 관련하여 증선위 사업재편 요건 등을 반영한 공시서식도 마련되어 있다. 증권신고서 심사와 관련해서는 기초자산 매입 및 가치평가의 적정성, 사업자 도산위험과의 절연, 기초자산의 소유, 보관 및 처분방법, 투자자 보호장치 및 권리행사수단, 소액공모 등 공모규제 완화 필요성 등이 주로 쟁점이 된다. 그 중 투자자 보호장치는 증권신고서 심사를 통해 임시적으로 통제되고 있으나 토큰증권 관련 자본시장법 개정으로 인해 금융소비자보호법이 적용될 것으로 예상되며, 장기적으로는 자본시장법상 관련 규제의 도입을 통해 통제하는 것이 타당하다. 그리고 투자자의 권리행사는 투자계약증권과 집합투자를 구분하는 중요한 요소이나 현행 자본시장법 체계상 집합투자와의 경계가 모호해지는 측면이 있는바, 공모 투자계약증권의 발행을 명시적으로 집합투자에서 배제하여 증권성 판단에 대한 예측가능성을 제고할 필요가 있다. 그리고 금융소비자 보호를 위한 제도적 인프라가 완비되기 전에는, 공모규제를 완화하여 증권신고서 외 투자계약증권 발행을 장려하는 것은 시기상조라고 생각된다.

한편 도산절연 원칙에 따라 투자계약증권의 양도 시 기초자산의 반환청구권 양도를 통한 소유권 양도가 함께 이루어져야 하는 점이 투자계약증권의 장내·외 유통을 어렵게 하고 있는바, 채권양도에 대한 특례규정을 통하여 이를 해결할 필요가 있다. 또한, 비금전 신탁 수익증권의 유통규제에 준하여 인가규제, 업무기준, 영업행위규제, 발행·유통 분리규제, 투자한도규제 등을 도입할 필요가 있다. 그리고 토큰증권이 우리 법제에 도입되더라도 자본시장법상 증권에의 규제체계가 그대로 적용되는바 상기 논의는 여전히 유효하며, 오히려 앞으로 다가올 토큰증권 시장의 활성화에 대비하여 투자계약증권 발행 및 유통의 전(全)단계(즉 증권성 판단-발행-유통)에서 제도적 인프라를 정비할 필요성이 크다고 사료된다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

금융감독원, 2023, “투자계약증권 최초 발행 예정” 공시·심사체계 개편으로 투자자 보호를 강화하겠습니다, 보도자료, (8.1.)

_____, 2023, 2023.12.15.부터 투자계약증권 투자가 가능해집니다, 보도자료, (12.15.)

_____, 2024, 투자계약증권 투자자 보호 모범규준 마련, 보도자료(7.10.)

_____, 2024, 2023년 증권신고서 정정요구 사례, 금융감독원 공시유의사항

금융위원회, 2008, 조각투자 샌드박스 제도화, ATS의 ETF 거래 허용 등을 위한 자본법 시행령·규정 입법예고, 보도자료, (2.3.)

_____, 2022, (주)뮤직카우 및 키움증권(주) 등 2개 신탁회사의 혁신금융서비스 지정, 공고 제2022-335호, (9.7.)

_____, “투자계약증권의 성격에 대한 질의”, 금융위원회 법규유권해석(일련번호 140015)

_____, 2025, “한국ST거래(주)의 혁신금융서비스 지정”, 금융위원회 공고 제2025-300호

_____, 2026, 토큰증권 도입 및 투자계약증권 유통을 위한 「전자증권법」·「자본시장법」 개정안 국회 본회의 통과, 보도자료, (1.15.)

_____, 2026, 수익증권 장외거래중개업 (조각투자 장외거래소) 예비인가 금융위원회 정례회의(‘26.2.13.) 의결, 보도자료, (2.13.)

_____, 2026, 민·관 합동 「토큰증권 협의체」 Kick-off 회의 개최, 보도자료, (3.4.)

금융위원회·금융감독원, 2022, “저작권료 참여청구권의 증권성 여부 판단 및 (주)뮤직카우에 대한 조치”, 보도자료, (4.20.)

_____, 2022, 조각투자 등 신종증권 사업 가이드라인, 보도자료(4.28.)

_____, 2022, 조각투자 시장의 규율을 지속적으로 확립해 나가겠습니다, 보도자료, (11.29.)

_____, 2023, 조각투자 방식 신종증권 장내시장 개설 혁신금융서비스 신규 지정, 보도자료, (12.13.)

_____, 2025, 소상공인 사업 기반 투자계약증권 유통플랫폼 등 혁신금융서비스 28건 신

- 규 지정 의결, 보도자료, (5.2.)
- _____, 2025, 자본시장 분야 주요 혁신금융서비스의 제도화를 추진합니다, 보도자료, (5.8.)
- _____, 2025, 조각투자 장외거래소(유통플랫폼) 신규인가 운영방안 안내, 금융위원회 보도자료(9.4.)
- 김갑래, 2021, 미국의 증권토큰발행(STO)에 관한 고찰, 자본시장포커스(2021-13호) 연구의견
- _____, 2022, 국내 ICO 시장과 STO 시장의 당면 과제와 발전 방향, 자본시장연구원 이슈 보고서(22-13)
- _____, 2024, 토큰증권 발행·유통 제도 구축에 있어서의 주요 이슈 및 발전 방안, 자본시장연구원 이슈보고서 24-12, (6.20.)
- _____, 2024, 미연방법원의 루나 증권성 판결의 시사점, 자본시장포커스(2024-08호) 연구의견
- _____, 2024, 토큰증권 발행·유통제도 구축에 있어서의 주요 이슈 및 발전 방안, 자본시장연구원 이슈보고서(24-12)
- 김건식·송옥렬, 2004, 미국의 증권규제, 홍문사
- 김건식·정순섭, 2023, 자본시장법(제4판), 박영사
- 김종원, 2023, 투자계약증권의 판단기준에 대한 비교법적 고찰, 기업법연구 제37권 제4호
- 넘버스, 2022, 미술품 천원 투자 가능한 ‘테사’의 수익모델은? 비상장 투자노트, (12.14.) ([https:// numbersmoney.co.kr/2022121408/](https://numbersmoney.co.kr/2022121408/))
- 동아일보, 2022, “미술품 가치를 ‘데이터’로 분석합니다” 테사 에셋의 아트 애널리스트 이야기, (6.10.)
- 삼일PwC경영연구원, 2024, 조각투자의 이해 및 STO(토큰증권 발행) 시장 전망, Issue Brief(2024.6.)
- 서울남부지방검찰청, 2023, ‘테라 프로젝트’ 금융사기 사건 수사결과, 보도자료(4.25.)
- 성희활, 2022, 조각투자의 증권성에 대한 연구, 경제법연구 제21권 3호

- 신봉근, 2025, 채권양도의 디지털화에 대한 일본법의 현황, 재산법연구 제42권 제2호
- 심인숙, 2006, 미국 증권법상 증권(Security) 개념, 중앙법학 제8집 제2호
- _____, 2008, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 상 ‘투자계약증권 개념에 대한 검토, 비교사법, 제15권 제1호(통권40호)
- 여밀림, 2021, 일본의 증권토큰발행(STO) 현황과 시사점, 자본시장포커스(2021-19호) 연구의견
- 이상근·양창규·임승민, 2024, “가상자산의 증권성 판단기준에 대한 연구”, 증권법연구 제25권 제1호
- 이영경, 2022, 조각투자의 거래구조와 투자자 보호, 선진상사법률연구 통권 제99호
- 이정수, 2023, 가상자산의 증권성 판단기준 -서울남부지방법원 2020.3.25. 선고 2019가단225099 판결, 상사판례연구 제36권 제2호
- 이중기, 2023, 지급결제수단인 스테이블코인의 증권성 여부 - 루나, 테라를 중심으로, 홍익법학 제24권 제1호
- 이한준, 2023, 바람직한 조각투자 규제체계에 관한 고찰, 증권법연구 제24권 제3호
- 임재연, 2009, 미국증권법, 박영사
- _____, 2021, 자본시장법, 박영사
- 자본시장통합연구회(편), 2007, 자본시장통합법해설서, 한국증권업협회
- 재정경제부, 2006, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제정안」 설명자료, 보도자료 (6.30.)
- 전우정, 2023, 가상자산의 증권성에 대한 소고, 법조 제72권 제4호, 381면
- 조선비즈, 2023, 테라·루나, 증권 아니라는 권도형...검찰이 넘어야 할 두 가지 벽, (4.28.)
- 증권선물위원회, 2022, “한우 및 미술품 관련 5개 조각투자 서비스의 증권성 여부 및 (주)스탁피퍼 등 4개사에 대한 조치안, 의결 제218호, (11.29.)
- _____, 2022, “(주)뮤직카우의 사업재편 이행여부 점검결과 보고 및 (주)뮤직카우에 대한 제재 면제안”, 의결 제219호, (11.29.)

_____, 2023, “(주)스타키퍼 등 5개사의 사업재편 이행여부 점검결과 보고 및 5개사에 대한 제재 면제안, 의결 제135호, (7.12.))

한서희, 2023, 조각투자를 둘러싼 법적 쟁점에 관한 연구, 금융법연구 제20권 제3호

한국증권법학회, 2015, 자본시장법 주식서I(개정판), 박영사

IT조선, 2023, [테라 몰락 전말] ⑧앵커 20% 이자 주려고 ‘돌려막기’ 파국, (5.4.)

2. 해외문헌

Friel v. Dapper Labs, Inc. et al, Case 1:2021cv05837

Glenn W. Turner Enterprises, Inc., 474 F. 2d 476(9th Cir), cert. denied, 414 U.S. 821(1973)

International Brotherhood of Teamsters v. Daniel, 439 U.S. 551,560(1979)

SEC, 2019, Framework for “Investment Contract” Analysis of Digital Assets, (4.3)

SEC, 2026, Application of the Federal Securities Laws to Certain Types of Crypto Assets and Certain Transactions Involving Crypto Assets (Release Nos. 33-11412; 34-105020; File No. S7-2026-09), (3.17.)

SEC v. Ripple, Case 1:20-cv-10832-AT-SN-Document 874 (S.D.N.Y. 2021)

SEC v. Terraform Labs, Pte, Ltd., Case 1:23-cv-1346(JSR) – Document 51 (S.D.N.Y. Jul. 31, 2023)

SEC v. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293(1946)

United Housing Found., Inc. v. Forman 421 U.S. 837 (1975)

Robert C. Art, Sell A condominium, Buy A Securities Lawsuit: Unwarranted Liabilities in the Secondary Market, 53 Ohio St.L.J. 413(1992)

Analysis of Legal Issues and Supervisory Policy Implications of Investment Contract Securities Issuance and Distribution Under the FSCMA

Sanghyun Ahn*

Abstract

This paper examines the requirements and precedents on the determination of security status related to Investment Contract Securities (ICS) under the Financial Investment Services and Capital Markets Act (FSCMA), with a focus on critical issues arising during the security test, issuance and distribution. Regarding the security test, while the FSCMA currently excludes arrangements based on "resale profit-type" from the definition of ICS, it can be argued that the inclusion of this form is justifiable and necessary from a legislative perspective. These requirements are contested in the determination of security status for fractional investments, precedents, and investigative cases regarding virtual assets. Concerning practical issues, the "efforts by others" requirement should be interpreted broadly to cover third parties with a legal or contractual relationship with the promoter. The resulting problem of "issuer platformization" should be systematically addressed through the introduction of a robust issuer licensing system.

Furthermore, provisions related to investor protection mandated in the registration statement under the FSCMA serve only as temporary control mechanisms. For long-term regulatory stability, it is appropriate to introduce explicit regulations under the FSCMA. To enhance legal predictability during the issuance stage, public offering of Investment Contract Securities should be explicitly excluded from the definition of Collective Investment under the FSCMA. Finally, concerning the distribution and transfer of ICS, new special provisions must be established to resolve the issues surrounding the simultaneous transfer of both the security and its underlying asset. Distribution regulations should also be introduced by referencing and adapting the existing rules governing the circulation of non-monetary trust beneficiary certificates, ensuring regulatory parity.

Key words: Investment Contract Securities, Fractional Investment, Security Token, Judgment of Security Status, Securities Registration Statement

JEL Classifications:: K4 Legal Procedures, Legal Systems, and Illegal Behavior

* Senior Manager of Financial Supervisory Service (ash1031@fss.or.kr)